الوجيز في القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية

جمع وإعداد

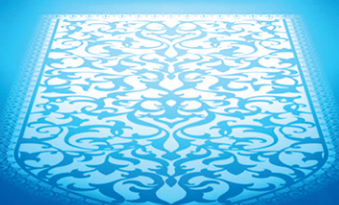
عبد الفتاح الشيخ رشيد إبراهيم

المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

من الجامعة الوطنية الصومالية








الوجيز
في القواعد الكلية
والضوابط الفقهية
في الشريعة الإسلامية

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٢٠٢٥م - ١٤٤٦ هـ

الوجيز
في القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية



Hud Hud
BOOKS

مقديشو – الصومال

تليفون: ٠٠٢٥٢٦١٦٠٠٠٥٥٠

الوجيز في القواعد الكلية
والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية

جمع وإعداد

عبد الفتاح الشيخ رشيد إبراهيم

المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

من الجامعة الوطنية الصومالية

Hud Hud
BOOKS


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المُقدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّ اللّهم وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن علم القواعد الفقهية علم مهم وضروري للمتخصصين في الفقه الإسلامي وغيرهم، فهو يعين الدارسين له على حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة في قواعد كلية قليلة سهلة، ويعمل كذلك على تكوين ملكة فقهية راسخة، وتكوين تصور عام عن الفقه وفهمه.

وقد عهدَت إليَّ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من الجامعة الوطنية الصومالية تدريس مادة: (القواعد الفقهية) لطلاب الكلية، وكان الكتاب المقرر على الطلاب هو كتاب: (القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) للأستاذ الدكتور: محمد عثمان شبير، وهو كتاب مفيد ماتع، اتبع المؤلف فيه المنهج التحليلي الذي يقوم على:

١- ذكر القاعدة وبيان أهميتها، ومفرداتها.

٢- المعنى الإجمالي للقاعدة.

٣- التأصيل الشرعي للقاعدة.

٤- تحليل عناصرها من موضوع، وحكم كليٍّ، ومناط الحكم، والمقصد الشرعي من القاعدة.

٥- تطبيقات القاعدة.

٦- القواعد الفرعية التي تندرج تحت القاعدة الكلية وتتفرع عنها.

٧- القواعد التي تمثِّل قيدًا أو ضابطًا أو استثناء من القاعدة الكلية وتندرج تحتها.

وميزة هذا الكتاب: أنه اعتمد واستفاد من جُلّ أو كلّ كتب من سبقوه في التأليف في هذا الموضوع، وبهذا يمكن وصف الكتاب بأنه زبدة الدراسات في موضوع القواعد الفقهية.

ولما رأيت الكتاب بهذه المكانة العظيمة- ورأيت أن المؤلف جزاه الله خيرًا- توسع في بعض الموضوعات، وأدخل في الكتاب بعض المباحث التي لا تتصل اتصالًا مباشرًا بموضوع القواعد الفقهية؛ مما يثقل كاهل الطالب المبتدئ في دراسة القواعد الفقهية- عزمت على تهذيب الكتاب. واتبعت المنهج التالي:

١- اختصار العبارات التي أوردها المؤلف بإسهاب وتوسع، بحيث لا تخل بالمعنى وتفي بالغرض.

٢- إيراد القاعدة.

٣- ذكر التأصيل الشرعي للقاعدة.

٤- ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة.

٥- إيراد الشروط المتعلقة بمفردات القاعدة.

٦- تطبيقات القاعدة.

٧- ذكر القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية.

٨- تطبيقات القواعد الفرعية.

٩- ذكر القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا أو استثناء للقاعدة الكلية.

١٠- تطبيقات القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا.

١١- توثيق النصوص من مصادرها الأصلية.

١٢- زيادة بعض الموضوعات التي لم يذكرها المؤلف، والتي نقلتها من مصادر أخرى.

وقد جاء الكتاب - بحمد الله وتوفيقه- على نحو نصف الكتاب الأصلي أو يزيد قليلًا، مع أنه استوفى معظم موضوعاته، واتبعت نفس تقسيمات المؤلف لفصول الكتاب، حيث جعل فصول الكتاب أربعة فصول على النحو التالي:

۞ **الفصل الأول: حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية،** ومصادر القواعد الفقهية، ونشأتها وتطورها، وأنواعها وأهميتها ومكانتها.

۞ **الفصل الثاني: فقه القواعد الكلية الكبرى،** وهي تشمل ست قواعد:

- الأمور بمقاصدها.
- اليقين لا يزول بالشك.
- الضرر يزال.
- المشقة تجلب التيسير.
- العادة محكمة.
- إعمال الكلام أولى من إهماله.

۞ الفصل الثالث: فقه القواعد الكلية الصغرى، ويشمل:

- قاعدة: التابع تابع.
- القواعد الكلية الخاصة بالضمان.
- القواعد الخاصة بالحلال والحرام.
- القواعد الخاصة بالقضاء وطرق الإثبات.
- القواعد الخاصة بالسياسة الشرعية.
- القواعد الخاصة بالاجتهاد الفقهي.

۞ الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بكل من العبادات، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية، والجنايات، والقضاء.

وبعد، فهذا جهد متواضع، فما كان فيه من توفيق فمن فضل الله وكرمه، وأسأله أن يجعله في ميزان حسناتي، وما كان فيه تقصير فمن نفسي وضعفي، والله أسأل أن يغفره ويعفو عنه تكرمًا.

وصلّى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.

عبد الفتاح الشيخ رشيد إبراهيم

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الجامعة الوطنية الصومالية
الثلاثاء/ ٢٤ جمادى الثاني /١٤٤٦هـ ٢٠٢٤/١٢/٢٥م
مقديشو- الصومال



الْفَصْلُ الأَوَّلُ

حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية

يشمل هذا الفصل المباحث التالية:

- **المبحث الأول: معنى القواعد الكلية والضوابط الفقهية والعلاقة بينهما.**
- **المبحث الثاني: القواعد الفقهية والعلوم المشابهة.**
- **المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها.**
- **المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها.**



المبحث الأول

معنى القواعد الكلية والضوابط الفقهية والعلاقة بينهما

القواعد في اللغة: مأخوذة من قعد يعقد قعودًا، وأصل القاعدة في اللغة الثبوت والاستقرار، ومنه قوله تَعَالَىٰ: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].

والقاعدة في الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها[١].

تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا:

هناك تعريفات كثيرة للقواعد الفقهية، نختار منها تعريف الشيخ مصطفى الزرقا، حيث قال: هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة، تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها[٢].

الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

فرق بعض العلماء بين القاعدة والضابط بأن الضابط يجمع فروعًا في باب واحد، أما القاعدة فهي تجمع فروعًا من أبواب شتى، فقال السيوطي: إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعًا في باب واحد.

❁ ❁ ❁

---

(١) التعريفات للجرجاني، ص: ١٧١.

(٢) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ٢/ ٩٤٧.

المبحث الثاني

القواعد الفقهية والعلوم المشابهة

توجد عدة علوم شرعية وغير شرعية ذات علاقة بالقواعد الفقهية، منها: النظريات الفقهية، والقواعد الأصولية، والقواعد المقاصدية، والأشباه والنظائر، والفروق الفقهية، والقواعد القانونية، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً: النظريات الفقهية:

بدأ الفقه الإسلامي بالفروع والجزئيات، ثم انتقل إلى القواعد الكلية والضوابط، ثم توقف العمل الاجتهادي عند مرحلة التعقيد فترة من الزمن، إلى أن ظهرت النهضة الفقهية في هذا العصر، فقام بعض العلماء بصياغة نظريات فقهية عامة، مثل: نظرية الملكية، نظرية الحق، نظرية الشرط، نظرية العقود.

فالنظرية الفقهية عبارة عن: نظام عام لموضوع فقهي خاص، تنضوي تحته مسائل وفروع فقهية عديدة، تتعلق بتعريف الموضوع، وبيان مقوماته من أركان وشروط وموانع وضوابط، وبيان آثاره، وتحديد أسباب نهايته وغير ذلك.

الفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية:

١- النظرية الفقهية أكثر اتساعًا وشمولًا من القاعدة الفقهية، وأحيانًا قد تكون القاعدة الفقهية أعم من النظرية الفقهية، فتكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي.

٢- النظرية الفقهية تتضمن في الغالب الأركان والشروط والضوابط، وهذا ما لا تتضمنه كثير من القواعد الفقهية.

٣- النظرية الفقهية لا تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها؛ لأنها مجرد هيكل عظمي ينظم مجموعات من القضايا المتجانسة في إطار ذلك الهيكل، في حين أن القاعدة الفقهية تتضمن حكمًّا فقهيًّا في ذاتها.

٤- النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث أو كتاب، في حين تصاغ القاعدة بشكل عبارة موجزة دقيقة.

ثانيًا: القواعد الأصولية:

القواعد الأصولية هي: قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، مثل:

الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف عنه.

الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.

النهي يقتضي الفور والدوام.

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

١- القواعد الأصولية ناشئة- في معظمها- عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي، في حين أن القواعد الفقهية نشأت من النصوص الشرعية ومن الاستقراء.

٢- القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع، في حين أن القواعد الفقهية متأخرة عن الجزئيات والفروع.

٣- القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، في حين أن القواعد الفقهية يفهم منها ذلك.

٤- القواعد الأصولية قواعد استدلالية يلتزمها الفقيه ليعتصم بها عن الخطأ في الاستنباط، مثل: النهي المطلق يفيد التحريم، فهي تعين الفقيه على اكتشاف الحكم الشرعي وليست هي ذات الحكم، في حين أن القواعد الفقهية تعبر عن حكم شرعي كلي مثل: الأمور بمقاصدها، فهي تتضمن حكمًا شرعيًّا كليًّا يندرج تحته جزئيات كثيرة.

٥- القواعد الأصولية أكثر اطرادًا وعمومًا، فاستثناءاتها قليلة، في حين ترد على القواعد الفقهية كثير من الاستثناءات.

٦- القواعد الأصولية لها قوة وحجة يمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم الشرعي، في حين أن القواعد الفقهية لا يصح الاعتماد عليها وحدها في بيان الحكم الشرعي، إلا إذا كانت تستند إلى دليل شرعي.

ثالثًا: القواعد المقاصدية:

القواعد المقاصدية هي: الغاية والأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية:

١- القاعدة المقاصدية تبين حِكَم الشريعة وأسرارها في تشريع الأحكام، مثل: مقصود الشارع من الرخص هو: الرفق بالمكلف من تحمل المشاق، اما القاعدة الفقهية فتبين الحكم الشرعي الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة.

٢- موضوع القاعدة المقاصدية هو أهداف الشريعة وغاياتها العامة، وموضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف.

٣- القاعدة المقاصدية لها قوة وحجة يمكن الاستناد إليها في الاستدلال، أما القاعدة الفقهية فلا يمكن الاعتماد عليها وحدها في الاستدلال إلا إذا كانت تستند إلى نص شرعي.

٤- القواعد المقاصدية مقدَّمة على القواعد الفقهية عند التعارض؛ لأن القواعد المقاصدية تعبر عن أهداف الشريعة وغاياتها، والقواعد الفقهية تعبر عن وسائل تلك الغايات، والغاية مقدمة على الوسيلة.

رابعًا: الأشباه والنظائر:

الأشباه والنظائر من علوم الفقه ويركز على الفروع الفقهية، وترجع نشأته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حيث قال في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك.

الأشباه: هي الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه، مما يقتضي التساوي في الحكم.

والنظائر: هي الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجوه ولو كان وجهًا واحًدا مما يقتضي الاختلاف في الحكم.

الفرق بين الأشباه والنظائر وبين القواعد الفقهية:

١- الأشباه والنظائر أعم من القواعد الفقهية.

٢- الأشباه والنظائر تهتم بالفروع والجزئيات المتشابهة، في حين تهتم القواعد الفقهية بالرابط الجامع للفروع والجزئيات.

خامسًا: الفروق الفقهية:

الفروق الفقهية: هي العلم الذي يُبحث فيه عن وجوه الاختلاف وأسبابها بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، فهو جزء من الأشباه والنظائر بينهما عموم وخصوص.

الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية:

١- الفروق الفقهية تهتم بالفروع الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، والقواعد الفقهية تهتم بالفروع الفقهية المتشابهة صورة ومعنى وحكمًا.

٢- الفروق الفقهية تبحث في أسباب الافتراق بين الجزئيات المتشابهة، والقواعد الفقهية تبحث في الرابط الجامع للفروع والجزئيات.

سادسًا: القواعد القانونية والمبادئ العامة:

القواعد القانونية ظهرت مع فترة الاستعمار للعالم الإسلامي، حيث طُبِّقت القوانين الوضعية في البلاد المحتلة من قبل الاستعمار.

القاعدة القانونية: هي الوحدة التي يتكون منها القانون المطبَّق في بلد ما، وهي تتسم بالخصائص التالية:

١-الوضعية؛ لأنها من وضع الإنسان، وربما يكون الدين مصدرًا من مصادرها.

٢- العناية بالسلوك الظاهر للأفراد، فلا تهتم بالنوايا الباطنة ما لم تظهر للعالم الخارجي.

٣-تنظم الروابط بين الأشخاص، وتتأثر بالزمان والمكان؛ ولهذا تختلف من دولة لأخرى ومن عصر لآخر.

٤- عامة مجردة لا تتعلق بشخص ولا بواقعة معينة.

٥- ملزمة.

٦- مصاغة صياغة دقيقة محكمة.

الفرق بين القواعد والمبادئ القانونية والقواعد الفقهية:

١- القواعد القانونية من وضع البشر، أما القواعد الفقهية فمصدرها القرآن والسنة والاجتهاد المرتبط بالقرآن والسنة.

٢- القواعد القانونية تحكم الجانب القضائي فقط، فلا تشتمل على أحكام العقيدة والعبادات والأخلاق، أما القواعد الفقهية فهي تشمل الجانب الديني والقضائي معًا، مثل العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق.

٣- القواعد القانونية تأخذ بالظاهر، ولا تلتفت إلى بواطن الأمور، في حين أن القواعد الفقهية تأخذ بالباطن مثل النية، والظاهر مثل التصرفات الفعلية والقولية.

٤- الجزاء في القواعد القانونية تقتصر على الجزاء الدنيوي، في حين أن القواعد الفقهية تشمل الجزاء الدنيوي والأخروي؛ فالقاتل عمدًا يأثم في الآخرة، ويعاقب قصاصًا في الدنيا.



المبحث الثالث

مصادر القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها

مصادر القواعد الفقهية:

القواعد الفقهية تختص بالربانية، فهي في أصلها ترجع إلى الكتاب والسنّة وروح الشريعة الإسلامية، ومصادر القواعد الفقهية أربعة:

الأول: القرآن الكريم:

فقد جاء القرآن بمبادئ عامة، وقواعد كلية وضوابط شرعية لتكون منارات يهتدي بها العلماء في تأصيل الأحكام وتقعيد الفقه.

والسرُّ في اشتمال القرآن على هذه المبادئ: هو تأكيد كمال الشريعة ومرونة التشريع وقدرته على مسايرة الأزمنة والأمكنة.

وهذه المبادئ العامة كانت مصدرًا للفقهاء في صياغة القواعد الفقهية، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: ١٨٨]

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِ﴾[البقرة: ٢٢٠] وهذه الآية أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها.

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ١٨٥] وهذه الآية أصل لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

الثاني: السنة النبوية:

لقد أُعطِي النبيّ ﷺ جوامع الكلم، والمراد بذلك: أنه كان يتكلم بلفظ قليل يفيد معاني كثيرة، وهذا غاية البلاغة، فقد كان النبيّ ﷺ ينطق بالحكمة التي تخرج مخرج القاعدة الكلية والمبدأ العام الذي ينطوي على أحكام وجزئيات كثيرة، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله ﷺ: **(المسلمون علىٰ شروطهم)**[1].

قوله ﷺ: **(الدين النصيحة)**.

قوله ﷺ: **(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)**.

قوله ﷺ: **(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىٰ)**.

قوله ﷺ: **(البينة علىٰ المدعي، واليمين علىٰ من أنكر)**.

قوله ﷺ: **(مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)**.

كل هذه الأحاديث وغيرها تعد مصدرًا من مصادر القواعد الفقهية.

---

(١) أبو داود، باب الصلح، رقم: ٣٥٩٤.

الثالث: آثار الصحابة والتابعين:

تأثر الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم بمنهج الرسول ﷺ في فهم نصوص الشريعة، وبيان مقاصدها، والتعبير عنها بعبارات موجزة تخرج مخرج القاعدة الكلية.

وقد ترك السلف الصالح آثارًا كثيرة في مجال القواعد الفقهية، ومن ذلك:

قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: **(مقاطع الحقوق عند الشرط)**[١].

وقوله أيضًا: **(لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام)**.

وقول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: **(ليس علىٰ صاحب العارية ضمان)**.

وقول شريح القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ: **(لا يقضىٰ علىٰ غائب)**.

وقوله أيضًا: **(ليس علىٰ المستعير ولا علىٰ المستودَع غير المُغِّل ضمان)**.

وقول إبراهيم النخعي رَحِمَهُ اللَّهُ: **(كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا)**.

وقول الشعبي رَحِمَهُ اللَّهُ: **(المعتدي في الصدقة كمانعها)**.

وقول قتادة رَحِمَهُ اللَّهُ: **(كل شيء لا يقاد منه فهو علىٰ العاقلة)**.

وقول حماد رَحِمَهُ اللَّهُ: **(كل فرقة كانت من قِبَلِ الرجل فهي تطليقة، وكل فرقة من قِبَل المرأة فليست بشيء)**[٢].

---

(١) هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، في باب الشروط في النكاح.

(٢) القواعد الكلية والضوابط الفقهية، الدكتور محمد عثمان شبير، ط: ٢ سنة: ١٤٢٨هـ . دار النفائس- الأردن. ص: ٤٤- ٤٥.

الرابع: اجتهادات الفقهاء:

لقد اهتم الفقهاء بموضوع القواعد الفقهية منذ العصور الأولى للفقه الإسلامي، فبذلوا جهودًا كبيرة في صياغتها والتخريج عليها والاستئناس بها في الكشف عن الأحكام الفقهية.

وقد اتبع الفقهاء في تقعيد القواعد وإنشائها طريقتين:

الأولى: استنباط القواعد الفقهية من النصوص الشرعية.

الاستنباط في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد الأصولية، وبهذا يتبين أن الطريقة الأولى لإنشاء القاعدة هي الاستنباط الذي يقوم على القواعد الأصولية، مثل:

(الأمر يفيد الوجوب).

(النهي يفيد التحريم).

(النكرة في سياق النهي تعم).

(القياس حجة) وغير ذلك.

الثانية: الاستقراء:

الاستقراء في اللغة: التتبع، وفي الاصطلاح: أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كليّ، حتى إذا وجدت حكمًا في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكليّ به.

والاستقراء نوعان: تام، وناقص.

الاستقراء التام: هو أن يثبت الحكم في كل جزئي من جزئيات الكلي، وهو

لا يكون إلا في العقليات، ويسمى: الاستقراء المنطقي، ومن أمثلته:

كل جسم متحيز، وكل متغير حادث.

الاستقراء الناقص: هو أن يثبت الحكم في الكلي لثبوته في أكثر جزئياته.

وقد اتبع الفقهاء الاستقراء الناقص في استخراج القواعد الفقهية، ومن الأمثلة على ذلك قاعدة: (الضرر يزال)، فقد استندت هذه القاعدة على نصوص شرعية تشتمل على أحكام جزئية، منها: (لا ضرر ولا ضرار).

وقوله تعالى: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ﴾[البقرة:٢٣٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ﴾[الطلاق:٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾[البقرة:٢٨٢].

فمن هذه النصوص وغيرها أُخِذت قاعدة: الضرر يزال، وهذه النصوص جزئيات وردت في موضوعات مختلفة يجمعها المعنى العام للضررالذي هو الأساس في تكوين القاعدة.

نشأة علم القواعد الفقهية وتطوره:

لقد مرّ هذا العلم بعدد من المراحل التاريخية، وهي:

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء.

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين والتطور.

المرحلة الثالثة: مرحلة الاسقرار.

المرحلة الرابعة: مرحلة النهضة العلمية.

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء: (من البعثة النبوية إلى القرن الرابع الهجري).

ترجع نشأة القواعد الفقهية إلى عصر النبيّ ﷺ، ونمت وترعرعت في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقد ضمَّن كثير من الفقهاء كتبهم الكثير من القواعد الفقهية، ومن ذلك:

١- الإمام مالك بن أنس في كتابه (المدونة)، ذكر عدة قواعد، منها: لا يرث أحد أحدًا بالشك.

٢- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه (الخراج)، ذكر فيه بعض القواعد والضوابط، منها: ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

٣-محمد بن حسن الشيباني، ذكر في كتبه عدة قواعد، منها: كل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج.

٤-الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ذكر في كتابه: الأم قاعدة: «وَلَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ وَلَا عَمَلُ عَامِلٍ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى كُلٍّ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ»[(١)].

المرحلة الثانية: مرحلة تدوين القواعد الفقهية وتطورها:

تبدأ هذه المرحلة من القرن الرابع الهجري إلى التاسع، ففيها بدأ تدوين القواعد الفقهية في كتب خاصة على يد الفقيه الحنفي «أبي الحسن الكرخي»[(٢)]،

---

(١) الأم للشافعي، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة. سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م. ج/ ١ ص:١٧٨.

(٢) الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، مُفْتِي العِرَاق، شَيْخُ الحنفيَّة، أَبُو الحَسَنِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ دَلاَّلٍ

حيث ألف رسالة صغيرة في القواعد الفقهية تعرف بـ: «أصول الكرخي» بدأها بقاعدة (ما ثبت باليقين لا يزول الشك).

وكان أبو طاهر الدباس الضرير يردد بعض القواعد الفقهية من حفظه كل ليلة بعد العشاء في المسجد بعد أن يخرج الناس، وقد أرجع فقه الإمام أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة(١).

=

البَغْدَادِيُّ، الكَرْخِيُّ، الفَقِيْهُ.

انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئاسَةُ المَذْهَب، وَانْتَشَرت تلاَمِذَتُهُ فِي البِلاَد، وَاشْتُهِرَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صيتُهُ، وَكَانَ مِنَ العُلَمَاءِ العُبَّاد ذَا تهجُّد وَأَوراد وَتَأَلُّه، وَصَبْرٍ عَلَى الفَقْرِ وَالحَاجَة، وَزُهدٍ تَامٍّ، وَوقْعٍ فِي النُّفُوْس، وَعَاشَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قال أَبُو القَاسِمِ بنُ عَلاَّنَ الوَاسِطِيُّ: لَمَّا أَصَابَ أَبَا الحَسَنِ الكَرْخِيّ الفَالِجُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، حَضَرْتُهُ، وَحَضَرَ أَصْحَابُه: أَبُو بَكْرٍ الدَّامَغَانِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الشَّاشِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ البَصْرِيّ، فَقَالُوا: هَذَا مَرَضٌ يحتَاجُ إِلَى نَفَقَة وَعِلاج، وَالشَّيْخ مُقِلٌّ، وَلا يَنْبَغِي أَن نَبذُلَه لِلنَّاسِ، فَكَتَبُوا إِلَى سَيْفِ الدَّوْلَة بنِ حَمْدَان، فَأَحسّ الشَّيْخُ بِمَا هُم فِيْه، فَبَكَى، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تجعلْ رِزْقِي إِلَّا مِنْ حَيْثُ عَوَّدتَنِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْمَل إِلَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ سَيْف الدَّوْلَة عَشْرَة آلاَف دِرْهَم، فتُصدِّق بِهَا عَنْهُ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَكَانَ رَأْسًا فِي الاعتزَال - الله يُسَامحه. سير أعلام النبلاء. ج/ ١٥ ص:٤٢٦.

(١) حَكَى الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ: أَنَّ بَعْض أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة بِهَرَاةَ بَلَغَهُ أَنَّ الْإِمَام أَبَا طَاهِرٍ الدَّبَّاسَ إِمَام الْحَنَفِيَّة بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، رَدَّ جَمِيع مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة إِلَى سَبْع عَشْرَة قَاعِدَة، فَسَافَرَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو طَاهِرٍ ضَرِيرًا، وَكَانَ يُكَرِّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ بِمَسْجِدِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْهُ، فَالْتَفَّ الْهَرَوِيُّ بِحَصِيرٍ، وَخَرَجَ النَّاسُ، وَأَغْلَقَ أَبُو طَاهِرٍ الْمَسْجِدَ وَسَرَدَ مِنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ سَبْعًا، فَحَصَلَتْ لِلْهَرَوِيِّ سَعْلَةٌ فَأَحَسَّ بِهِ أَبُو طَاهِرٍ فَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مَنْ الْمَسْجِد، ثُمَّ لَمْ يُكَرِّرْهَا فِيهِ بَعْد ذَلِكَ، فَرَجَعَ الْهَرَوِيُّ إِلَى أَصْحَابه، وَتَلَا عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّبْع. قَالَ الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا بَلَغَ الْقَاضِي حُسَيْنًا ذَلِكَ رَدَّ جَمِيع مَذْهَب الشَّافِعِيِّ إِلَى أَرْبَع قَوَاعِد:

الْأُولَى: الْيَقِين لَا يُزَال بِالشَّكِّ.

وَالثَّانِيَة: الْمَشَقَّة تَجْلِب التَّيْسِير.

=

وكان محمد بن الحارث الخشني المالكي (٣٦١) وأبو الليث السمرقندي (٣٧٣) وأبو زيد عبيد الله الدبوسي (٤٣٠) ممن اهتم بالقواعد الفقهية في كتبهم.

ومنذ ذلك الوقت إلى نهاية القرن التاسع استمر التدوين للقواعد الفقهية فظهرت عدة مؤلفات في القواعد الفقهية، منها:

القواعد في فروع الشافعية لأبي حامد الجاجرمي (٦١٣)، وهو كتاب غير موجود.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للشيخ عز الدين ابن عبد السلام (٦٦٠).

الأصول والضوابط للإمام أبي زكريا النووي (٦٧٦).

أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (٦٨٤)، وغير ذلك من كتب القواعد الفقهية.

وبعد منتصف القرن الثامن الهجري تحددت مناهج الترتيب والتنظيم في ثلاثة مناهج، وهي:

الأولى: ترتيب القواعد الفقهية على ترتيب الكتب الفقه، كقواعد ابن رجب الحنبلي.

والثاني: ترتيب القواعد الفقهية على حسب عمومها وخصوصها وموضوعها، مثل: الأشباه والنظائر للسبكي.

والثالث: ترتيب القواعد الفقهية وفق الترتيب الهجائي لحروف المعجم، كالمنثور في القواعد للزركشي.

= **الثَّالِثَة**: الضَّرَر يُزَال.

الرَّابِعَة: الْعَادَة مُحَكَّمَةٌ. (الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:٧).

المرحلة الثالثة: مرحلة استقرار القواعد الفقهية:

تبدأ هذه المرحلة منذ بداية القرن العاشر الهجري إلى ما قبل تأليف مجلة الأحكام العدلية، ومن أشهر المؤلفين للقواعد الفقهية في هذه المرحلة:

جلال الدين السيوطي الشافعي (٩١١) ألف كتاب "الأشباه والنظائر"، وقد حظي هذا الكتاب بالنظم والاختصار والشرح.

جمال الدين بن عبد الهادي (٩٠٩)، له كتاب: القواعد الكلية والضوابط الفقهية.

زين الدين ابن نجيم الحنفي (٩٧٠) له كتاب: الأشباه والنظائر، وهو من أهم كتب القواعد عند الحنفية، وقد حظي كتاب ابن نجيم بأعمال كثيرة من تبويب وترتيب وشرح واختصار وتعقيب ونظم وحل مبهمات، وغير ذلك من الكتب.

المرحلة الرابعة: مرحلة النهضة العلمية في مجال القواعد الفقهية:

المرحلة الأخيرة تبدأ من نهاية القرن الثالث الهجري، وتمتد إلى أيامنا هذه، وأول معالم هذه المرحلة هو ظهور مجلة الأحكام العدلية التي عرضت القواعد الفقهية على شكل مواد.

ومن معالم النهضة العلمية في هذه المرحلة ما يلي:

أولا: تقنين القواعد الفقهية

والمراد بتقنين القواعد الفقهية: صياغة القواعد في صورة مبادئ عامة مرتبة في صورة مواد ومبوبة بحسب الموضوعات، تسهل على القاضي الكشف عن الحكم الشرعي، ومن مؤلفات هذا النوع:

- مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية، ومجموع القواعد في هذه المجلة ٩٩ قاعدة.

وقد حظيت تلك القواعد بالاهتمام والشرح من قِبَلِ كثير من العلماء، منهم: الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء، حيث شرح القواعد في كتابه: المدخل الفقهي العام، وأضاف إليها إحدى وثلاثين قاعدة أخرى، وهو شرح موجز مفيد.

- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ أحمد بن عبد الله القاري.

ثانيًا: تحقيق طائفة من كتب التراث في القواعد الفقهية:

اهتم كثير من طلبة العلم بنشر كتب القواعد الفقهية وتحقيقها، ومن الكتب التي حُققت:

المنثور في القواعد للزركشي، تحقيق تيسير فائق.

القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام، تحقيق جلال الدين عبد الرحمن.

الأشباه والنظائر للسبكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وغير ذلك.

ثالثًا: استخلاص القواعد والضوابط الفقهية من أمهات كتب الفقه:

إن أمهات كتب الفقه مثل الأم للشافعي، والمبسوط للسرخسي، والاستذكار لابن عبد البرّ تنضوي على قواعد كلية وضوابط فقهية كثيرة تعين الباحثين على تصنيف القواعد حسب الموضوعات الفقهية، ومن الكتب التي

أُلِّفت في ذلك:

الفرائد البهية في القواعد والضوابط الفقهية لمحمود حمزة الحسيني، جمع قواعد كثيرة من كتب الفقه الحنفي.

القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي، جمع قواعد وضوابط من كتب الفقه الحنبلي، وغير ذلك.

رابعًا: رصد القواعد وإحصاؤها وترتيبها:

كتب الفقه مليئة بالقواعد الفقهية، وهذا يحتاج إلى تتبع وملاحظة تلك القواعد وجمعها، وقد قام بهذا العمل بعض العلماء، منهم: الشيخ محمد عميم الإحسان البنغلادشي، جمع في كتابه: قواعد الفقه ما تفرق في أصول الكرخي، وتأسيس النظر للدبوسي، وآداب المفتي، والتعريفات الفقهية، والقواعد الفقهية، فبلغ مجموع ذلك٤٢٦ قاعدة فقهية.

خامسًا: تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة:

لم يكن هذا العمل من مبتكرات العلماء المعاصرين، بل قام به العلماء السابقون كالقرافي (٦٨٤) في كتابه: الأمنية في إدراك النية، وابن عابدين (١٢٥٢) في كتابه: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ولكن العلماء المعاصرين اهتموا بهذا الأمر أكثر من السابقين، ومن الموضوعات التي لاقت اهتمام المعاصرين، وألفوا فيها البحوث ما يلي:

النية والقواعد المتعلقة بها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وما يتعلق بها،

والضرورة الشرعية وما يتعلق بها، والعرف والعادة وما يتصل بها، واليقين لا يزول بالشك وما يتعلق به، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أفرد لها البعض بالدراسة، والغنم بالغرم، وغير ذلك من القواعد الكلية التي وجدت مؤلفات تتعلق بها.

سادسًا: جمع القواعد الفقهية ذات الموضوع الواحد:

من الموضوعات المعاصرة في مجال القواعد الفقهية جمع القواعد ذات الموضوع الواحد في مصنف واحد، كقواعد التيسير، وقواعد القعود، وقواعد الجنايات والإثبات، وقواعد الاقتصاد وغير ذلك. ومن فوائد هذه الدراسة:

رسم صورة كلية للموضوع المطروح.

التعرف على الجوانب التي لم تعالجها القواعد الفقهية.

سد النقص فيها عن طريق إنشاء قواعد جديدة.

ومن مؤلفات هذا الموضوع كتب ألفت في قواعد الضمان، وقواعد النظام الاقتصادي، وقواعد نظام القضاء، وقواعد المقاصد، وغير ذلك.

سابعًا: الاهتمام بالمدخل لعلم القواعد «الدراسة النظرية»:

ظهرت في هذا العصر دراسات علمية تتعلق بالمدخل لعلم القواعد، حيث تبين حقيقة القواعد، وتاريخ نشأتها وتطورها وأهميتها، وأقسام القواعد وحجيتها، وممن ألف في ذلك:

على الندوي، ويعقوب باحسين، ومصطفى الزرقاء، ومحمد الزحيلي، ومحمد صدقي البورنو، وغيرهم.

المبحث الرابع

أنواع القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها

القواعد الفقهية كثيرة العدد، لكن يمكن تقسيمها إلى أقسام رئيسة، ويتناول هذا المبحث مطلبين، هما:

المطلب الأول: أنواع القواعد الفقهية:

تتنوع القواعد الفقهية باعتبارات مختلفة إلى عدة أنواع، منها:

١- تقسيم القواعد باعتبار الشمول والاتساع، تنقسم إلى:

أ- القواعد الكلية الكبرى الشاملة، وهي القواعد الخمس التي ذكرها السيوطي: "اليقين لا يزول بالشك" "الأمور بمقاصدها" "المشقة تجلب التيسير" "الضرر يزال" "العادة محكمة" ويضاف إليها "إعمال الكلام أولى من إهماله".

ب- القواعد التي هي أقل شمولًا من الكبرى، وسماها الطوفي بالصغرى، فهي تدخل في أبواب كثيرة من الفقه، لكنها أقل شمولًا من القواعد الكبرى، ومنها: التابع تابع، الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

ج- القواعد الخاصة بباب فقهي خاص، وهي التي ترجع إليها مسائل كثيرة في باب فقهي واحد، وهي بمعنى الضابط، ومنها: "كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد".

٢- تقسييم القواعد باعتبار دليلها ومصدرها تنقسم إلى:

أ- قواعد فقهية منصوصة ورد بشأنها نص شرعي من كتاب أو سنة: مثل الخراج بالضمان.

ب- قواعد فقهية استنبطها الفقهاء من تتبع الفروع الفقهية في مواردها المختلفة، مثل قاعدة أبي حنيفة: ما غَيّر الفرض في أوله غَيّره في آخره.

٣- تقسيم القواعد باعتبار الاستقلال والتبعية، تنقسم إلىٰ:

أ- مستقلة أصلية ليست قيدًا أو شرطًا أو ضابطًا لقاعدة أخرى، ومن أمثلتها: القواعد الفقهية الست الكبرى.

ب- القواعد الفقهية التابعة: هي القواعد التي تخدم غيرها من القواعد، بأن تمثل جانبًا من جوانب القاعدة الكبرى كقاعدة: "العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني"، فإنها تمثل جانب المعاملات في قاعدة: الأمور بمقاصدها، وقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، فإنها قيد لقاعدة: الضرر يزال.

٤- تقسيم القواعد باعتبار اتفاق العلماء واختلافهم عليها، تنقسم إلىٰ:

أ- قواعد متفق عليها، وهي تنقسم إلىٰ:

- قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، كالقواعد الست الكبرى.

- قواعد متفق عليها بين أكثر المذاهب، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم، وهي أربعون عند السيوطي، مثل: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد".

ب- القواعد المختلف فيها، وهي نوعان:

- القواعد الفقهية المختلف فيها بين المذاهب الفقهية، مثل : ما حرم استعماله حرم اتخاذه" فقد اختلف فيها الحنفية والشافعية.

- القواعد المختلفة فيها بين علماء مذهب الواحد، وهي في الغالب ترد بصيغة الاستفهام، ومن أمثلتها: "العصيان هل ينافي الترخيص أم لا"؟.

المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية ومكانتها:

تتضمن دراسة القواعد الفقهية فوائد عديدة لا يستغني عنها الفقيه ولا طالب العلم الشرعي، منها:

أولاً: حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة:

فقد يندرج تحت القاعدة عدد كبير من الفروع؛ ولهذا قال القرافي: من ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات.

ثانيًا: تكوين الملكة الفقهية:

دراسة القواعد الفقهية تشكل عند طالب العلم ملكة فقهية عن طريق الأمور التالية:

- يفهم مناهج الاجتهاد والاطلاع على حقائق الفقه ومآخذه، بحيث يتمكن من تخريج الفروع على الأصول.
- إدراك مقاصد الشريعة وحِكَمِها وأسرارها.
- حفظ وضبط الفروع الفقهية في قواعد كلية.

ثالثًا: المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه ودفع التناقض:

إن دراسة القواعد الفقهية وحفظها يؤدي إلى المحافظة على المنطق العام للفقه ودفع التناقض عنه، فلا ينظر الفقيه إلى الجزئيات منفردة فقط بل يربطها بكلياتها، ولا ينظر إلى الكلي فقط دون ربطه بالجزئي، وبهذا يحافظ على وحدة الفقه ودفع التناقض عنه.

رابعًا: تكوين تصوُّر عام عن الفقه:

إن علم الفقه من أكثر العلوم الإسلامية مساسًا بحياة الناس؛ إذ فيه بيان حكم الشرع في تصرفات الإنسان ومشكلات حياته اليومية، ومعرفة جميع الفروع الفقهية شاقة على الفقيه وغيره؛ ولهذا يصار إلى جمع الفروع الفقهية في قواعد كلية أو ضوابط فقهية بهدف تكوين تصور عام عن الفقه، ومن فوائد تكوين هذا التصور العام ما يلي:

- تيسير فهم الفقه الإسلامي، فإن هذه القواعد تجمع فروعًا كثيرة في عبارة سهلة لا تعقيد فيها.

- التيسير على الباحثين من غير المختصين في الفقه، فالقواعد تساعدهم في فهم النصوص الفقهية والبحث عن الأحكام الشرعية في مظانها.

- التمهيد لصياغة نظريات كلية في الفقه الإسلامي؛ لأن هذ الفقه غنيّ بالكليات، وقد بُذِلت جهود لاستخراج بعض النظريات، والباب مفتوح.

خامسًا: أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء:

إن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم، وهذا الخلاف لا بد من وقوعه.

وكثير من مسائل الخلافات الفقهية يرجع سببها إلى القواعد الفقهية نفسها، ومن الأمثلة على ذلك: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي، فقد اختلف الفقهاء في هذه القاعدة، فمنهم من أقرها، ومنهم من لم يقرها، وبناء على هذا اختلفوا في الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدة.

سادسًا: مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام:

اختلف العلماء في اعتبار القواعد الفقهية دليلًا شرعيًّا يستند إليه في الاستنباط والترجيح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الكلية والضوابط الفقهية. وهذا مقتضى قول الجويني، وابن دقيق العيد، وابن نجيم، واستدلوا ببما يلي:

- إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية، وإن المستثنيات فيها كثيرة فلا يصلح للاستدلال.

- إن اغلب القواعد الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية، فبعضها يستند إلى استقراء ناقص، وبعضها يستند إلى الاجتهاد، وهو يحتمل الخطأ، فتعميم القاعدة على جميع الفروع نوع من المجازفة.

- إن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة ورابط لها، فلا نجعل الثمرة والرابط دليلًا للاستنباط.

القول الثاني: جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية إذا لم يعارضها أصل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا مقتضى قول الغزالي الشافعي والقرافي وابن بشير والشاطبي من المالكية، ويؤيد ذلك:

- أن القاعدة الفقهية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، ولا يقدح في كليتها وجود بعض الاستثناءات.

- أن حجية القاعدة استفيد من مجموع الأدلة الجزئية، فإن كان كل دليل جزئي حجة في نفسه، فالقاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأدلة أولى بالاحتجاج.

- أن تتبع اجتهادات الأئمة يدل على اعتبارهم لهذ القواعد واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي في الوقائع التي لم يرد فيها نص شرعي.

القول الثالث: ذهبت لجنة إعداد مجلة الأحكام العدلية إلى أن الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة الإستناد إليها في استنباط الأحكام ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب أو السنة.

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الاستدلال بالقاعدة إلا بشرط:

- أن تستند على دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.
- أن لا تعارض القاعدة أصلًا مقطوعًا به من كتاب أو سنة أو إجماع.





الفصل الثاني

فقه القواعد الكلية الكبرى

يشمل هذا الفصل المباحث التالية:

- **المبحث الأول: فقه قاعدة: الأمور بمقاصدها.**
- **المبحث الثاني: فقه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.**
- **المبحث الثالث: فقه قاعدة: الضرر يزال.**
- **المبحث الرابع: فقه قاعدة:المشقة تجلب التيسير.**
- **المبحث الخامس: فقه قاعدة: العادة محكَّمة.**
- **المبحث السادس: فقه قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.**



المبحث الأول: فقه قاعدة: الأمور بمقاصدها

معنى القاعدة:

المراد بهذه القاعدة: أن أحكام التصرفات الصادرة من الإنسان تختلف باختلاف قصد الإنسان ونيته، فالنية يكون الفعل عبادة أو غير عبادة، وبالنية يكون التصرف طاعة أو معصية، وبالنية يكون القول حلالًا أو حرامًا، وبالنية يكون العقد صحيحًا أو فاسدًا، ولا فرق بين أن يكون التصرف فعلًا أو قولًا، ومما يدل على كون الفعل تابعًا للقصد والنية قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾[البقرة: ٢٢٨]، فالزوج إذا قصد من إرجاع زوجته الإصلاح جازت الرجعة، وإن قصد بها الإضرار لم تجز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾[البقرة: ٢٣١]، فالمدار في تصرفات الإنسان الفعلية والقولية على المقاصد والنيات لا على ذات الأفعال والألفاظ.

تأصيل القاعدة:

الأدلة من القرآن: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[البينة: ٥].

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾[البقرة: ٢٢٠].

الأدلة من السنّة: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىٰ، فمن كانت هجرته إلىٰ دنيا يصيبها، أو إلىٰ امرأة ينكحها، فهجرته إلىٰ ما هاجر إليه»[(١)].

---

(١) صحيح البخاري رقم الحديث: ١.

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت: قال رسول الله ﷺ: «**يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يُخسف بأولهم وآخرهم**»، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ قال: «**يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون علىٰ نياتهم**».

عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ»[1].

الإجماع: قد أجمع العلماء على اعتبار النية في الأعمال، قال ابن القيم: فَالنِّيَّةُ رُوحُ الْعَمَلِ وَلُبُّهُ وَقِوَامُهُ، وَهُوَ تَابِعٌ لَهَا يَصِحُّ بِصِحَّتِهَا وَيَفْسُدُ بِفَسَادِهَا... وَهَذَا يَعُمُّ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَيْمَانَ وَالنُّذُورَ وَسَائِرَ الْعُقُودِ وَالْأَفْعَالِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى بِالْبَيْعِ عَقْدَ الرِّبَا حَصَلَ لَهُ الرِّبَا، وَلَا يَعْصِمُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الْبَيْعِ، وَأَنَّ مَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِّلًا، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَوَى ذَلِكَ[2].

الشبهات التي ترد على قاعدة: الأمور بمقاصدها:

هناك شبهتان تردان على هذه القاعدة، هما:

الأولىٰ: إن هذه القاعدة لم تبق على كليتها، بسبب وجود بعض الأحاديث التي تجيز النيابة في العبادات، مثل: من مات وعليه صوم صام عنه وليُّه.

---

(١) الأدب المفرد للبخاري، ٧٥٢.

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م ج/ ٣ ص: ٩١.

ويجاب عن هذه الشبهة بأن خروج بعض الجزئيات التي تدخل في القاعدة من أن يتناولها حكم القاعدة أمر مقبول، فيعمل بالقاعدة في غير تلك الجزئيات، ويعمل بالجزئيات بحسب ما ورد في السنَّة.

الثانية: أن هذه القاعدة لم تبق على كليتها بسبب وجود بعض الأحاديث التي ترتب بعض الأحكام على أعمال غير مقصودة، كتصرفات الهازل في النكاح والطلاق والرجعة، ويجاب عن هذه الشبهة بما أجيب على الشبهة الأولى.

عناصر هذه القاعدة وشروط كل عنصر منها:

هذه القاعدة مبنية علىٰ خمسة عناصر هي:

١- الأمور.

٢- الحكم، وهو اعتبار النية في الأمور.

٣- مناط الحكم، وهو النية أو القصد.

٤- الناوي، أو القاصد.

٥- مقصود الحكم على القاعدة.

وفيما يلي شروط كل عنصر من هذه العناصر.

١- **شروط الأمور**: الأمور تشمل الأقوال والأفعال الصادرة عن المكلف والتي تسمى التصرفات، وليس المراد بالأمور ذواتها، وإنما المراد أحكامها كالصحة، والفساد، والطاعة، والمعصية، والثواب، والعقاب، والوجوب، والندب، والحرام، والكراهة، وغير ذلك من الأحكام.

ويشترط في الأمور التي تصدر من المكلف عدة شروط، وهي كالآتي:

أ – أن يكون الأمر معلومًا معينًا، فيحدده المكلف ويعرف حقيقته وحكمه الشرعي؛ لأن من لا يعرف الشيء لا يصح أن يقصده أو ينويه، كما لا يصح من المكلف أن ينوي أمرًا مبهمًا، قال البغوي: من جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها.

فمن نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها لا يقع منه الطلاق.

ب– أن يكون الأمر مقدورًا على فعله عقلًا أو شرعًا أو عادة.

فغير المقدور عقلًا: أن ينوي أن يصلى بوضوئه صلاة ما، وأن لا يصليها لما فيه من التناقض.

وغير المقدور شرعًا: أن ينوي أن يصلي بوضوئه في مكان نجس.

وغير المقدور عادة: أن ينوي أن يصلي بوضوئه صلاة العيد، وهو في أول السنة، فكل عمل غير مقدور للبشر لا يتعلق به تكليف.

ج– أن يكون الأمر مكتسبًا اكتسابًا شخصيًّا، وبخاصة التكاليف المخصصة بالشخص كالصلاة مثلًا.

٢– الحُكْم، وهو اعتبار النية في الأمور.

يشترط في الحكم الذي تتعلق به القاعدة عدة شروط، هي:

أ – أن يكون الحكم ثابتًا بنص شرعي كالقرآن والسنة، أو آثار الصحابة أو الإجماع والقياس.

ب– أن يكون الحكم غير منسوخ بنص شرعي؛ لأن نسخ الحكم دلالة من الشارع على عدم اعتباره.

ج- أن لا يكون حكم القاعدة معارضًا لنص شرعي قطعي.

٣- مناط الحكم، وهو النية أو القصد.

يشترط لاعتبار النية في التصرفات عدة شروط، وهي:

أ – أن تكون النية معلومة، فالله تعالى يعلم مقاصد المكلفين ويحاسبهم عليها، أما العباد فلا يعلمون مقاصد بعضهم إلا بإحدى الطرق التالية:

-أن يقر القاصد عن نيته ويبوح بها.

-أن تدل القرائن على نية الشخص وقصده، ومن هذه القرائن:

القرينة الأولى: انتفاء المصلحة المشروعة من الفعل مع لزوم المضرة بالآخرين.

القرينة الثانية: أن يكون في تحصيل الفعل مصلحة لمن صدر عنه، لكن يترتب عليه ضرر الآخرين.

ب- أن لا تكون النية معارضة لمقصد الشارع.

مقصد الشريعة هو تحقيق مصالح العباد في دنياهم وأخراهم عن طريق جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكي يكون قصد المكلف مشروعًا لا بد أن يكون قصده موافقًا لقصد الشريعة.

ج- أن تكون النية مجزومة .

فلابد أن تكون النية جازمة لا تردد فيها ولا شك.

د- عدم التشريك في النية.

الأصل العام هو عدم التشريك في النية؛ لأن العبادة الواحدة لا تغني عن عبادتين، والتصرف الواحد لا يغني عن تصرفين، ومن ذلك أنه لا يجوز أن

يذبح الأضحية لله ولغيره، وكذلك لا يجوز أن يكبر المسبوق تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع.

ويستثنى من هذا الأصل عدة حالات يجوز التشريك فيها في النية، منها:

- يجوز التشريك في النية إذا كانت تتعلق بالوسائل، كمن نوى الصوم لله والتدواي، وغسل الجنابة مع غسل الجمعة أوالعيد، وصوم يوم عرفة مع صوم الاثنين، أو سنة الظهر مع تحية المسجد.

- يجوز التشريك في النية إذا نوى عبادة مفروضة وعبادة مندوبة معًا، على خلاف بين العلماء في المسألة.

- يجوز التشريك في النية فيما نص عليه الشارع، كالجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة.

- أن تكون النية مقارنة للأمر.

الأصل مقارنة النية لأول العبادة، فلا يصح تأخيرها عن بداية العبادة؛ لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة، فلا يبنى الباقي عليه، وأما تقديم النية فقد أجازه كثير من الفقهاء.

٤- **الناوي، أو القاصد**: القاصد هو الشخص الذي تصدر عنه التصرفات المعتبرة بالنية، ويشترط لاعتبار قصده: الأهلية، فلا بد أن يكون أهلًا لأن تصدر عنه التصرفات والنيات.

والأهلية قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

فأهلية الوجوب هي: صلاحية للإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا، وهذا القسم هو المراد هنا.

وتتحقق أهلية الأداء بالتمييز، وليس لها سنّ أو علامة معينة، فقد تتقدم أو تتأخر، ولكن الفقهاء قدروا سنّ التمييز بتمام السنة السابعة، ويلحق بغير المميز المجنون والسكران فلا تصح النية منهما.

٥- **المقصود من قاعدة: الأمور بمقاصدها:** إن مقصود النية: هو التمييز بين الأعمال الصادرة من الإنسان، وذلك بتمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كالوضوء والغسل، فكل منهما يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة، وكل من الوضوء والغسل والصلاة قد يكون فرضًا ونفلًا ونذرًا، والتيمم قد يكون من الحدث أو الجنابة، فشرعت النية لتتميز رتب العبادات بعضها عن بعض، فالتمييز يشمل أمرين:

الأول: التمييز بين الأعمال المتشابهة في الصورة، وذلك بتحديد وصفها الشرعي من فرض أو نفل أو عبادة أو عادة.

الثاني: التمييز من أجل تحديد الأهداف والغايات من العمل أو العبادة، كنية التقرب إلى الله تعالى ودفع ما يخالطها من البواعث الأخرى.

تطبيقات القاعدة:

- ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد الشهوة، فالنية هي المعيار في انتقاض الوضوء.
- ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن الملتقط إذا أشهد على اللقطة

كانت أمانة، وإن لم يشهدها كان الملتقط غاصبًا.

● للرجل أو الزوجة أن يتبرع بثلث ماله، لكن إذا علم أن تبرعه هذا بقصد الإضرار بالورثة منع منه هذا التبرع.

● لو قال شخص لآخر: أبيعك سيارتي هذه بألف، وقصد من فعل المضارع-أبيع- زمن الحال وقال المشتري: قبلت، انعقد البيع، أما إذا قصد من فعل المضارع زمن الاستقبال فلا ينعقد البيع؛ لأنه وعد بالبيع لا بيع؛ لأن فعل المضارع يحتمل الحال والمستقبل، فتحديد أحدهما يحتاج إلى نية.

القواعد التي تتعلق بقاعدة: الأمور بمقاصدها:

أولاً: القواعد التي تمثل فروعًا للقاعدة.

هناك قاعدتان تمثلان فروعًا لهذه القاعدة، وهما:

١ - قاعدة في العبادات والقربات، وهي: **(لا ثواب إلّا بالنية)**.

والثواب: ما يستحق به من الله الرحمة والمغفرة، ومن الرسول ﷺ الشفاعة.

والثواب نوعان:

- أخرويّ، وهو استحقاق الأجر والمثوبة أو العقوبة في الآخرة.
- ودنيويّ، وهو استحقاق الأجر أو العقاب الدنيوي.

والمراد بهذه القاعدة: أن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لا يتحققان في الأعمال والعبادات والقربات إلا بوجود النية، فإذا وُجدت النية وكانت خالصة لله تعالى صح العمل وحصل الثواب، وإذا فُقدت النية أو اختلت فسد العمل وكان العقاب.

تطبيقات القاعدة:

- إنفاق المال بنية السمعة والرياء لا يثاب عليه.
- الوقف بدون نية يصح، لكن ليس له ثواب، إلا إذا نوى التقرب إلى الله تعالى.
- ذبح الحيوان قد يكون للأكل فيكون مباحًا، وقد يكون للأضحية فيكون عبادة، وقد يكون لصنم فيكون حرامًا.

٢- قاعدة في المعاملات (**العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني**).

المقاصد الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد إذا ظهر منها القصد كان الاعتبار لهذا القصد، ويقيد به اللفظ ويترتب الحكم عليه.

والألفاظ بالنسبة إلىٰ مقاصد المكلفين ونياتهم ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون اللفظ مطابقًا للقصد، ويعرف ذلك بالقرائن، فحينئذ يحمل اللفظ على ظاهره.

الثاني: ما يظهر أن المتكلم لم يُرِد معنى الذي نطق به، ويُعرَف ذلك بالقرائن، وهي نوعان:

- أن لا يكون مريدًا لمقتضى كلامه ولا لغيره، كالمكره والنائم والمجنون والسكران، فلا يعتد بلفظه.

- أن يكون مريدًا لمعنى يخالف الظاهر، كالمعرض والملغز والمتأول، فيحمل على المعنى المراد لا على الظاهر.

الثالث: ما هو ظاهر في معناه، لكن يحتمل إرادة المتكلم لهذا المعنى الظاهر ولغيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، وهذا القسم هو مما اختلف

فيه الفقهاء، والراجح هو: اعتبار المقصود والمعاني لا للألفاظ الظاهرة.

والمعنىٰ الإجمالي للقاعدة هو: أن الأحكام في المعاملات تُبنَى على مقاصدها، لا على ظاهر الفاظها المستعملة في صيغة العقد (الإيجاب والقبول)؛ لأن المقاصد هي حقائق المعاملات، وإنما اعتبرت الألفاظ للدلالة على المقاصد، فإذا ظهر القصد اعتبر وبني الحكم عليه، ولكن لا يعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية ؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني، فتراعى أولًا الألفاظ بما تحمل من معاني ظاهرة، فإذا ظهرت مقاصد تعارضها وتعذر الجمع بينها وبين الألفاظ فتقدم المقاصد على الألفاظ.

وتعرف المقاصد من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو القرائن.

تطبيقات القاعدة: هذه القاعدة من القواعد التي اختلف الفقهاء فيها، ولذلك اختلفت تطبيقاتها كما قال السيوطي: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

- الهبة بشرط العوض بأن قال شخص لآخر: وهبتك سيارتي هذه بخمسة الآف دينار، فقال الآخر: قبلت، كان العقد بيعًا.
- إعارة النقود تكون قرضًا لا عارية؛ لأن النقود لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، والعارية محلها المال غير القابل لاستهلاك عينه، وهو الذي ينتفع به مع بقاء عينه.
- الإعارة بشرط العوض، بأن قال شخص لآخر: أعرتك سيارتي لتركبها إلى مقديشو بخمسين ألف شلن يكون عقد إجارة؛ لأن الإعارة هي: تمليك منفعة بغير عوض.

ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: الأمور بمقاصدها:

١- الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية.

النية المجردة عن الفعل لا أثر لها في أحكام الدنيا؛ لأن النية عمل قلبي باطني، والأحكام الدنيوية لا تبنى إلا على الأمور الظاهرة، أما الأمور الأخروية فتبنى على النيات الباطنة؛ لقوله ﷺ: «إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيَّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»[(١)].

تطبيقات القاعدة:

- إذا طلق الرجل زوجته في قلبه، ولم يتلفظ بالطلاق فلا يعد ذلك طلاقًا.
- إذا أجَّر رجل بيته لشخص، ولم يصدر من الطرف الآخر قبول، لا يعد إجارة؛ لأن الإيجاب لم يصادف قبولًا.

٢- الأصل مقارنة النية للفعل إلا إن تعذر أو تعسر ذلك، فتقدم ولا تتأخر.

يشترط في النية أن تقارن أول العبادة، ولا يجوز تأخيرها عند جمهور الفقهاء إذا كانت العبادة واجبة، أما تقديم النية عن أول العبادة فأجازه غالبية العلماء لرفع المشقة.

---

(١) صحيح البخاري ٦٤٩١.

المبحث الثاني: فقه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

معنى القاعدة:

إن الأمر الثابت ثبوتًا يقينيًّا والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنه بالأصل أو اليقين لا يرفعه شك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل، بل يبقى حكم الأصل أو اليقين ساريًا حتى يقوم الدليل المعتبر في تغيير ذلك الحكم.

تأصيل القاعدة:

إن قاعدة اليقين لا يزال بالشك من أوائل القواعد التى دخلت مجال التعقيد الفقهي، فقد ذكرها الشافعي والكرخي والدبوسي، وتستند هذه القاعدة على الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن هذه الأدلة:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾[يونس: ٣٦].

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾[النجم:٢٣].

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[النجم:٢٨]

٤ - وقال الرسول ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ

يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»(١)

٥ - «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(٢).

٦ – أجمع العلماء على هذه القاعدة، وقد نقل ذلك القرافي في الفروق، حيث قال: فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يُجعل كالمعدوم الذي يُجزم بعدمه(٣).

٧ – ومن جهة العقل فإن اليقين أقوى من الشك؛ لأن اليقين مبني على الثبوت والجزم، والشك مبني على التردد والاحتمال فلا يقوى على إزالة اليقين.

موضوع القاعدة:

موضوع القاعدة هو الحكم اليقيني: كالتيقن من إباحة شيء، أو التيقن بأن الماء بلغ قلتين، ويدخل في ذلك الأقوال والأفعال والأعيان من عبادات ومعاملات ومأكولات ومشروبات وملبوسات وغيرها.

والمراد باليقين هنا هو الاستصحاب لما تُيُقِن في الماضي، وهو الأصل، وأطلق عليه اليقين مجازًا، وإنما يراد به ما ثبت بالبينة الشرعية، سواء استند إلى علم يقيني أو ظن غالب؛لأن الأحكام الفقهية تُبنَى عليه.

---

(١) صحيح مسلم، ح/ ٥٧١.

(٢) صحيح مسلم، ح/ ٣٦٢.

(٣) الفروق، للقرافي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. ج/ ١ ص: ١١١.

والمراد بالأصل المستصحب: هو أن حكمه ثبت بدليل شرعي معتبر، ويبقى مستمرًّا ويُعمل به، ولا يلتفت إلى الاحتمالات والشكوك التي ترد عليه ما لم يعضدها دليل قوي.

الأصول اليقينية المستمرة:

١- الأصل في المياه الطهارة بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾[الفرقان: ٤٨].

٢- الأصل في الأرض وما تولد منها الطهارة، بدليل قوله ﷺ: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ»(١).

٣- الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم التحريم، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[المائدة: ٣٣]، وقوله ﷺ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»(٢).

٤- الأصل في الذبائح التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام:١٢١].

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٣٣٥.

(٢) صحيح البخاري، ح/ ١٧٣٩.

٥- الأصل في الأبعاض التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾[النساء: ٢٣].

٦- الأصل في الطلاق الحظر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾[النساء:٣٤].

٧- الأصل في المنافع الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

٨- الأصل في المضار التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾[البقرة: ٢٣٣]، وقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»(١).

٩- الأصل في الميتات التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

(١) سنن ابن ماجه، ح/ ٢٣٤١.

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[المائدة: ٣] ، وقد استثنى الشارع من ذلك ميتة السمك والجراد.

شروط الحكم اليقيني:

يشترط في الحكم اليقيني عدة شروط، هي:

أ- أن يستند الحكم اليقيني إلى دليل شرعي.

ب- أن يتحقق اليقين بالفعل، فلا عبرة باليقين التقديري، فلو تيقن من الحدث، ثم غفل عن حاله وصلى، وبعد فراغه من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أو لا؟ فصلاته صحيحة؛ لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل، ولم يوجد الشك قبله.

ج- أن لا يعارض الحكم اليقيني بما هو أرجح منه وأقوى، فإذا حصل التعارض عمل بالراجح، ويحصل التعارض في حالتين هما:

الأولى: أن يوجد أصلان يقتضي كل منهما حكمًا يخالف الآخر، فإذا كان ما يقابل الحكم اليقيني راجحًا قُدِّم عليه- والموازنة بين الراجح والمرجوح اجتهادية مختلف فيها بين الفقهاء- مثال ذلك: ظهر في المبيع عيب، وادعى كل من البائع والمشتري أن العيب حدث عند الآخر، ففي إحدى روايات الحنابلة يقدم قول البائع؛ لأن الأصل سلامة المبيع من العيب.

الثانية: أن يوجد ظاهر أرجح من الحكم اليقيني، مثل القرائن القوية المخالفة للحكم اليقيني مثل: إذا كان رجلان في سفينة محملة بالدقيق،

فادعى كل منهما السفينة وما فيها، وأحدهما يعرف بأنه تاجر دقيق، والآخر يعرف بأنه ملاح، فإن الدقيق يحكم لتاجر الدقيق، والسفينة تحكم بالملاح عملًا بالظاهر.

تطبيقات القاعدة (اليقين لا يزول بالشك):

- إذا شك من يغتسل من الجنابة هل عَمَّ الماء أم لا؟ بني على اليقين وهو عدم التعميم، ولزمه تعميم الماء ما لم يكن ذلك وسواسًا.
- إذا شك المصلي المنفرد هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، بنى على اليقين وهو الثلاث.
- إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل.
- إذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في سبب هلاكها، هل كان بتعد في حفظها أو هلكت قضاء وقدرًا؟ بنينا على اليقين، وهو أن الأصل في الإنسان الأمانة، فلا يزول هذا اليقين بالشك. فلا يضمن الوديع.

القواعد التي تتعلق بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك:

أولًا: القواعد التي تمثل فروعًا لهذه القاعدة:

هناك فروع سبعة تتفرع من هذه القاعدة، وهي:

الفرع الأول: (الأصل بقاء ما كان على ما كان):

معنىٰ القاعدة: أن ما كان محكومًا بحكم فيما مضى يبقى على ذلك الحكم ما لم يرد دليل آخر يفيد تغير ذلك الحكم الأول، وهذا الذي يسمى بالاستصحاب.

تطبيقات القاعدة:

لو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر وأنكر المؤجر ذلك، كان القول قوله مع اليمين؛ لأن الأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلى أن يثبت دفعها إلى المؤجر.

مستثنيات القاعدة:

- لو ادعى الوديع ردّ الوديعة إلى المستودع، فأنكر المستودع ذلك، يصدق الوديع مع أن الأصل بقاء الوديعة بيد الوديع، ووجه الاستثناء أن الوديع يدعي براءة ذمته، والمستودع يدعي انشغال ذمته، والأصل براءة الذمة، فتقدم البراءة الأصلية.

- لو أن أقذار دار شخص تسيل في الطريق العام أو إلى نهر يشرب منه الناس، فيرفع ذلك الضرر ولا عبرة بقدمها؛ لأن الشارع لا يمكن أن يجيز حقًّا يكون منه ضرر عام.

الفرع الثاني: (الأصل براءة الذمة):

معنىٰ القاعدة: الأصل براءة ذمم الناس من جميع أنواع التحمل والالتزام إلى أن يثبت الالتزام بالدليل؛ لأن الناس يولدون وذممهم فارغة، والتحمل صفة طارئة، فيستصحب الأصل المتيقن به، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على المُدعى عليه»[1].

---

(١) سنن الترمذي.ح/ ١٣٤١.

تطبيقات القاعدة:

- إذا ادعى شخص على آخر دَينًا لم تقبل دعواه إلا بدليل.
- إذا اتهم إنسان بذنب فإنه بريء حتى تثبت التهمة بالدليل.
- إذا اختلف المؤخر والمستأجر فالقول في مقدار الأجرة: قول المستأجر بيمينه.
- إذا أتلف إنسان مالًا واختلف المتلف والمالك في قيمة المال، فالقول قول المتلف بيمينه.

الفرع الثالث: الأصل في الأمور العارضة العدم:

معنى القاعدة: الأمور العارضة هي الصفات والأحوال الطارئة على الشيء التي لم تكن تلازم الموصوف منذ وجوده كالعيب في المبيع، ويقابل ذلك الصفات الأصلية التي تلازم الموصوف منذ وجوده ككون المبيع سليمة من العيوب، فيحكم بعدم وجود الصفات الطارئة إلى أن يثبت دليل وجودها.

تطبيقات القاعدة:

- إذا ادعى شخص شرطًا جائزًا في العقد، وأنكر الآخر ذلك، فالشروط الجائزة أمور طارئة يحتاج إلحاقها بالعقد إلى دليل وإثبات.
- إذا باع شخص مبيعًا وسلمها إلى المشتري فادعى المشتري وجود عيب فيها، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن السلامة من العيوب في المبيع هي الأصل، والعيب طارئ فلا يقبل إلا ببينة.
- إذا اختلف المضارب ورب المال في وجود ربح، فالقول قول المضارب، وعلى رب المال البينة؛ لأن الربح حالة طارئة.

مستثنيات القاعدة:

- إذا أراد الواهب الرجوع عن هبته بعد قبض الموهوب له، وادعى الموهوب له تلف الهبة فالقول قول الموهوب له بلا يمين، مع أن التلف حالة عارضة، والسبب في قبول قول الموهوب له؛ لأن الهبة بعد القبض أصبحت في ملك الموهوب له، والمرء مصدق في قوله فيما يخص ملكه الذي لا علاقة لأحد به.

- إذا طلب المسروق منه رد العين المسروقة، فادعى السارق استهلاك العين وأن عليه رد القيمة لا العين، فالقول قول السارق مع يمينه، مع أن الاستهلاك حالة طارئة، والسبب في قبول قول السارق؛ لأنه يدعي إجراء صادرًا منه-الاستهلاك- والأصل أن المرء مصدق فيما يدعي أنه أجراه بنفسه.

- إذا تصرف الزوج بمال زوجته في حياتها وبعد مماتها ادعى الورثة أنَّ تصرف الزوج كان بدون إذن الزوجة وطلبوا منه التضمين، فالقول قول الزوج مع أن الإذن حالة طارئة؛ لأن حالة الزوجية دليل على الإذن في التصرف في العادة.

الفرع الرابع: (لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان).

معنى القاعدة: الأصل عدم الاعتداد بالسكوت، ولكن قد يعتد بالسكوت أحيانًا، فالسكوت في معرض الحاجة بيان، ودلت الظروف الملابسة على ذلك، فالسكوت يحمل معنى عدم الانتباه والشرود أو عدم الاكتراث أو الاستهزاء أو الاستغراب أو الموافقة أو الإنكار أو الرفض أو غير ذلك، وإذا كان السكوت في معرض الحاجة يعتد به كسكوت النبيّ ﷺ عن إنكار قول أو فعل حدث بين

يديه أو علم به وسكت عنه، فهذا السكوت يعتبر ضمن إقرارات الرسول التي استدل بها العلماء في أحكامهم.

تطبيقات القاعدة:

- سكوت المالِك على بيع غيره ملكه لا يعتبر رضا ولا إذنًا.
- لو رأى الشخص غيره يتلف ماله لا يكون سكوته إذنًا بإتلافه، وعلى المتلف الضمان.
- لو سكن شخص في دار آخر وهي غير معدة للإيجار، فسكت، لا يعد ذلك إيجارًا.
- إذا سكتت الثيب عند استئذانها في الزواج من فلان فلا يُعَدّ سكوتها إذنًا.

أما الحالات التي يعتد بالسكوت، فمنها:

- الحالات التي تمخض فيها السكوت لمنفعة من وُجِه إليه، كسكوت المتصدق عليه، وسكوت الموقوف عليه، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له.

- الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين، ويتصل الإيجاب بهذا التعامل، مثل إذا قبض المرتهن العين بعد العقد واقترن هذا القبض سكوت الراهن، اعتبر هذا السكوت إذنًا بالقبض.

- الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا، كسكوت السيد حين يرى عبده يبيع ويشتري، فإن سكوته يعتبر إذنًا للعبد بالتجارة، دفعًا للضررعمن يتعامل معهم.

- الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضا، كسكوت البكر عند استئذانها بالتزويج، فسكوتها يعتبر إذنًا ورضا.

الفرع الخامس: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته):

معنىٰ القاعدة: إذا وقع اختلاف في زمن حدوث شيء نُسِب إلى أقرب الأوقات في الحال، ولا يعدل عن هذه النسبة إلا بدليل؛ لأن الخصمين اتفقا على حدوث الشيء، وادعى أحدهما حدوثه في وقت، وادعى الآخر حدوثه في وقت آخر قبل ذلك الوقت، فقد اتفقا على وجود العيب في الوقت الأقرب، وانفرد أحدهما بزيادة وقت آخر، وذلك يورث شكًّا في صحة كلامه، فيعمل بالوقت الأقرب؛ لأنه يقين، ويترك الوقت الأبعد؛ لأنه شك.

تطبيقات القاعدة:

- لو ادعت زوجة المتوفي أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت طلاق الفارِّ، وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته، فالقول قول الزوجة، وهو إضافة الطلاق إلى مرض الموت؛ لأنه أقرب الأوقات.
- إذا ظهر في المبيع عيب وهو عند المشتري، فاختلف البائع والمشتري في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع، فلا يجوز للمشتري فسخ البيع حتى يثبت أن العيب قديم.
- لو تزوج مسلم نصرانية، ثم مات، فادعت الزوجة أنها أسلمت قبل وفاته، وأنكر الورثة ذلك، وقالوا: بل أسلمت بعد موته، فالقول قولهم.

الفرع السادس: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل):

معنىٰ القاعدة: لا تقبل الحجة إذا وجد معها احتمال نشأ عن دليل قطعي أو ظنيّ، فإذا عارض الحجة احتمال يستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة؛ لأن مع الاحتمال يسقط الاستدلال.

تطبيقات القاعدة:

- لو أقر شخص في مرض موته لبعض الورثة بدين، لا يصح إقراره إلا بتصديق باقي الورثة؛ لاحتمال محاباة بعض الورثة.
- لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض؛ لتمكن تهمة القرابة التي تدعو إلى التحزب والتناصر فيما بينهم.

الفرع السابع (لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح):

معنى القاعدة: دلالة التصريح أقوى من دلالة الحال عند التعارض والتقدم عليها، سواء أكان التصريح قولًا أم كتابة، وعند عدم التعارض يعمل بدلالة الحال؛لأنها في حكم التصريح.

تطبيقات القاعدة:

- يجوز للبائع حبس المبيع لقبض الثمن، فلو قبض المشتري المبيع ورآه البائع وسكت كان إذنًا بالقبض، ولكن لو نهاه صراحة فلا يعتبر إذنًا بالقبض؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة.
- لو تصدق على إنسان فسكت يثبت له الملك، ولا حاجة إلى قوله: قبلت، لكن لو صرح بالرد والرفض لا يملك؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة.

ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك):

١- **قاعدة: (لا عبرة للتوهم)**: الأصل في اليقين الثبات والاستمرار، عملًا بقاعدة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فلا يرتفع اليقين بطروء الشك ولا

التوهم عليه، والتوهم هو: الاحتمال العقلي الذي لا تدل عليه قرينة ولا يصحبه مرجح، فلا يقوى على تغيير اليقين، ولا يبنى عليه حكم أصلًا.

تطبيقات القاعدة:

- إذا أدلى الثقات بشهادتهم فإنه يعمل بمقتضاها، ولا عبرة بتوهم الخطأ واحتماله.
- إذا توفي شخص عن عدد معروف من الورثة تقسم التركة بينهم، ولا تؤخر لتوهم وجود وارث آخر.

٢- **قاعدة: (لا عبرة بالظن البين خطؤه)**: الظنّ الراجح لا يقوى على تغيير حكم اليقين، ولا يبنى عليه حكم أصلًا.

تطبيقات القاعدة:

- إذا ظن المصلي أن الوقت قد دخل فصلى، ثم بان أن الوقت لم يدخل لم تجزئ تلك الصلاة، وعليه الإعادة بعد دخول الوقت .
- العقود والتصرفات والالتزامات التي ينشئها الشخص بناء على الظن، تبطل إذا تحقق خطأ هذا الظنّ.

❁ ❁ ❁

□

المبحث الثالث: فقه قاعدة : الضرر يزال

معنى القاعدة: هذه القاعدة من جوامع الأحكام، وهي أساس لمنع الفعل الضار عن النفس والغير، وتوجب دفع الضرر قبل وقوعه ورفع الضرر بعد وقوعه؛ لأن الوقاية خير من العلاج، فإذا وقع الضرر وجب إزالته وترميم آثاره.

تأصيل قاعدة (الضرر يزال):

تستند هذه القاعدة إلى نصوص كثيرة من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح والاجماع.

القرآن: نصوص تدل علىٰ النهي عن الضرر والمضارة:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾[البقرة: ٢٣١].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة:٢٣٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾[الأعراف: ٥٦].

نصوص تدل على إزالة الضرر:

قال تعالى: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴾[الأنبياء: ٧٨].

فالآيتان تدلان على إزالة الضرر وترميم الآثار الناجمة عن الضرر.

السنّة: عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»(١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»(٢).

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»(٣).

موضوع القاعدة:

موضوع القاعدة هو الضرر أو الفعل الضار، وينقسم بالاعتبارات التالية:

باعتبار محله ينقسم إلىٰ ضرر يتعلق: بالدين والنفس والعقل والعرض (النسب) والمال.

وباعتبار فاعله ينقسم إلى:

١- المباشرة، وهو فعل الضرر بدون واسطة، أو هو إتلاف الشيء بالذات.

---

(١) ابن ماجه.ح/ ٢٣٤١.

(٢) ابن ماجه، ح/ ٣٩٣٣.

(٣) ابن ماجه، ح/ ٢٤٠٠.

٢- التسبب، وهو أن يكون الشخص سببًا في حصول ضرر لغيره.

وباعتبار هيئته ينقسم إلىٰ:

ضرر مادي كالضرب، وضرر معنوي كالتعدي على الغير في حريته أو في شرفه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي.

شروط الضرر:

يشترط في الضرر عدة شروط، هي:

أولًا: أن يكون الضرر محققًا في الحال أو المستقبل، فلا تبنى الأحكام على ضرر موهوم أو نادر الحصول، فالعبرة في الضرر كثرة الحصول.

ثانيًا: أن يكون الضرر فاحشًا، وذلك بأن يكون مقدراه كبيرًا أو فاحشًا، والعبرة في تحديد الكبير واليسير إلى العرف والعادة.

ثالثًا: أن يكون الضرر بغير حق، مثل التعدي والتعسف والإهمال.

فالتعدي هو: الإضرار بالغير بغير حقّ.

والتعسف هو: مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعًا بحسب الأصل.

والإهمال هو: ترك الشيء بغير عناية والتقصير في النظر المأمور به.

رابعًا: أن يكون الضرر مخلًّا بمصلحة مشروعة، أما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فلا تعتبر الضرر الواقع عليها، كإتلاف خمر لمسلم، وإتلاف آلات اللهو المحرمة.

خامسًا: أن يكون الضرر مخلًّا بمصلحة مستحقة للمتضرر بأيّ وجه من وجوه الاستحقاق، فإذا كانت المصلحة غير مستحقة للمتضرر، لم تعتبر

الإخلال بها ضررًا: كمن بنى في أرض الغير بدون وجه حق، فإن البناء يزال ولا يضمن صاحب الأرض قيمة البناء المهدوم.

حكم القاعدة الكليّ:

حكم القاعدة الكليّ هو إزالة الضرر، وهو يتضمن حكمين:

الأول: وجوب دفع الضرر قبل وقوعه، وذلك بسد الذرائع وغلق الأبواب والمنافذ المؤدية إلى الضرر.

الثاني: وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه، وإزالة الضرر بعد وقوعه تكون بإحدي طرق ثلاثة:

أ- إزالة عين الضرر لو أمكن ذلك، سواء كان الضرر فعلًا أو قولًا أو منعًا (كالاحتكار).

ب- التعويض عن الضرر (الضمان)، وهو: التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير.

ج- إيقاع العقوبة على الفاعل، والعقوبات ثلاثة أنواع هي: القصاص والحدود والتعازير.

وهذه الأنواع الثلاثة من إزالة الضرر قد تكون منفردة في بعض الأضرار، وقد تكون مجتمعة في بعض الأضرار كما في الغصب، فإن الغاصب يرد العين المغصوبة إن بقيت ويضمن ما نقص منها، ويعزر على جناية الغصب.

تطبيقات القاعدة:

- إذا سلط شخص ميزاب بيته في الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال.
- إذا استقرض مبلغًا من النقود فبطل التعامل بها، فعلى المستقرض ردّ قيمة ما استقرض.

● إذا انتهت مدة عقد إجارة الأرض الزراعية قبل حصاد الزرع، تبقى الأرض في يد المستأجر بأجرة المثل حتى يتم الحصاد.

● من أحدث في ملكه مدبغة جلود يتأذى منها الجيران بسبب الروائح الكريهة؛ فإنه يكلف بدفع الضرر بالطرق الممكنة.

● إذا ماطل المدين في قضاء الدين، فللقاضي أن يأمر ببيع أمواله لإيفاء الدين.

القواعد تتعلق بقاعدة : الضرر يزال.

أولًا: القواعد التي تمثل فروعًا لهذه القاعدة:

القاعدة الأولى: (تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره).

معنىٰ القاعدة: إن على الإنسان مراعاة حقوق غيره، فلا يلحق به ضررًا، فمن كان مالكًا لدار له أن يتصرف فيها أي تصرف شرعي بشرط عدم إلحاق ضرر بجاره.

تطبيقات القاعدة:

● إذا بنى بيتًا وفتح فيه نوافده بدون إذن جاره، وكانت تلك النوافد تطل على نساء الجيران فيجب سدها ولو كان لصاحبها مصلحة في فتحها؛لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

● إذا حفر حفرة في أرضه من أجل البناء (أو غيره) لكنها تؤدي إلى انهدام بيت الجار، فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ذلك.

● حبس الأب إذا امتنع عن الإنفاق على ولده.

القاعدة الثانية (درء المفاسد أولى من جلب المصالح):

معنى القاعدة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد في فعل شيء أو الكف عنه فإنه يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح؛ لأن الشارع حرص على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات؛ لأن للمفاسد سريانًا كالوباء والحريق، فمن الحكمة القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من مصالح ومنافع، بدليل قوله ﷺ: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[1].

من تطبيقات هذه القاعدة:

قطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف من قطعها والخوف من إبقائها.

القاعدة الثالثة: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما).

معنى القاعدة: عند اختلاف رتب المفاسد ترتكب المفاسد المتعلقة بالتحسينيات دفعًا للمفاسد المتعلقة بالحاجيات والضروريات، وترتكب المفاسد المتعلقة بالحاجيات دفعًا لمفاسد الضروريات بناء على قاعدة: يختار أهون الضررين.

وعند اتحاد رتب المفاسد بأن تكون المفسدتان متعلقتين بالضروريات

---

(١) صحيح البخاري. ح/ ٧٢٨٨.

ترتكب مفسدة المال دفعًا لمفسدة أو العقل أو النفس أو الدين.

وترتكب المفسدة الخاصة دفعًا للمفسدة العامة، بناء على قاعدة: يتحمل الضرر الخاص دفعًا للضرر العام.

تطبيقات القاعدة:

- جواز الكذب في الحرب لدفع الهلاك عن النفس، مع ما فيه من مفسدة تتعلق بالتحسينات.
- يجوز إلقاء حمل السفينة دفعًا لمفسدة هلاك النفس.
- التحاق الشخص بالخدمة العسكرية حفظًا لكيان الأمة العام، مع ما فيه من ضرر خاص على الفرد وأسرته.

القاعدة الرابعة: (الضرر يُدفع بقدر الإمكان):

معنىٰ القاعدة: الضرر يُدفَع قبل وقوعه قدر الإمكان، فإذا لم يمكن دفع بالكلية فيدفع القدر الممكن حتى لا يتجاوز إلى الأكثر من ذلك.

من تطبيقات القاعدة:

الجهاد شرع لدفع شر الأعداء.

وجوب العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن وردع المجرمين.

من غصب مالًا فهلك لزم تضمين المال مثليًّا كان أو قيميًّا.

شرعت الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار.

يجوز الحجر على المدين المفلس دفعًا للضرر عن الدائنين.

منع سفر المدين بناء على طلب الغرماء.

ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة (الضرر يزال):

القاعدة الأولى: (الضرر لا يزال بمثله):

معنىٰ القاعدة: هذه تمثل قيدًا لقاعدة: الضرر يزال، فإذا كانت إزالة الضرر واجبة فلا يزال بضرر مثله أو أشدّ، فيزال الضرر بغير إضرار بالغير، أو بأخف منه.

تطبيقات القاعدة:

- لا يجوز لمن أُكرِه على قتل غيره أن يفعل ذلك بغير وجه حق.
- لا يجوز لمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر.
- لا يجوز لأصحاب حرفة في سوق منع صاحب حرفة جديد، بدعوى أن ذلك يؤدي إلى كساد عملهم.

القاعدة الثانية: الضرر لا يكون قديمًا:

هذه القاعدة تمثل ضابطًا للضرر الذي يزال، فتجب إزالة الضرر ولو كان قديمًا قد سكت الناس عنه.



المبحث الرابع: فقه قاعدة: المشقة تجلب التيسير

أصل المشقة في اللغة: انصداع الشيء أو انخرام فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا﴾[عبس: ٢٤-٢٦].

والمشقة في لغة الفقهاء هي: العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال.

وهناك ألفاظ ذات صلة بالمشقة وهي: الحرج، والضرورة، والحاجة.

فالحرج في الاصطلاح هو: ما فيه مشقة فوق المعتاد.

والضرورة في الاصطلاح هي: بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب.

والحاجة هي: ما تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة.

والتيسير هو الإفتاء بما هو أيسر على الناس، وهناك ألفاظ ذات صلة بالتيسير هي:

التخفيف، والترخيص، والتوسعة، والتعزيم.

فالتخفيف هو رفع مشقة الحكم الشرعي بنسخ أو تسهيل أو إزالة بعضه أو نحو ذلك.

والترخيص في الاصطلاح يطلق على معنيين، هما:

١- الحكم النازل باليسر بعد العسر لعذر من الأعذار.

٢- ما استبيح مع قيام المحرم كبيع السلم مع انعدام المبيع.

والتوسعة هي: السعة والرفاهية وهي من التيسير، بل هي أعلى منه.

والتعزيم هو: الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض، كوجوب

الصلوات في الأحوال العادية، وصوم رمضان.

معنىٰ القاعدة: الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.

تأصيل القاعدة:

هناك نصوص من القرآن والسنة والاجماع والمعقول تدل على هذه القاعدة.

الأدلة من القرآن:

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾[البقرة: ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾[النساء: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة:٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[المائدة: ٦].

الأدلة من السنّة النبوية: قال رسول الله ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»(١).

وقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «ما خُيِّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله»(٢).

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٣٩.

(٢) صحيح البخاري، ح/ ٦٧٨٦.

وقال أيضًا: «أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة»[١].

وقال أيضًا: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» [٢].

الدليل من الإجماع:

أجمع العلماء على أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والعنت، ونصوص الشريعة دالة على ذلك، ولو حصل التكليف الشاق لكان ذلك تناقضًا واختلافًا في الشريعة، وهي منزهة عن ذلك.

الدليل من المعقول:

العقل السليم مفطور على النفور مما فيه مشقة وحرج، كما أنه مفطور على عدم التناقض، فلو كان الشارع قاصدًا للمشقة لما كان مريدًا لليسر والتخفيف، وذلك باطل عقلًا.

أسباب وجود المشقة ثمانية:

أولاً: السفر: وهو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بقصد معلوم، ويشترط في السفر الذي تترتب عليه أحكام التيسير أربعة شروط، هي:

الشرط الأول: أن تكون مسافته معقولة شرعًا وعرفًا، وقد اختلف الفقهاء في حد تلك إلى ثلاثة أقوال:

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٩٠.

(٢) البخاري، ح/ ٨٨٦.

أ- مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول الحنفية.

ب- مسيرة ستة عشر فرسخًا (٨١ كم)، وهو قول جمهور الفقهاء.

ج- أن تكون معقولة عرفًا، وهو قول ابن حزم وابن تيمية، ويمكن اعتبار المسافة ستة عشر فرسخًا (٨١ كم)؛ لأنها معقولة شرعًا وعرفًا.

الشرط الثاني: أن يكون السفر سفر طاعة، فلا يرخص للعاصي في الأحكام الشرعية، وهو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

الشرط الثالث: أن يجاوز المسافر مكان إقامته، وما يتصل به من أبنية و مزارع؛ لأن الرسول ﷺ كان لا يبتدئ القصر في سفر إلا بعد خروجه من المدينة، وهذا هو قول الجمهور.

الشرط الرابع: قصد السفر، وذلك بأن يقصد المسافر في سفره موضعًا معينًا، اما الهائم الذي لا يقصد موضعًا معينًا فلا يترخص عند الجمهور.

ثانيًا: المرض: وهو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، ويشترط فيه: أن يكون شديدًا يؤدي إلى هلاك النفس، أو تلف بعض الأعضاء، أو فوات منافعها.

ثالثًا: الإكراه: وهو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد أو الإلزام و الإجبار، وله خمسة شروط، هي:

الشرط الأول: أن يكون المكرِه قادرًا على تنفيذ ما هدد به من قتل ونحوه، و المكرَه عاجزًا عن التخلص مما هدد به بهروب أو مقاومة أو استغاثة.

الشرط الثاني: أن يقع في غالب ظن المكرَه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه

تحقق ما هدد به.

الشرط الثالث: أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على المكرَه تحمله، كالقتل، والضرب الشديد والحبس المديد.

الشرط الرابع: أن يكون الإكراه بغير حق، أما إذا كان بحق فلا يعد إكراهًا معتبراً.

الشرط الخامس: أن يكون الإكراه عاجلًا بأن يهدد بتنفيذه في الحال.

رابعًا: النسيان: وهو زوال المعلومة عن فكر المكلف مع العجز عن تذكرها في الحال، وله أربعة شروط هي:

الشرط الأول: أن لا يكون النسيان بسبب تقصير المكلف في مباشرة أسباب التذكر مع قدرته عليه، كمن أكل في أثناء الصلاة ناسيًا فإن صلاته فاسدة ولا يعذر بالنسيان.

الشرط الثاني: أن لا يتعلق النسيان بحقوق العباد؛ لأن حقوق العباد لا تسقط بالنسيان.

الشرط الثالث: أن لا يسبق تصريح بتنفيذ الأمر، كمن قال: والله لا أدخل هذه الدار عامدًا أو ناسيًا، فدخلها ناسيًا، حنث في يمينه.

الشرط الرابع: أن يكون الحق غير قابل للتدارك، أما إذا كان الحق قابلًا للتدارك فلا يسقط ولا يخفف، كمن نسي الصلاة أو غيرها من الواجبات، فيجب عليه أن يأتي بها عند تذكرها.

خامسًا: الجهل: والمراد به: عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، ويشترط في الجهل الذي لاعتباره عذرًا أو سببًا للتخفيف والتيسير ثلاثة

شروط، هي:

الشرط الأول: أن يتعلق بموضوع اشتبهت فيه الأدلة كالجهل في موضع الاجتهاد، والجهل في موضع الشبهة، أما الجهل فيما علم من الدين بالضرورة فلا يعد عذرًا.

الشرط الثاني: أن لا يكون فيما يمكن الاحتراز عنه بسؤال أهل العلم عن حكمه، أما إذا تعذر ذلك كمن دخل في الإسلام قريبًا أو نشأ في أماكن بعيدة عن العلماء فإنه يعذر بجهله.

الشرط الثالث: أن لا يتعلق الجهل بحق العباد، فحق العباد لا يسقط بالجهل، بل يضمن.

سادسًا: العسر وعموم البلوى: والمقصود بالعسر هنا: هو أن يجد الإنسان مشقة في تجنب الشيء والاحتراز عنه، وأما عموم البلوى فهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه أو الابتعاد عنه، ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في زمان رسول الله ﷺ في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (١).

والضابط في عموم البلوىٰ تتحقق بأحد أمرين، هما:

أ- نزارة الشيء وقلته، فإذا أصبحت العدالة نادرة يقبل شهادة الأمثل فالأمثل.

ب- كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره مثل طين الشارع بسبب الأمطار وغيرها، فلا يمكن الاحتراز منه فيعفى عنه.

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ١٧٣.

سابعًا: النقص: وهو خلاف الزيادة والكمال، والنقص في المكلف يتعلق بثلاثة أمور، هي:

أ- العقل.

ب- والحرية.

ج- والجنس (الأنوثة).

والنقص الذي يعترض العقل خمسة أنواع، هي:

الجنون، والعته، والنوم، والإغماء، والسكر.

والنقص الذي يعترض الحرية هو الرقّ أو العبودية، وهو نقص يقتضي التيسير على العبد؛ لأن العبد يتزاحم عليه حقان هما حق الله وحق سيده، فإذا ما طولب بكلا الحقين على وجهها سقط في الحرج والمشق؛ لذا أسقطت عنه الشريعة بعض التكاليف.

والنقص الذي يتعلق بالجنس هو الأنوثة، فتعتبر الأنوثة من أسباب التيسير؛ لاختلاف المرأة عن الرجل في كثير من الأمور الجسمية والنفسية والمسؤوليات؛ ولذلك طالبها الإسلام بواجبات أقل من واجبات الرجل، فاسقط عنها الصلاة والصوم في أيام الحيض، وأسقط عنها الجمعة وغير ذلك.

ثامنًا: الخطأ: وهو ما ليس للإنسان فيه قصد، أو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، وهو سبب من أسباب التيسير، بدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: ٢٨٦].

ويشترط لاعتبار الخطأ سببًا من أسباب التيسير عدة شروط، منها:

الشرط الأول: أن يكون الخطأ متعلقًا بحق من حقوق الله تعالى؛ لأنها مبينة على المسامحة، أما حقوق العباد فلا تسقط بالخطأ؛ لأنها مبنية على المشاحة والمقاضاة .

الشرط الثاني: أن لا يكون فيما يمكن الاحتراز منه، كالطبيب الذي يمارس مداواة الناس وهو غير أهل لذلك، فإنه مؤاخذ بما ترتب على عمله من خطأ، أما الطبيب الحاذق في مهنته فلا يضمن إلا بالتعدي والتقصير.

أنواع المشقة:

قسم العلماء المشقة باعتبارها مختلفة إلى أقسام، منها:

التقسيم الأول: تنقسم المشقة باعتبار تحمل الإنسان لها إلى:

١- مشقة معتادة. ٢- ومشقة غير معتادة.

فالمشقة المعتادة، وهي المشقة الطبيعية التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق ضرر به، فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عن الناس، وهي من مستلزمات التكاليف الشرعية، فلا تنفك عنها العبادة غالبًا؛ لأن مصالح الدنيا والآخرة كلها منوطة بالتعب، قال ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وَإِنْ كَانَتْ مَشَقَّةَ تَعَبٍ فَمَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَنُوطَةٌ بِالتَّعَبِ، وَلَا رَاحَةَ لِمَنْ لَا تَعَبَ لَهُ، بَلْ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ تَكُونُ الرَّاحَةُ[1]، ومن أمثلتها: مشقة الوضوء والغسل في شدة البرد.

---

(١) الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م ج/ ٢ ص: ٨٦.

والمشقة غير المعتادة، وهي الزائدة عن المشقة المعتادة، والتي لا يتحملها الإنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها، وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة غالبًا.

وقد بيَّن الشاطبي الحكمة من عدم التكليف بالمشاق من وجهين:

الوجه الأول: خوف الانقطاع والبغض للعبادة وكراهة التكليف.

الوجه الثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع.

وقد جعل العز ابن عبد السلام هذا القسم علىٰ ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفس أو الأعضاء أو منافعها، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص.

النوع الثاني: مشقة خفيفة: كالوجع البسيط في الإصبع أو الصداع الخفيف، وهذه مشقة لا تأثير لها ولا التفات إليها.

النوع الثالث: مشقة متوسطة بين المرتبتين السابقتين، وضابطها: أنها إن اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض، فيجوز له الفطر، أما إذا اقتربت من المشقة الخفيفة فلا توجب التخفيف، كمن أصيب بحمى خفيفة .

التقسيم الثاني: تنقسم المشقة باعتبار علاقتها بمقاصد الشريعة إلى قسمين:

الأولىٰ: مشقة تتعلق بالضروريات.

الثانية: مشقة تتعلق بالحاجيات.

أنواع التيسير(الرخص):

تنقسم التيسيرات الشرعية إلىٰ عدة سبعة أنواع هي كما يلي:

١- رخصة إسقاط: كإسقاط الصلاة والصيام عن الحائض والنفساء.

٢- رخصة تنقيص: كقصر الصلاة الرباعية في السفر.

٣- رخصة إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله.

٤- رخصة تقديم: كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في السفر أو المطر.

٥- رخصة تأخير: كتأخير صلاة المغرب إلى العشاء في مزدلفة، وتأخير صيام رمضان إلى أيام أخر بسبب المرض أو السفر.

٦- رخصة اضطرار كأكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر للغصة.

٧- رخصة تغيير: كتغيير هيئة الصلاة للخوف.

فائدة: الرُّخَصُ أَقْسَامٌ:

مَا يَجِبُ فِعْلُهَا، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَالْفِطْرِ لِمَنْ خَافَ الْهَلَاكَ بِغَلَبَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا، وَإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ.

وَمَا يُنْدَبُ كَالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، وَالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ، وَالنَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ.

وَمَا يُبَاحُ، كَالسَّلَمِ.

وَمَا الْأَوْلَى تَرْكُهَا: كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، وَالْجَمْعِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ لَا يَتَضَرَّرُ، وَالتَّيَمُّمِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ.

وَمَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا، كَالْقَصْرِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ مَرَاحِلَ[1].

تطبيقات القاعدة (المشقة تجلب التيسير):

- يجوز للمسافر بيع مال رفيقه، وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية.
- يجوز فسخ الإجارة (الإجارة عقد لازم) بعذر السفر الطارئ.
- يجوز للطبيب النظر إلى موضع الألم في جسم المرأة المريضة.
- يجوز تأخير إقامة الحد على المريض غير حد الرجم إلى أن يبرأ.
- إذا جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة (لأن الشفعة على الفور وتأخيرها بدون عذر يبطلها).

القواعد التي تتعلق بقاعدة (المشقة تجلب التيسير).

أولًا: القواعد الفرعية التي تمثل فرعًا لهذه القاعدة.

الفرع الأول: (الضرورات تبيح المحظورات):

معنىٰ القاعدة: إن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور شرعًا، لكن ليس كل من يدعي أنه مضطر إلى ارتكاب المحظور؛ بل لا بد من توفر هذه الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة .

الشرط الثاني: أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور، بأن لا يكون

---

(١) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م. ج/ ١ ص:٨٢.

وسيلة أخرى لدفع الاضطرار.

الشرط الثالث: أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة.

الشرط الرابع: أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة.

الشرط الخامس: أن لا يخالف المضطر المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، من تحقيق العدل وحفظ حقوق الآخرين، والمحافظة على أصول الدين.

الشرط السادس: أن يتحقق وليّ الأمر في حالة الضرورة العامة من وجود ضرر على عامة الناس إذا لم يرتكب المحظور.

الشرط السابع: أن يكون زمن الإباحة مقيدًا بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة.

تطبيقات القاعدة:

- جواز تلفظ المسلم بكلمة الكفر إذا اضطر إليها بالإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان.
- إذا وجد حريق في بلد واحتيج إلى هدم بعض البيوت لإخماد الحريق جاز ذلك.
- جواز فرض ضرائب استثنائية لسد حاجة الدولة من النفقات.

مستثنيات القاعدة:

يستثنىٰ من قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات: القتل بغير حق، والاعتداء على عضو، والزنا، وضرب الوالدين؛ لأن هذه الأفعال لا تباح بحال من الأحوال.

الفرع الثاني: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة):

معنىٰ القاعدة: الحاجة الماسة سواء أكانت عامة أو خاصة تؤثر في تغيير الأحكام كالضرورة تبيح المحظور، وتجيز ترك الواجب، فحاجات الجماعة مما هي دون الضرورة توجب التسهيل والتيسير، سواء كانت الحاجة عامة تشمل جميع الأمة، أم كانت خاصة بفئة خاصة من الناس.

ويعتبر لاعتبار الحاجة سببًا للتيسير عدة شروط، منها:

الشرط الأول: أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة.

الشرط الثاني: أن لا يؤدي اعتبار الحاجة إلى بطلان ضرورة من الضروريات.

الشرط الثالث: أن لا يؤدي اعتبارها إلى مخالفة قصد الشارع.

تطبيقات القاعدة:

جواز التصوير (الفوتوغرافي) لحاجة الناس في سفرهم وإقامتهم لإثبات شخصيتهم ومراقبة سلوكهم.

جواز بعض العقود مع اشتمالها على محظور كالسلم والإجارة والوصية والجعالة والمضاربة؛ وذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملات.

جواز النظر إلى وجه المرأة للمعاملة والإشهاد والخطبة.

الفرع الثالث: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)

معنىٰ القاعدة: الشيء الواجب أداؤه هو الأصل ما دام ممكنًا، فلا يصار إلى البدل؛ لأن الأصل هو الواجب، أما إذا تعذر الأصل لسبب من الأسباب فإنه يصار إلى البدل، كما إذا هلكت العين المغصوبة في يد الغاصب فإنه يضمن مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية.

تطبيقات القاعدة:

الأصل في حل لحوم الحيوانات أن تذبح، أما إن تعذر الذبح فيصار إلى الذكاة الاضطرارية.

ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أوضوابط لقاعدة (المشقة تجلب التيسير):

القاعدة الأولىٰ: (الضرورة تقدر بقدرها).

معنىٰ القاعدة: كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك، فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، فلا يباح بالضرورة محظور أعظم منها، كما أن الاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

وعلى المسلم الاحتياط عند الأخذ بالرخص، والأولى الأخذ بالعزائم، كما ينبغي عليه مراجعة العلماء المختصين وسؤالهم فيما يطرأ له من ضرورات وحاجات.

تطبيقات القاعدة :

- المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق أو يدفع عن نفسه خطر هلاك النفس.
- لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى العورة إلا بقدر الحاجة.
- لا تتداوى المرأة عند طبيب إذا وجدت طبيبة تحسن الطب.
- للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة بقدر ما يدعوه إلى الزواج منها كالوجه والكفين.

القاعدة الثانية (ما جاز لعذر بطل بزواله):

معنى القاعدة: أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار، فإنه يزول جوازه بزوال العذر.

من تطبيقات القاعدة:

- من جاز له الفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفي منه طولب بالصيام، وكذلك من أفطر في رمضان بسبب السفر.
- من قُبلت إشارته في العقود للخرس، ثم زال الخرس طولب بالتلفظ في العقود.
- الوكيل تنتهي وكالته إذا علم بعزل الموكل له.
- إذا شب حريق في دار فأخرج صاحبها ما عنده من الودائع وسلمها إلى بعض الجيران، فهو معذور ولا يضمن إن تلفت، ولكن إذا تركها عندهم بعد انتهاء الحريق فهلكت، كان مقصرًا، فيضمن.

القاعدة الثالثة: (الميسور لا يسقط بالمعسور):

معنىٰ القاعدة: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لقدم القدرة على الوجه الأكمل، وإنما يمكن فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه، ولا يترك هذا بترك الكل الذي يشق فعله.

وقد ذكر ابن القيم أربع حالات للمكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز، فقال:

المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له أربعة أحوال:

إحداهما: قدرته بهما، فحكمه ظاهر كالصحيح القادر على الماء، والحر القادر على الرقبة الكاملة.

الثانية: عجزه عنهما كالمريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة، فحكمه أيضًا ظاهر.

الثالثة: قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به، كالصحيح العادم للماء، والعاجز عن الرقبة في الكفارة، فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه كالتيمم أو الصيام في الكفارة ونحو ذلك، فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه، كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة فإنه يصلى ولا يعيد.

الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله، فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام، وله صور:

إحداها: المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، وله مال يقدر أن يحج به عنه، فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به، وإن

عجز عن مباشرته هو بنفسه، وهذا قول الأكثرين، ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهما رويتان منصوصتان عن أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

الصورة الثانية: الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا في أصح أقوال العلماء.

الصورة الثالثة: المريض العاجز عن استعمال الماء، فهذا حكمه حكم العادم، وينتقل إلى بدله كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام.

وضابط هذا أن المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه[1].

تطبيقات القاعدة:

- إذا كان الإنسان مقطوع بعض الأطراف كاليد أو الرجل، فيجب عليه غسل الجزء الباقي من العضو الواجب غسله في الوضوء.
- إذا وجد المتوضئ ماء لا يكفيه لإزالة النجاسة والوضوء، غسل النجاسة وتيمم.
- إذا عجز المصلي عن الركوع والسجود، لكنه قادر على القيام، لزمه القيام.

مستثنيات هذه القاعدة:

خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِل: مِنْهَا: وَاجِدُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، لَا يَعْتِقُهَا، بَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَدَلِ بِلَا خِلَافٍ؛ (لأن الرقبة لا تتجزأ).

---

(١) بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،ج/ ٤ ص: ٢٩.

وَمِنْهَا: الْقَادِرُ عَلَى صَوْمِ بَعْضِ يَوْمٍ دُونَ كُلِّهِ، لَا يَلْزَمُهُ إمْسَاكُهُ؛ (لأن الصوم لا يتجزأ).

وَمِنْهَا: إذَا وَجَدَ الشَّفِيعُ بَعْضَ ثَمَنِ الشِّقْصِ، لَا يَأْخُذُ قِسْطَهُ مِنْ الشِّقْصِ.

وَمِنْهَا: إذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ يُشْتَرَى بِهِ رَقَبَةٌ، فَلَمْ يَفِ بِهَا، لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ.

وَمِنْهَا: إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، وَلَمْ يَتَيَسَّر لَهُ الرَّدُّ وَلَا الْإِشْهَادُ، لَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِالْفَسْخِ، فِي الْأَصَحِّ[1].

القاعدة الرابعة (الاضطرار لا يبطل حق الغير):

معنى القاعدة: الاضطرار يعد معذرة تسقط الإثم، وتعفي من عقوبة التجاوز على حق الغير، ولكن لا يعد عذرًا لإبطال حقوق الغير ولا ينافي الضمان؛ لأن أموال الناس مصونة مضمونة، فالضرر لا يزال بالضرر، والضرورة شُرِعت للحفاظ على حياة المضطر.

تطبيقات القاعدة:

- إذا أرضعت امرأة طفلًا بأجرة، فانتهت مدة الإجارة، والطفل لا يقبل ثدي غيرها، ولم يستغن عن الرضاعة، فإنها تجبر على إرضاعه مدة أخرى، لكن بأجرة المثل.
- لوأشرفت السفينة على الغرق، فألقى الملاح متاع أحد الركاب في البحر ليخفف حمولتها، ضمنه.

---

(١) الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.ج/١ ص: ١٦٠.

المبحث الخامس فقه قاعدة: العادة محكمة

معنىٰ القاعدة: العادة لغة مأخوذة من العَوْد، فيقال: عاد يعود عودًا وعادة، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي: يرجع إليها مرة بعد مرة.

والعادة في الاصطلاح: ما استمر عليه الناس على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد مرة، ومن الألفاظ المرادفة للعادة: العرف، وهو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

المعنى الإجمالي للقاعدة:

إن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقتضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.

وقد صاغ الفقهاء قاعدة أخرى في معنى هذه القاعدة وهي: استعمال الناس حجة يجب العمل به.

تأصيل قاعدة (العادة محكّمة):

تستند هذه القاعدة إلى نصوص من القرآن والسنة، والإجماع والمعقول.

أولًا: القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: ٢٣٣].

وقال تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾[الطلاق: ٧].

والآية تدل على أن الإنفاق لليس له تقدير شرعي، ولكنه مفوض إلى العرف والعادة.

وقال تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:٢٤١].

ثانيًا: السنة النبوية: عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف»(١).

فالمراد بالمعروف في الحديث: القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية، وهو يدل على اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لأن مقدار النفقة يرجع فيه إلى العادة.

ثالثًا: الإجماع: أجمع العلماء على اعتبار العرف في الاحكام الشرعية، ولا شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لا يصح أن يتركه الفقيه.

رابعًا: المعقول: مراعاة العرف يحقق مبدأ رفع الحرج عن الناس.

نشأة العادة وسلطانها على النفوس.

ترجع نشأة العادة في المجتمعات إلىٰ ثلاثة أسباب، هي:

الأول: الحاجة، وهي سبب لمعظم العادات؛ إذ يعرض للناس ظرف خاص يدعوهم إلى عمل خاص، فيتكرر العمل ويشيع بين الناس حتى يصبح

---

(١) البخاري، ح/ ٥٣٦٤.

عرفًا دارجًا.

الثاني: صدور أمر سلطاني للقيام بعمل من الأعمال:

الثالث: وراثي تناقله الخلف عن السلف كما في كثير من العادات التي كانت منتشرة في الجاهلية.

وللعادة سلطان على النفوس وتحكُّم فيها، فمتى رسخت اعتبرت من ضروريات الحياة؛ ولذلك يقول علماء الطبيعة: إن العادة طبيعة ثانية. ويقول ابن عابدين: إن في نزع الناس عن عاداتهم حرجًا عظيمًا.

أنواع العادة أو العرف:

قسم العلماء العادة أو العرف باعتبارات مختلفة إلى أقسام:

التقسيم الأول: تقسم العادة أو العرف – باعتبار الموضوع أو متعلقه إلى قسمين: قولى (لفطي) وعملي.

أ- **العرف القولي أو اللفطي**: وهو الدي يسميه الأصوليون بالحققيقة العرفية، ويسميه بعض الفقهاء بالعادة في اللفظ، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاط أو التركيب في معنى معين.

بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية.

ب- **العرف العملي**: وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية، أو ما جرى عليه عمل الناس وتعارفوه في معاملاتهم وتصرفاتهم.

التقسيم الثاني: يقسم العرف -باعتبار عمومه وخصوصه- إلى عام وخاص.

أ- **العرف العام**: وهو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد على اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم.

ب- **العرف الخاص**: وهو الذي يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى.

التقسيم الثالث: تقسم العادة باعتبار نص الشارع على اعتبارها أو عدم نصه إلى شرعية وجارية بين الخلق مما ليس فيه نص شرعي.

أ- فالعادات الشرعية هي التي كلف بها الشرع وأمر بها، وهذه العادات ثابتة لا تتغير.

ب- والعادات الجارية بين الخلق مما ليس فيه نص شرعي تتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: العادات الجارية الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، كشهوة الطعام والشراب، ولما كانت هذه العادات أسبابًا لمسببات حكم بها الشارع، واعتبرها، وبنى عليها الأحكام.

النوع الثاني: العادات الجارية المتبدلة، وهي ما كان للزمان والمكان والأحوال دخل في تبدلها وتغيرها، وينتظم تحتها عدة صور، منها:

الصورة الأولى: العادات التي تختلف باختلاف البقاع والبيئات.

الصورة الثانية: العادات التي تختلف باختلاف الأقوال والألفاظ المعبرة عن المقاصد والنيات، وكذلك المصطلحات المستخدمة بين أهل الحرف والمذاهب.

الصورة الثالثة: العادات التي تختلف باختلاف الأفعال في المعاملات كالعادة في البيع والشراء والقبض.

الصورة الرابعة: العادات التي تختلف بحسب أمور خارجة عن إرادة المكلف، كاختلاف الأقطار حرارة وبرودة وأثر ذلك في الإسراع والبطء في البلوغ.

الصورة الخامسة: ما يكون في أمور خارقة للعادة، كبعض الناس تصير له خوراق العادات عادة جارية.

مجالات عمل العادة:

تعمل العادة في عدة مجالات، منها:

المجال الأول: تفسير النصوص التي وردت مطلقة، ولم يأت الشرع ولا اللغة بتفسيرها، كما قال ابن تيمية: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف(١).

المجال الثاني: بناء الأحكام الشرعية عليها للقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي.

المجال الثالث: تجديد بناء الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو أصلًا مبني على العادات، فإذا تغيرت تلك العادات وجب تغيير الحكم.

شروط العادة:

قرر الفقهاء لاعتبار العمل بالعادة شروطًا عدة، هي:

١-أن لا تخالف العادة نصًّا من الكتاب والسنة أو أصل قطعي في الشريعة الإسلامية.

٢-أن تكون العادة مطردة أو غالبة، بأن يكون العمل بها مستمرًّا في جميع

(١) مجموع الفتاوى، ابن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.ج/ ٢٤ ص: ٤٠.

الحوادث أو في أغلبها، كما قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اطردت[١]، فإن اضطربت فلا.

٣- أن تكون العادة موجودة عند إنشاء التصرف؛ بأن تكون سابقة للتصرف أو مقارنة، كما لو وقف شخص قبل ألف سنة مزرعة على علماء الأزهر، وكان المتبادر من كلمة العلماء من لهم خبرة كافية بعلوم الدين والعربية وإن لم يحمل شهادة، ثم حدث عرف في هذا الزمان في هذا الزمان يطلق هذا اللفظ على حملة الشهادة العالية، فيفسر هذا اللفظ بالعرف الذي كان سائدًا وقت إنشاء الوقف.

٤- أن لا تعارض العادة شرطًا للعاقدين أو أحدهما بعدم العمل بها، كما قال العز ابن عبد السلام: كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح.

تطبيقات القاعدة:

- نص الفقهاء على أنه ينظر إلى العادة في الحيض، فلو زاد الدم على أكثر الحيض يرد إلى أيام عادتها.
- نص الفقهاء على أن العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف، فلو كان العمل بحيث لو رآه شخص يظن أنه خارج الصلاة أفسدها وإلا فلا.
- ثبوت المالية للشيء يكون بالعرف حيث يتحدد به ما يعد مالًا شرعًا وما لا يعد.

---

(١) (اطرد) تتَابع وتسلسل وعَلى هَذَا قَوْلهم: اطرد الْكَلَام، أَو الحَدِيث جرى مجْرى وَاحِدًا متسقًا وَالنّهر تتَابع جَرَيَان مَائه، وَالْقِيَاس دَار الحكم فِيهِ مَعَ الْوَصْف وجودًا وعدمًا. المعجم الوسيط،ج٢ ص: ٥٥٣.

● حقوق الارتفاق كالشرب والمسيل والجوار تستند إلى العرف السائد في البلد؛ ولذا تختلف من بلد إلى بلد.

● توجد كثير من البيوع التي بني جوازها على العرف، مثل: السلم والاستصناع.

● توجد كثير من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية تعتمد على العرف، مثل:

أ- الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة هل يحق له استردادها إذا عدل عن الخطبة؟

ب- الكفاءة في الزواج تُحمل على العرف.

ج- تقدير النفقة تعتبر العرف في تقديرها.

د- إفتاء الناس والقضاء بينهم يبنى على العرف والعادة، قال ابن القيم: "وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَأَمْكِنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ، وَكَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى الدِّينِ أَعْظَمَ مِنْ جِنَايَةِ مَنْ طَبَّبَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَى اخْتِلَافِ بِلَادِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ بِمَا فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الطِّبِّ عَلَى أَبْدَانِهِمْ، بَلْ هَذَا الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ وَهَذَا الْمُفْتِي الْجَاهِلُ أَضَرُّ مَا عَلَى أَدْيَانِ النَّاسِ وَأَبْدَانِهِمْ، وَاَللهُ الْمُسْتَعَانُ"[1].

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م. ج/ ٣ ص: ٦٦.

القواعد المتعلقة بقاعدة: العادة محكمة.

أولًا: القواعد التي تمثل فرعًا أو أثرًا لهذه القاعدة:

الفرع الأول: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: وقد صيغت هذه القاعدة بعبارات مختلفة كلها تؤدي إلى معنى واحد.

معنى القاعدة: إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم أو اعتادوا التعامل عليه لا يحتاج إلى ذكر صريح في العقد، وهو يقوم مقام الشرط في الالتزام والتقييد به إذا توافرت فيه شروط اعتبار العرف المار ذكرها.

تطبيقات القاعدة:

- إذا اشترى شخص سيارة فإن توابعها من عدة ومفاتيح وعجل احتياطي تدخل في المبيع ولو لم ينص على ذلك.
- أقر الفقهاء على انعقاد بيع التعاطي دون إيجاب وقبول.

الفرع الثاني: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم:

هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة، إلا أن القاعدة الأولى عامة، وهذه خاصة بعرف التجار وأرباب الصنائع والحرف.

تطبيقات القاعدة:

- إذا باع التاجر في السوق شيئًا بثمن ولم يصرح بحلول الثمن أو تأجيله انصرف إلى المتعارف بين التجار.
- لو باع بدراهم وأطلق يحمل على النقد الغالب في بلد المتعاقدين.

الفرع الثالث: الحقيقة تترك بدلالة العادة.

معنىٰ القاعدة: إذا كان للمصطلح معنيان أحدهما حقيقي والآخر عرفي، فإن المعنى الحقيقي يترك ويحمل على المعنى العرفي عند المتعاقدين، وضابط هذا: إذا كان المعنى الحقيقي غير مستعمل لتعذره، أو لكونه أصبح مهجورًا شرعًا أو عادة، فإنه يصار إلى معناه العرفي.

تطبيقات القاعدة:

- جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين ما لم توجد دلالة المنع.
- اليوم في عرف إجارة العمال يكون ثماني أو تسع ساعات، ومعنى اليوم الحقيقي أكثر من ذلك.
- صيغ الماضي في العقود: كبعت ووهبت وأجرت ينعقد بها العقد وإن كانت للماضي ؛لأنها جعلت إيجابًا للحال.
- لو حلف أن لا يأكل رأسًا فلا يحنث بأكل رأس عصفور؛ لأن العرف خص الرأس برأس الأنعام الذي يباع للأكل في الأسواق.

الفرع الرابع: الكتاب كالخطاب:

معنىٰ القاعدة: إن الكتاب كالخطاب تنعقد به العقود من بيع وإجارة وكفالة وغير ذلك، فللعاقدين أن يعقدا بينهما بطريق الكتابة كما جاز لهما العقد بطريق المشافهة.

ويشترط في الكتاب:

أ - أن يكون مستبينًا يمكن قراءة خطه.

ب- وأن يكون مرسومًا على الرسم المعتاد، بأن يكون معنونًا ومصدقًا ومكتوبًا حسب الأصول المعروفة في البلد.

تطبيقات القاعدة:

إذا كتب شخص كتابًا إلى شخص غائب، قائلًا فيه: إنني قد بعت منك سيارتي بألف دينار وقبل المرسل إليه، انعقد البيع، وصح العقد.

الفرع الخامس: الإشارة المعهود للأخرس كالبيان باللسان:

معنىٰ القاعدة: إشارة الأخرس المعهودة أو المعروفة قصده منها تقوم مقام الكلام أو النطق باللسان؛ لأنه لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ووقع في الحرج.

تطبيقات القاعدة ومستثنياتها:

- الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام النطق في جميع العقود، من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح ورجعة وظهار وغير ذلك.
- ذكر السيوطي مستثنيات من هذه القاعدة، هي:

أ- لا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة في الأصح.

ب- لا ينعقد يمنه في الإشارة إلا في اللعان.

ج- إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل صلاته في الأصح.

د- إذا حلف لا يكلم شخصًا فأشار إليه، لا يحنث.

هـ- إسلام الأخرس بالإشارة لا يصح في قول، حتى يصلي بعدها، والصحيح صحته.

الفرع السادس: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة:

معنىٰ القاعدة: إن دعوى المستحيل عادة لا تسمع كدعوى المستحيل حقيقة، لكن الممتنع حقيقة يستقل الحاكم بردّ الدعوى فيه، ويستبد به بدون حاجة إلى سؤال الخصم، ولكن دعوى الممتنع عادة تحتاج إلى سؤال الخصم عنها؛ فإن دافع بأنها لا تسمع لامتناعها عادة ردها القاضي حينئذ؛ لأن الخصم لو أقر بالمدعى به لدى الحاكم نفذ عليه الحكم.

تطبيقات القاعدة:

- لو ادعى شخص بأن الجنين الذي في بطن هذه المرأة باعه دارًا فادعاؤه غير صحيح؛ لأنه أسند إلى سبب مستحيل عادة.
- إذا ادعى شخص أن زيدًا المعروف أنه في السجن أنه غصب فرسه يوم الدعوى، فلا تُستمع دعواه؛ لامتناع ذلك عادة.

الفرع السابع: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان:

معنىٰ القاعدة: الأحكام المبنية على العرف في زمن قد تتبدل لتبدل العرف والعادة في هذا الزمان؛ لأن العادات تتغير بتغير الأزمان، أما الأحكام المبنية على نصوص شرعية أو أعراف ثابتة فلا تتغير بتغير الأزمنة وتبدلها.

الأحكام التي تخضع للتغيير:

الأحكام الشرعية نوعان: النوع الأول: ما كان مستنده صريح القرآن والسنة والإجماع، فهذا لا يخضع للتغيير؛ لأن التغيير نسخ للأحكام الشرعية، ولا نسخ بعد وفاة الرسول ﷺ.

النوع الثاني: ما كان مستنده الاجتهاد من مصلحة أو قياس أو عرف وعادة، فهذا هو محل التغيير، ويراعى فيه تحقيق العدل وجلب المصلحة ودفع المفسدة.

أسباب تغير الزمان:

الأسباب التي أدت الىٰ تغير الزمان هي: السبب الأول: فساد أخلاق الناس وضعف الوازع الديني، حيث ينشأ من ذلك تبدل بعض الأحكام، كما في وجوب التقاط ضالة الإبل في زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ضعف الوازع الديني لدى الناس.

السبب الثاني: تغير العادات والأعراف التي جعلها المجتهد مناطًا لحكم شرعي، كعادة قبض المهر قبل الدخول أو تقسيمه إلى مؤجل ومعجل.

السبب الثالث: حدوث معطيات علمية جديده تستدعي تغير الحكم الذي بني على معطيات علمية قديمة، مثل مدة الحمل، فقد اختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل على النحو التالي:

- قال الزهري: تحمل المرأة سبع أو ست سنين.
- قال عبادة بن العوام: مدة الحمل خمس سنين.
- قال الليث: مدة الحمل ثلاث سنين.
- ذهب الجمهور أن مدة الجمل سنتان.

● ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، وقد أثبت الطبّ الحديث المبني على التجربة والملاحظة أن أكثر مدة الحمل هو قول ابن حزم.

السبب الرابع: تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والأساليب الاقتصادية، مما يستدعي تغير بعض الأحكام تبعًا لذلك التطور، ومن ذلك أنه لَمَّا قَدِمَ عمر بن الخطاب الشَّامَ وَوَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ وَأَرْخَى الْحِجَابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ، وَسَلَكَ مَا يَسْلُكُهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَالَ لَهُ: لَا آمُرُك، وَلَا أَنْهَاك، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِك هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إلَى هَذَا فَيَكُونُ حَسَنًا أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالْأَحْوَالِ، فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمًا، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ[1].

السبب الخامس: حدوث ضرورات وحاجات عامة تتطلبها الحياة المعاصرة مما يستدعي تغيير بعض الأحكام القديمة، ومن ذلك جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإقامة.

تطبيقات القاعدة:

● لما ضعفت التربية الدينية اشترط الفقهاء تزكية الشهود سرًّا وعلنًا، وهذا

(١) الفروق للقرافي، الناشر: عالم الكتب، ج/ ٤ ص: ٢٠٣.

لم يكن في الزمن الأول.

● لما نذرت العدالة قال الفقهاء بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورًا فالأقل.

● حوز الفقهاء استحداث أحكام سياسية وأقضية لقمع أرباب الجرائم عند كثرة فساد الناس.

ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: العادة محكمة:

القاعدة الأولى: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت:

معنى القاعدة: إن العادة المعتبرة في الأحكام هي المطردة التي يستمر العمل بها في جميع الحوادث، أو الغالبة التي يعمل بها في غالب الأحوال، فالعادة المطردة لا تتخلف أبدًا، والغالبة قد تتخلف قليلًا، أما العادة المغلوبة فلا عبرة لها ولا تحكم.

تطبيقات القاعدة:

● إذا سرق الأجير من مال المستأجر- ولو مرة واحدة- فسخت الإجارة، ونحكم بأن السرقة عادة له.

● عادة الحيض يمكن أن تثبت بمرة واحدة.

القاعدة الثانية: العبرة للغالب الشائع لا النادر.

هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة ومكملة لها؛ لأن من شروط إعمال العادة أن تكون غالبة شائعة، أما إذا كانت نادرة فلا يعمل بها، وهذه القاعدة

أصل عام في الشريعة وهو اعتبار الغالب وتقديمه على النادر كما قال القرافي: اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الْغَالِبِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى النَّادِرِ، وَهُوَ شَأْنُ الشَّرِيعَةِ كَمَا يُقَدَّمُ الْغَالِبُ فِي طَهَارَةِ الْمِيَاهِ وَعُقُودِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْصِرُ فِي السَّفَرِ، وَيُفْطِرُ بِنَاءً عَلَى غَالِبِ الْحَالِ، وَهُوَ الْمَشَقَّةُ، وَيَمْنَعُ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ وَالْخُصُومِ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْهُمْ الْحَيْفُ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الشَّرِيعَةِ، لَا يُحْصَى كَثْرَةً[1].

تطبيقات القاعدة:

- إذا أكمل الشخص من عمره خمس عشرة سنة حكم ببلوغه؛ لأن الغالب أن الإنسان يبلغ عند وصوله هذا السن.
- يحكم بانتهاء مدة الحضانة للطفل الذكر ببلوغه سبع سنين، وللبنت تسع سنين؛لأن الغالب أن كلًّا منهما يستغني عن أمه في الأكل واللباس والطهارة في هذا السنّ.

مستثنيات قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا النادر.

قَدْ يُلْغِي الشَّرْعُ الْغَالِبَ رَحْمَةً بِالْعِبَادِ، ولهذا أمثلة كثيرة، نذكر منها عشرين مثالًا:

(**الْأَوَّلُ**): غَالِبُ الْوَلَدِ أَنْ يُوضَعَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا دَارَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زِنًى وَهُوَ الْغَالِبُ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَأَخَّرَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَهُوَ نَادِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُقُوعِ الزِّنَا فِي الْوُجُودِ أَلْغَى الشَّارِعُ الْغَالِبَ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ، وَهُوَ تَأَخُّرُ الْحَمْلِ رَحْمَةً بِالْعِبَادِ لِحُصُولِ السَّتْرِ عَلَيْهِمْ، وَصَوْنِ أَعْرَاضِهِمْ عَنْ الْهَتْكِ.

---

(١) الفروق للقرافي، ج/ ٤ ص: ١٠٤.

(**الثَّانِي**): إِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَهُوَ الْغَالِبُ أَوْ مِنْ وَطْءٍ بَعْدَهُ، وَهُوَ النَّادِرُ فَإِنَّ غَالِبَ الْأَجِنَّةِ لَا تُوضَعُ إِلَّا لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنَّمَا يُوضَعُ فِي السِّتَّةِ سِقْطًا فِي الْغَالِبِ أَلْغَى الشَّرْعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ، وَجَعَلَهُ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ لِحُصُولِ السَّتْرِ عَلَيْهِمْ وَصَوْنِ أَعْرَاضِهِمْ.

(**الثَّالِثُ**): نَدَبَ الشَّرْعُ النِّكَاحَ لِحُصُولِ الذُّرِّيَّةِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْأَوْلَادِ الْجَهْلُ بِاللهِ تَعَالَى وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمَعَاصِي، وَعَلَى رَأْيِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اللهَ تَعَالَى بِالْبُرْهَانِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يُنْهَى مِنْ الذُّرِّيَّةِ لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ فَأَلْغَى الشَّرْعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَاعْتَبَرَ حُكْمَ النَّادِرِ تَرْجِيحًا لِقَلِيلِ الْإِيمَانِ عَلَى كَثِيرِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي تَعْظِيمًا لِحَسَنَاتِ الْخَلْقِ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ رَحْمَةً بِهِمْ.

(**الرَّابِعُ**): طِينُ الْمَطَرِ الْوَاقِعُ فِي الطُّرَقَاتِ وَمَمَرِّ الدَّوَابِّ الْغَالِبُ عَلَيْهَا وُجُودُ النَّجَاسَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَإِنْ كُنَّا لَا نُشَاهِدُ عَيْنَهَا، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا مِنْهَا، وَمَعَ ذَلِكَ أَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ تَوْسِعَةً وَرَحْمَةً بِالْعِبَادِ فَيُصَلِّي بِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ.

(**الْخَامِسُ**): النِّعَالُ الْغَالِبُ عَلَيْهَا مُصَادَفَةُ النَّجَاسَاتِ، لَا سِيَّمَا نَعْلٌ مَشَى بِهَا سَنَةً، وَجَلَسَ بِهَا فِي مَوَاضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ سَنَةً، وَنَحْوَهَا فَالْغَالِبُ النَّجَاسَةُ وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا مِنْ النَّجَاسَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَلْغَى الشَّرْعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ فَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِالصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ قَلْعَ النِّعَالِ فِي الصَّلَاةِ بِدْعَةٌ. كُلُّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ وَتَوْسِعَةٌ عَلَى الْعِبَادِ.

(**السَّادِسُ**): الْغَالِبُ عَلَى ثِيَابِ الصِّبْيَانِ النَّجَاسَةُ لَا سِيَّمَا مَعَ طُولِ لُبْسِهِمْ لَهَا، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا، وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأُمَامَةَ يَحْمِلُهَا فِي

الصَّلَاةِ؛ إِلْغَاءً لِحُكْمِ الْغَالِبِ، وَإِثْبَاتًا لِحُكْمِ النَّادِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ.

(**السَّابِعُ**): ثِيَابُ الْكُفَّارِ الَّتِي يَنْسِجُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ مَعَ عَدَمِ تَحَرُّزِهِمْ مِنْ النَّجَاسَاتِ، فَالْغَالِبُ نَجَاسَةُ أَيْدِيهِمْ لِمَا يُبَاشِرُونَهُ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَمُبَاشَرَتِهِمْ الْخُمُورَ وَالْخَنَازِيرَ، وَلُحُومَ الْمَيْتَاتِ، وَجَمِيعُ أَوَانِيهِمْ نَجِسَةٌ بِمُلَابَسَةِ ذَلِكَ، وَيُبَاشِرُونَ النَّسْجَ وَالْعَمَلَ مَعَ بِلَّةِ أَيْدِيهِمْ، وَعَرَقِهَا حَالَةَ الْعَمَلِ، فَالْغَالِبُ نَجَاسَةُ هَذَا الْقُمَاشِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ عَنْ النَّجَاسَةِ، فَأَثْبَتَ الشَّارِعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ، وَجَوَّزَ لُبْسَهُ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ.

(**الثَّامِنُ**): مَا يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِن الْأَطْعِمَةِ فِي أَوَانِيهِمْ، وَبِأَيْدِيهِمْ الْغَالِبُ نَجَاسَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَالنَّادِرُ طَهَارَتُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ أَثْبَتَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ، وَجَوَّزَ أَكْلَهُ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ.

(**التَّاسِعُ**): مَا يَصْنَعُهُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ، وَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنْ النَّجَاسَاتِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ الْغَالِبُ نَجَاسَتُهَا، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا فَأَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ، وَجَوَّزَ أَكْلَهَا تَوْسِعَةً وَرَحْمَةً عَلَى الْعِبَادِ.

(**الْعَاشِرُ**): مَا يَنْسِجُهُ الْمُسْلِمُونَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُمْ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ، وَجَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ.

(**الْحَادِيَ عَشَرَ**): مَا يَصْبُغُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْغَالِبُ نَجَاسَتُهُ، وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا يَنْسِجُونَهُ لِكَثْرَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّاقِلَةِ لِلنَّجَاسَةِ، وَأَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ رِفْقًا بِالْعِبَادِ فَجَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهَا.

(**الثَّانِي عَشَرَ**): مَا يَصْنَعُهُ الْعَوَامُّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنْ النَّجَاسَاتِ الْغَالِبِ نَجَاسَتُهُ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ، فَجَوَّزَ الشَّرْعُ الصَّلَاةَ فِيهِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ تَوْسِعَةً وَلُطْفًا بِالْعِبَادِ

(**الثَّالِثَ عَشَرَ**): مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ، وَيُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُعْلَمُ لَابِسُهُ كَافِرٌ أَوْ مُسْلِمٌ يُحْتَاطُ، وَيُتَحَرَّزُ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ الْبِلَادِ الْعَوَامُّ وَالْفَسَقَةُ وَتُرَّاكُ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَمَنْ لَا يَتَحَرَّزُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فَالْغَالِبُ نَجَاسَةُ هَذَا الْمَلْبُوسِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ فَأَثْبَتَ الشَّارِعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ.

(**الرَّابِعَ عَشَرَ**): الْحُصْرُ وَالْبُسُطُ الَّتِي قَد اسْوَدَّتْ مِنْ طُولِ مَا قَدْ لُبِسَتْ يَمْشِي عَلَيْهَا الْحُفَاةُ وَالصِّبْيَانُ، وَمَنْ يُصَلِّي، وَمَنْ لَا يُصَلِّي الْغَالِبُ مُصَادَفَتُهَا لِلنَّجَاسَةِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا، وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ بَعْدَ أَنْ نَضَحَهُ بِمَاءٍ، وَالنَّضْحُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَنْشُرُهَا فَقَدَّمَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى حُكْمِ الْغَالِبِ.

(**الْخَامِسَ عَشَرَ**): الْحُفَاةُ الْغَالِبُ مُصَادَفَتُهُمْ النَّجَاسَةَ، وَلَوْ فِي الطُّرَقَاتِ وَمَوَاضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُمْ، وَمَعَ ذَلِكَ جَوَّزَ الشَّرْعُ صَلَاةَ الْحَافِي كَمَا جَوَّزَ لَهُ الصَّلَاةَ بِنَعْلِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْشِي حَافِيًا، وَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَعْلِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَفَاءَ أَخَفُّ مِنْ تَحَمُّلِ النَّجَاسَةِ مِنْ النِّعَالِ، فَقَدَّمَ الشَّارِعُ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ.

(**السَّادِسَ عَشَرَ**): دَعْوَى الصَّالِحِ الْوَلِيِّ التَّقِيِّ عَلَى الْفَاجِرِ الشَّقِيِّ الْغَاصِبِ الظَّالِمِ دِرْهَمًا الْغَالِبُ صِدْقُهُ، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدَّمَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ، وَجَعَلَ الشَّرْعُ الْقَوْلَ قَوْلُ الْفَاجِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ بِإِسْقَاطِ الدَّعَاوَى عَنْهُمْ، وَانْدِرَاجُ الصَّالِحِ مَعَ غَيْرِهِ سَدًّا لِبَابِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ بِالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ.

(**السَّابِعَ عَشَر**): عَقْدُ الْجِزْيَةِ لِتَوَقُّعِ إسْلَامِ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ نَادِرٌ، وَالْغَالِبُ اسْتِمْرَارُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَمَوْتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ فَأَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ،

وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ رَحْمَةً بِالْعِبَادِ فِي عَدَمِ تَعْجِيلِ الْقَتْلِ وَحَسْمِ مَادَّةِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ.

(**الثَّامِنَ عَشَرُ**): الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ مَأْمُورٌ بِهِ، مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ الرِّيَاءُ، وَعَدَمُ الْإِخْلَاصِ، وَالنَّادِرُ الْإِخْلَاصُ، وَمُقْتَضَى الْغَالِبِ النَّهْيُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلرِّيَاءِ، وَوَسِيلَةُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّارِعُ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ.

(**التَّاسِعَ عَشَرَ**): الْمُتَدَاعِيَانِ أَحَدُهُمَا كَاذِبٌ قَطْعًا، وَالْغَالِبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَعْلَمُ بِكَذِبِهِ، وَالنَّادِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شُبْهَةٌ، وَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ تَحْلِيفُهُ سَعْيًا فِي وُقُوعِ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَيَكُونُ حَرَامًا غَايَتُهُ أَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَخْذُ الْحَقِّ، وَإِلْجَاؤُهُ إلَيْهِ، وَذَلِكَ إمَّا مُبَاحٌ أَوْ وَاجِبٌ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْمُحَرَّمُ، وَالْوَاجِبُ قُدِّمَ الْمُحَرَّمُ، وَمَعَ ذَلِكَ أَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ عَلَى تَخْلِيصِ حُقُوقِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي اللِّعَانِ الْغَالِبِ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ يُعْلَمُ كَذِبُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ يُشْرَعُ اللِّعَانُ.

(**الْعِشْرُونَ**): غَالِبُ الْمَوْتِ فِي الشَّبَابِ؛ لأنه لَوْ كَانَ الشُّبَّانُ يَعِيشُونَ لَصَارُوا شُيُوخًا، فَتَكْثُرُ الشُّيُوخُ، فَلَمَّا كَانَ الشُّيُوخُ فِي الْوُجُودِ أَقَلَّ كَانَ مَوْتُ الْإِنْسَانِ شَابًّا أَكْثَرَ، وَحَيَاتُهُ لِلشَّيْخُوخَةِ نَادِرًا، وَمَعَ ذَلِكَ شَرَعَ صَاحِبُ الشَّرْعِ التَّعْمِيرَ فِي الْغَائِبِينَ إلَى سَبْعِينَ سَنَةً إلْغَاءً لِحُكْمِ الْغَالِبِ، وَإِثْبَاتًا لِحُكْمِ النَّادِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ فِي إبْقَاءِ مَصَالِحِهِمْ عَلَيْهِمْ[1].

(١) الفروق للقرافي، ج/ ٤ ص:١٠٤- ١٠٧.

المبحث السادس فقه قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله)

معنىٰ القاعدة: لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي؛ لأن العاقل لا يتكلم باللغو والعبث، فكان جديرًا أن يحمل كلامه على معنى قدر الإمكان، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولًا به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز.

وإذا كان الكلام مما يحتمل التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى؛ لأن التاسيس يفيد معنى جديدًا لم يتضمنه اللفظ السابق، وأما التأكيد فيفيد معنى اللفظ السابق أو المؤكد، ولأن حمله على التوكيد إلغاء له وإهمال، وكلام العقلاء يصان عن الإلغاء ما أمكن.

تأصيل القاعدة:

يستدل لهذه القاعدة بعمومات كثيرة في الكتاب والسنة، بالإضافة إلى المعقول، منها:

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ﴾[المؤمنون:٣].

قوله تعالى: ﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾[ق: ١٨].

فالمسلم العاقل مؤاخذ بكل ما يتلفظ به من كلام؛ لأن الكلام وعاء للمعاني التي يقصدها الإنسان.

قوله ﷺ لمعاذ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»(١).

(١) سنن الترمذي، ح/ ٢٦١٦.

الكلام و أقسامه، والمتكلم وشروطه.

أولاً: تقسيمات الكلام:

ينقسم الكلام باعتبارات مختلفة إلىٰ عدة أقسام:

- **التقسيم الأول**: ينقسم الكلام باعتبار المتكلم - إلى قسمين : كلام الله تعالى، وكلام الناس.
- **التقسيم الثاني**: قسم كثير من العلماء الكلام – باعتبار دلالته – إلى حقيقة ومجاز.

فالحقيقة في الاصصطلاح: كل لفظ مستعمل فيما وضع له، وتنقسم إلى:

حقيقة لغوية، كالأسد في الحيوان المفترس.

وحقيقة شرعية، كالصلاة والصيام في الاصطلاح الشرعي.

وحقيقة عرفية، كالدابة مثلًا، فهي في الوضع اللغوي كل ما يدب على وجه الأرض، وفي عرف الناس ينصرف إلى نوع معين.

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما.

ثانيًا: المتكلم وشروطه:

المتكلم هو الشخص الذي يصدر عنه الكلام؛ ولإعمال هذه القاعدة في كلام المكلفين لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

١- **البلوغ**: اتفق الفقهاء على أن البالغ يصان كلامه وينفذ، كما اتفقوا على عدم صيانة كلام غير البالغ الذي لم يميز ولم يدرك، واختلفوا في صيانة كلام غير البالغ إذا كان مميزًا ومدركًا لما يتلفظ به.

٢- **العقل**: واتفق الفقهاء على أن المجنون لا ينفذ كلامه؛ لأنه نوع من الهذيان الذي لا يترتب عليه أثر شرعي.

واختلف الفقهاء فيما إذا زال عقله بفعل من نفسه، كشرب الخمر. فذهب الجمهور إلى اعتبار كلامه الصادر منه، وذهب بعض السلف إلى عدم اعتبار كلامه.

٣- **الاختيار**: ذهب الجمهور إلى أن المُكْرَه لا ينفذ كلامه ولا يعمل به.

شروط إعمال الكلام:

ويشترط لإعمال الكلام أن تتوفر فيه عدة شروط، منها:

أ- أن لا يتعذر إعمال الكلام بأحد أنواع التعذر الثلاثة: العادي أو العقلي، أو الشرعي.

فالتعذر العادي (العرفي): كمن حلف أن لا يأكل من هذه القدر، فإنه محال في العادة، فيحمل على المجاز، وهو الأكل مما في القدر.

والتعذر العقلي: كأن يقول لمن هو أكبر منه سنًّا: أنت ابني.

والتعذر الشرعي: مثل النكاح، فإنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فمن قال لأجنبية: إن نكحتك بألف فلك شقة خاصة، فلا يمكن حمله على المعنى الحقيقي، بل يحمل على المعنى المجازي، وهو العقد.

أ- أن لا يكون اللفظ مشتركًا بين معنيين، بحيث لا يتضح مراد المتكلم منهما، ولا يوجد ما يرجع أحدهما على الآخر. هذا عند الحنفية والرازي، وذهب الشافعية إلى أنه لا يهمل، وإنما يعمل باللفظ المشترك مع القرينة، ومثل الحنفية لذلك: بما إذا قال شخص: أوصيت لمولاي بألف دينار، وكان

لذلك الشخص سيد معتق (بالكسر) وعبد معتق (بالفتح)، والمولى يطلق على السيد والعبد، ولا مرجح لأحدهما فيهمل هذا الكلام، ولا تصح الوصية للجهالة.

ب- أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أما ما لا داعي له فهذيان.

ج- أن يأتي بالكلام في موضعه، ويتوخى فيه إصابة فرصته.

د- أن يقتصر فيه على قدر حاجته وكفايته، فإذا أطلق الإنسان لسانه كان حشوًا بلا فائدة.

هـ- أن يتخير الألفاظ التي يتكلم بها ويبرهن على مقصوده، فالكلام الذي لا يُدرَى مقصوده لا يعمل به.

تطبيقات القاعدة:

● لو حلف شخص أن لا يأكل من هذه النخلة فأكل من تمرها، فإنه يحنث؛ لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها، فحمل حلفه على ما تولد منها، وهو التمر.

● إذا قال: وقفت هذا المال على ولدي، فإنه يحمل على ولده من الصلب، وإذا لم يكن له ولد صلب يحمل على ولد ولده.

● إذا قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل: بنتي لم يصح؛ لكثرة الفواطم، وفيه وجه للجواز عند الشافعية.

● لو أوصى ألف دينار ثم أوصى ألف دينار، فيحمل على أنه أوصى بألفين.

القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة:

أولا: القواعد التي تمثل فروعًا لهذه القاعدة.

الفرع الأول: الأصل في الكلام الحقيقة:

معنىٰ القاعدة: تحمل ألفاظ المتكلم من شارع أو عاقد أو حالف عند الإطلاق على معانيها الحقيقية؛ لأن المعنى الحقيقي أصل في اللفظ، ولا يحمل على المعاني المجازية إلا عند التعذر، بحيث توجد قرائن تدل على ذلك، فمهما أمكن حمل الكلام على معناه الحقيقي، فلا يحمل على معناه المجازي.

تطبيقات القاعدة:

- **لو قال شخص:** هذه الدار لزيد، يحمل كلامه على الإقرار بأنها ملك لزيد.
- لو قال: داري هذه لزيد بعد موتي، فيحمل على الوصية لا على الإقرار، بدلالة قرينة (بعد موتي).
- إذا وقف شخص دارًا على أولاده، فيدخل فيهم الذكور والإناث جميعا؛ لأن لفظ الولد يشملهم جميعًا.

الفرع الثاني: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

معنىٰ القاعدة: هذه القاعدة تنص على أن حمل الكلام على المعنى الحقيقي، وإذا تعذر تعين المصير إلى المجاز، والأسباب التي تؤدي إلى ترك المعنى الحقيقي هي:

١-أن يتعذر حمل الكلام على المعنى الحقيققي بأحد أنواع التعذر الثلاثة

(العادي والشرعي والعقلي).

٢- أن يكون المعنى الحقيقي مهجورًا عادة أو شرعًا.

٣- أن تدل دلالة الكلام أو السياق أو العرف أو قصد المتكلم على ترك المعنى الحقيقي، ومثل دلالة نفس الكلام أن يقول: كل مملوك لي فهو حر، لم يدخل المكاتب؛ لأن لفظ المملوك يطلق على المملوك الكامل. ومثل دلالة سياق الكلام أن يقول مسلم لحربي: انزل فنزل كان آمنًا، ومثل دلالة العرف النذر بالصلاة فإنه يحمل على الصلاة في العرف الشرعي لا الصلاة اللغوية، ومثل دلالة قصد المتكلم أن يقول المؤجر للمستأجر: أعرتك هذه الدار كل شهر بمائة دينار، فقصده الإيجار وليست الإعارة.

تطبيقات القاعدة:

- إذا وقف مزرعة على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد، حُمل عليهم صونًا للفظ عن الإهمال عملًا بالمجاز.
- إذا قال شخص لراعي غنمه: أعط فلانًا رأسًا من غنمي، أعطي شاة كاملة؛ لتعذر المعنى لعذر الحقيقي.

الفرع الثالث: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل:

معنىٰ القاعدة: إذا تعذر حمل الكلام على المعنى الحقيقي يحمل على المعنى المجازي، وإذا تعذر حمله على المعنى المجازي، فيهمل ويعدُّ لغوًا، ولا يعتد به، ويرجع سبب الإهمال إلى أحد أمرين:

الأول: تعذر حمله على أحد أنواع التعذر الثلاثة: (العادي، العقلي، الشرعي).

والثاني: أن يكون اللفظ مشتركًا بين معنيين فأكثر، ولم توجد قرينة على ترجيح أحد المعاني.

تطبيقات القاعدة:

- إذا أقر عمرو بأن زيدًا الذي هو أكبر منه سنًّا ولده، فإن لفظ: (ولد) لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي، فيلغو هذا الكلام.
- لو ادعى شخص صحيح اليدين على رجل آخر أنه قطع يده، وطالبه بالدية وقع الكلام لغوًا.

الفرع الرابع: التأسيس أولى من التأكيد.

معنىٰ القاعدة: اللغظ الذي احتمل إفادة معنى جديد، واحتمل إفادة الإعادة، فالأولى حمله على إفادة معنى جديد؛ لأن الإفادة خير من الإعادة.

تطبيقات القاعدة:

- إذا قال رجل لزوجته: أنت طالق طالق طالق، تطلق ثلاثًا لحمل الكلام على التأسيس لا التأكيد.
- لو أقر شخص لآخر بدين وأعطاه المبلغ، ثم أقر ثانية بدين له، فإن إقراره الثاني يحمل على التأسيس، فيكون مقرًّا بدينين.

الفرع الخامس: المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة.

معنىٰ القاعدة: إن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه دون تقييد بوصف معين

أو قيد معين، حتى يقوم دليل على التقييد.

ودليل التقييد يكون إما بالنصّ، والنص يكون ما يلي:

أ- الصفة، مثل: فرس عربي.

ب- الحال أو الهيئة مثل: إن دخلت راكبًا.

ج- الإضافة، مثل: اشتر لى فرسَ زيدٍ.

د- المفعول، مثل: بع لي من فلان.

هـ- النهي، مثل: لا تبعه من سوق كذا.

و- الشرط، مثل الطلاق المعلق على شرط.

ز- الاستثناء، مثل: لك عليّ مائة دينار إلا عشرة.

وقد يكون دليل القيد دلالة الحال: مثل قول من قدم بلدة لغيره: استأجر لي شقة، فاستأجر له بعد سنة، فإنه لا ينفذ فعل المأمور على الآمر؛ لأن استئجار الشقة مقيد بسد حاجته في الحال.

وقد يكون القييد بدلالة الحال، فمن وكل غيره ببيع سيارة له، تقيّد البيع بثمن المثل وبالنقد.

تطبيقات القاعدة:

- لو أقر شخص لزيد بأن له في ذمته دينًا ولم يبينه ولم يقيده، فيصح إقراره، ويطلب منه بيان مقداره؛ لأن الجهالة في ذلك لا تضر، ولو كانت فاحشة.
- إذا وكل شخص آخرَ بشراء فرس، فاشتراها حمراء، فقال الموكل: إنما أردتها بيضاء يلزم البيع بما اشتراها الوكيل؛ لأن كلام الموكل كان مطلقًا، فيجري على إطلاقه.

الفرع السادس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

معنىٰ القاعدة: اللفظ العام يحمل على عمومه، ولو نزل في شخص بعينه؛ لأن استخدام الشارع الصيغة العامة في سبب خاص يدل دلالة واضحة على أن العبرة بعموم اللفظ، فيتناول كل من باشر ذلك العمل الوارد في سبب النزول.

والضابط في ذلك: أن تكون الصيغة عامة، أما إذا كانت الصيغة خاصة، ونزلت في معين فإنها تقصر عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿١٧﴾ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ [الليل:١٧-٢١]، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فتقصر عليه، ولا يدخل فيها كل من عمل عمل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأن الآية وردت بصيغة الخصوص لا العموم؛ إذ الألف واللام في الأتقى لا تفيد العموم؛ لأنها غير موصولة بأفعل التفضيل إجماعًا، والأتقى ليس جمعًا، بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوصًا مع ما تفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة.

الفرع السابع: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله:

معنىٰ القاعدة: الأشياء التي لا يمكن تجزئتها إذا ذُكر بعضُها، فكأنّ الكلي قد ذُكِرَ، وإذا جرى تصرف على بعضها، فإن التصرف يشمل الكلّ.

والأشياء التي لا تقبل التجزئة يمكن قسمتها إلىٰ قسمين، هما:

الأول: ما لا يقبل التجزئة لتعذره عقلًا، كالشفعة والقصاص والطلاق والكفالة.

والثاني: ما لا يقبل التجزئة لإمكانية إلحاق الضرر بالغير، كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة:

تطبيقات القاعدة:

- إذا قال رجل لزوجته: نصفك طالق أو ربعك طالق؛ تطلق كلها، وكذلك إذا قال لها: طلقتك نصف تطليقة؛ فتعتبر تطليقة كاملة.
- لو نذر أن يصلي الله تعالى ركعة لزمه أن يصلي ركعتين؛ لأن أقل الصلاة ركعتان، فذكر إحداهما كذكر كليهما.
- لو طَهُرت المرأةُ آخر وقت الظهر وقد بقي منه مقدار ما يمكن فعلها من الاغتسال والتحريمة للصلاة، لزمها الظهر كاملًا؛ لأن الواجب لا يتبعض.

الفرع الثامن: السؤال معاد في الجواب:

معنىٰ القاعدة: الجواب إذا ورد بصيغة مجملة من أدوات الجواب، مثل: نعم، بلى، أجل، يشتمل على مضمون؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها، فيكون المجيب بأداة من هذه الأدوات مقرًّا بمضمون السؤال؛ لأن تلك الأداة تنوب عن السؤال.

تطبيقات القاعدة:

- لو سئل شخص هل أخذت من زيد ألف دينار؟ فقال المسئول: نعم، يكون قوله إقرارًا بأخذ ألف دينار من زيد.
- لو باع شخص فضولي دار شخص آخر، فلما علم صاحب الدار بالبيع قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت إذنًا، وصح البيع.
- لو قالت امرأة لزوجها: أنا طالق؟ فقال الزوج: نعم، فتعتبر طالقة؛ لأن الكلام تضمن الطلاق.

ثانيًا: القواعد التي تعد قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله:

القاعدة الأولى: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر:

تطبيقات القاعدة:

● لو قال: بعتك هذه السيارة البيضاء بخمسة آلاف دينار وهي سوداء، فقبل المشترى، انعقد العقد لازمًا للمشتري، ولا خيار له في فسخه باختلاف الوصف؛ لأن وصفه لها بالبيضاء يلغو بحضور السيارة والإشارة إليها، هذا بخلاف ما إذا كانت السيارة غائبة؛ فللمشتري الخيار باختلاف الوصف؛ لأن الغائب لا يُعرف ولا يَتَعين إلا بالتوصيف، فإن وجدت العين على ما وصفت به فقد تم العقد، وإلا فلا.

القاعدة الثانية: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وبين ما لا يتعلق به الحكم، فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر:

معنىٰ القاعدة: من تكلم بكلام جمع فيه بين ما يكون محلًّا لحكم من الأحكام وما لا يكون، فالحكم يتعلق بما هو محل للحكم، ويهمل الكلام الذي لا يكون محلًّا للحكم.

تطبيقات القاعدة:

● أوصى مالًا لحيٍّ وميّتٍ، فالمال للحيّ، وليس للميت شيء، سواء علم بموته أو لم يعلم.

● إذا قال رجل لزوجته ودابته: إحداكن طالق تطلق الزوجة؛ لأن الدابة لا تقبل حكم الطلاق، فينصرف إلى الزوجة تصحيحًا لكلام المكلف.

● إذا قال: عَلَيَّ لزيد وهذا الجدار ألفُ دينار، لزمه الألف لزيد، ولا شيء للجدار.



الفَصْلُ الثَّالِثُ

فقه القواعد الكلية الصغرى

يشمل هذا الفصل المباحث التالية:

- **المبحث الأول: فقه قاعدة كلية عامة: التابع تابع.**
- **المبحث الثاني: فقه قواعد كلية خاصة بالضمان.**
- **المبحث الثالث: فقه قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام.**
- **المبحث الرابع: فقه قواعد كلية خاصة بالقضاء وطرق الإثبات.**
- **المبحث الخامس: فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية.**
- **المبحث السادس: فقه قواعد كلية خاصة بالاجتهاد الفقهي.**



الفصل الثالث

فقه القواعد الكلية الصغرى

تمهيد:

المراد بالقواعد الكلية الصغرى هي التي يرجع إليها مسائل كثيرة من أبواب الفقه الإسلامي، لكنها أقل من القواعد الكلية الكبرى من حيث عدد المسائل وأبواب الفقه.

هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه القواعد يندرج تحتها قواعد فرعية، وبعضها لا يندرج تحته أيّة قاعدة من القواعد الفرعية، وبالرغم من قلة عدد المسائل التي يرجع إليها وعدد القواعد التي تتفرع عنها إلا أنها تعد من معالم الفقه الإسلامي وأبراجه العالية التي لا يستغني عنها طالب العلم الشرعي والقانوني؛ إذ يستطيع الطالب بدراستها أن يطلّ على مساحات واسعة، وأطراف مترامية من الفقه الإسلامي نظريًّا وعمليًّا، ويري امتداداته التطبيقية في جميع نواحي الحياة الدنيوية والأخروية.

المبحث الأول : فقه قاعدة كلية عامة: التابع تابع

تدخل قاعدة التابع تابع في أبواب كثيرة من الفقه، فتدخل في العبادات من صلاة وزكاة، وتدخل في المعاملات من بيع وإجارة ورهن وإحياء موات وإقرار، وتدخل في القضاء والشهادات والجهاد، وتدخل في النيات والمقاصد.

ويطلق التابع في اصطلاح الفقهاء علىٰ عدة أمور، منها:

١- ما اتصل بغيره اتصالًا حقيقيًّا لغة أو شرعًا، بحيث يكون جزء منه كالعضو من الحيوان، والحجارة المخلوقة في الأرض.

٢- ما اتصل بغيره اتصالًا قابلًا للانفصال عنه، مثل الجنين والثمار.

٣- ما اتصل بغيره اتصالًا ضروريًّا، كالمفتاح من القفل.

٤- ما اتصل بغيره اتصالًا عرضيًّا كالنقل والتفريغ للأشياء المباعة.

المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن التابع للشيء في الوجود حقيقة أو حكمًا تابع له في الحكم، فيسري عليه ما يسري على متبوعه، ولا ينفرد بالحكم، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعًا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.

تأصيل القاعدة:

تستند هذه القاعدة إلى السنّة والإجماع والمعقول.

فعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»[1].

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٢٦١٧.

عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (١).

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة.

أسباب تبعية الشيء إلى غيره:

وترجع أسباب تبعية الشيء إلىٰ غيره إلىٰ عدة أمور، وهي:

أ- النص الشرعي كما في حديث بيع النخل المؤبر.

ب- اللغة، فما اقتضاه اللغظ يتبع متبوعه، كالأرض يتبعها البناء والأشجار.

ج- العرف، كلجام الدابة وخطام البعير.

د- الشرط العقدي، كما ورد في الحديث: إلا أن يشترطه المبتاع، فما اشترطه أحد العاقدين بأن يكون تابعًا له يكون كذلك.

تطبيقات القاعدة:

● الربح في عروض التجارة ونتاج السائمة يتبعان أصلهما في الحول، فيضمان إلى حول أصلهما؛ لأنهما تبع لهما من جنسهما، فأشبه النماء المتصل.

● إذا ضرب شخص بطن حامل فماتت، ثم ألقت جنينًا ميتًا، فعلى الضارب دية الأم، ولا غرة في الجنين؛ وذلك لأن غرته داخلة في دية الأم؛ لكونه تبعًا لها.

● زوائد المغصوب، كالصوف واللبن تعود إلى المغصوب منه؛ لأن المغصوب ملكه، والزوائد تابعة للمغصوب في الوجود.

● إذا باع أرضًا ولها حقوق ارتفاق: من حق شرب ومسيل وطريق، فإنها تدخل في الأرض تبعًا، ولا تفرد بالحكم.

---

(١) سنن الترمذي، ح/ ١٤٧٦.

مستثنيات القاعدة:

لو أسقط المرتهن حقه في حبس الرهن جاز ولا يسقط حقه في الدين.

لو أبرأ الدائن الكفيل صح الإبراء، ولا يسقط الدين عن الأصيل.

القواعد التي تمثل فروعا لقاعدة: التابع تابع

أولًا: يتفرع عن قاعدة: التابع تابع عدة قواعد، منها:

الفرع الأول: قاعدة (التابع لا يفرد بالحكم):

فلا يجوز بيع الجنين في بطن أمه دونها.

ولا يجوز بيع حق الشرب والمسيل دون الأرض

ولا يجوز بيع عضو من أعضاء الشاة، وهي حية دون أصلها.

(وهناك قيود علىٰ هذه القاعدة الفرعية: التابع لا يفرد بالحكم، يراجع في الكتب المطولة مثل أصل كتابنا هذا للأستاذ محمد عثمان شبير، والمدخل الفقهي العام لمصطفىٰ الزرقاء، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء).

الفرع الثاني: قاعدة (من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته).

فمن ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه عقلًا أو عرفًا ولو لم يشترط في العقد، فمن ملك دارًا ملك الطريق الموصلة إليها؛ لأن الطريق ضروري للدار لا ينتفع بها بدونه.

ومن ملك أرضًا ملك ما فوقها من فضاء وما تحتها من أرض، وله أن يبني الطوابق المتعددة في حدود التنظيم العام في البلد، وله أن يحفر في الأعماق إلى ما يشاء (في حدود تنظيم البلد).

الفرع الثالث: قاعدة (التابع يسقط بسقوط المتبوع):

وقريب من هذه القاعدة: يسقط الفرع إذا سقط الأصل.

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المبني على الفاسد فاسد.

ومعنى القاعدة: أن الذي يكون وجوده مرتبطًا بوجود غيره يتبعه في الوجود والعدم، فإذا سقط الأصل سقط الفرع.

تطبيقات القاعدة:

- إذا أبرأ الدائن المدين برئ كفيله (إذا برئ الأصيل برئ الكفيل).
- إذا مات الفارس في الجهاد سقط سهم فرسه، لا العكس.
- إذا خرج الموكل عن أهلية التوكيل بالموت أو الجنون انعزل الوكيل؛ لأنه فرع عن الموكل.
- إذا هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن عن المشتري؛ لأن الثمن فرع عن المبيع، وقد هلك.

مستثنيات القاعدة:

- إذا مات المجاهد الذي له حق في بيت المال فإن حقه لا يسقط، بل يعطى لأولاده ترغيبًا للناس في الجهاد، وكذلك العالِم يعطى نصيبه من بيت المال لأولاده إذا مات.
- المحرم الذي لا شعر على رأسه يجب عليه إمرار الموسي على رأسه، مع أن الأصل سقط وهو شعر الرأس.
- إذا بطل أمان رجال (كفار) لم يبطل أمان نسائهم وأطفالهم في الأصح.

ثانيًا: القواعد التي تعد قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: التابع تابع.

١- (**التابع لا يتقدم علىٰ المتبوع**): لا يصح تقدم المأموم على الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع، فاركعوا وإذا رفع، فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا»[(١)].

٢- (**يُغتَفر في التوابع ما لا يُغتَفر في غيرها**): قد يتساهل في استيفاء بعض الشروط الشرعية فيما يعد تابعًا لغيره أو فيما ثبت ضمنًا، في حين لا يتساهل في استيفاء تلك الشروط في المتبوع أو المحل الأصلي؛ لأن التابع يثبت ضرورة لثبوت متبوعه، فيشدد في المتبوع ويتساهل في التابع.

تطبيقات القاعدة:

- لا يجوز إطلاق النار على المسلمين ابتداء، ولكن إذا تترس بهم الكفار فيجوز إطلاق النار على الكفار والمسلمين.
- لا يجوز للمشتري أن يوكل البائع بقبض الثمن؛ لأن التسليم والتسلم لا يتمَّان من جانب واحد، ولكن لو أعطى المشتري البائع كيسًا ليكيل له ويضع فيه الطعام الذي اشتراه جاز، وكان قبضًا من المشتري.

ثالثًا: القواعد التي تعد استثناء من قاعدة: التابع تابع:

توجد عدة قواعد تندرج تحت هذا النوع من الاستثناء، لكن نقتصر على بيان واحدة منها:

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٦٨٨.

(قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل):

معنىٰ القاعدة: قد يحكم بثبوت شيء تابع لغيره مع عدم ثبوت المتبوع؛ وذلك لقيام الحجة على لزوم تحقق هذا الحكم.

تطبيقات القاعدة:

- إذا أقر رجل لشخص مجهول النسب أنه أخوه، ولكن الأب أنكر ذلك، ولم يستطع المدعي إثبات ذلك لم تثبت بنوته للأب، ولكن يؤخذ المقر بإقراره أنه اخوه، فيقاسمه ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.
- إذا ادعت امرأة على رجل بالنفقة لولدها، فأنكر الرجل الزوجية بينهما، وعجزت المرأة عن إثبات دعواها، فإن دعواها بالنفقة لا تسمع، ولكن لو ادعى الولد بعد ذلك كونه ابن ذلك الرجل، وأثبت ذلك بموافقة الرجل إياه، فإنه يثبت نسبه منه، مع عدم ثبوت النكاح الذي هو الأصل.



المبحث الثاني : فقه قواعد كلية خاصة بالضمان

الضمان في اصطلاح الفقهاء يطلق علىٰ أحد معنيين، هما:

الأول: الكفالة: وهي ضَمُّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.

الثاني: الغرم، وهو: ما يتحمله الغارم عند تلف شيء برد مثله إذا كان مثليًّا أو بقيمته إذا كان قيميًّا، وهذا المعنى الأخير هو الذي يهمنا في هذا المبحث لا المعنى الأول، وقواعد الضمان في هذا المبحث أربعة قواعد، هي:

القاعدة الأولى: الخراج بالضمان:

هذه القاعدة تعبر عن أهم المبادئ في المعاملات المالية، وهو مبدأ العدل.

الخراج هو: كل منفعة منفصلة حصلت من عين مملوكة.

معنىٰ القاعدة: إن منفعة الشيء أو غَلَّتَهُ (ريعه ومحصوله) يستحقها من يكون هلاك ذلك الشيء على حسابه وضمانه، ومن يضمن شيئًا لو تلف عنده فإنه ينتفع به في مقابلة الضمان.

تأصيل القاعدة:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»[1].

وقد روت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سبب ورود هذا الحديث، فقالت: إِنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

(١) سنن الترمذي، ح/ ١٢٨٥، وابو داود، ح/ ٣٥٠٨، والنسائي، ح/ ٤٤٩٠.

ﷺ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(١).

ومن المعقول: القياس على الأصل "من ملك شيئًا ملك منافعه"، بجامع ضمان الهلاك في كلٍّ، فالعين المملوكة إذا هلكت تهلك على مالكها، والعين المشتراة قبل الردِّ إذا هلكت تهلك على المشتري إذا كانت في يده فله منفعتها.

وموضوع القاعدة هو الخراج أو غلة العين المملوكة أو الزيادة الحاصلة في العين، وقد قسم الفقهاء هذه الزيادة إلى أربعة أقسام، وهي:

الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة ونماء الشجر.

الثاني: زيادة متصلة بالأصل، ولكنها غير متولدة منه، وإنما تحصل بفعل الإنسان: كالبناء في الأرض وزراعة الأشجار.

الثالث: زيادة منفصلة متولدة من الأصل، كثمار الأشجار وأولاد الماشية وغير ذلك.

الرابع: زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، وإنما تحصل من المنفعة: كأجرة السيارة وأجرة الدار وغير ذلك.

شروط القاعدة:

الشرط الأول: أن تكون الغلة منفصلة عن الأصل، سواء كانت متولدة عنه، أو غير متولدة.

الشرط الثاني: أن تكون الغلة حاصلة عن عين مملوكة ملكًا شرعيًّا: كالملك عن طريق البيع ولو في مدة خيار العيب.

(١) سنن ابي داود، ح/ ٣٥١٠.

الشرط الثالث: أن تكون الغلة حاصلة بعد وقوع سبب الملك: كعقد البيع، أما إذا كانت قبل ذلك فلا يستحقها من وقعت تحت يده، مثل لبن المصراة.

أسباب الضمان:

السبب الأول: الإتلاف لمال الغير بالمباشرة أو التسبب.

السبب الثاني: وضع اليد (القدرة على التصرف في العين).

وقسم الفقهاء الأيدي باعتبار الضمان وعدمه إلى: يد ضمان ويد أمانة.

فيد الأمانة هي التي قبضت العين لا لقصد التملك، بل نيابة عن المالك، فكان قبضها لمنفعة المقبوض منه: كالوديعة، وعامل المضاربة، والوصيّ على مال اليتيم، فيد الأمانة لا تضمن إذا كان بدون تعد أو تفريط.

ويد الضمان هي: اليد التي قبضت العين لمنفعة القابض نفسه، سواء كان بإذن المالك (اليد المؤتمنة) أو بغير إذن المالك (اليد العادية)، فصاحب يد الضمان يضمن بمجرد القبض، ولو كان التلف بآفة سماوية، أو قوة قاهرة.

السبب الثالث: **العقد**: العقد مصدر للضمان إذا نصّ فيه صراحة على شرط من الشروط أو كان الشرط مفهومًا ضمنًا حسب العرف والعادة، ثم أخلّ العاقد بما تقتضيه طبيعة العقد أو يتطلبه الشرط، فلم يقم بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه.

تطبيقات القاعدة:

- لو رد المشتري على البائع سيارة أجرة بخيار العيب بعد أن استعملها مدة أسبوع لا يلزم المشتري أجرة تلك المدة؛ لأنه لو تلف حال وجوده عنده

كان عليه ضمان مثله أو قيمته.

● لو كان المبيع ثمرة فأثمرت عند المشتري ثم ردت على البائع بعيب كان الثمرة للمشتري؛ لأنه هو المتحمل تبعة الهلاك فيما لو هلكت.

القاعدة الثانية: «الغُرم بالغُنم»:

بالرغم من أن هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة: (الخراج بالضمان) إلا أنها بمعناها، أي: المستفيد منفعة شيء هو أولى من غيره بتحمل خسارة ذلك الشيء؛ عملًا بمبدأ العدل في المعاملات الذي قررته الشريعة الإسلامية.

الغرم لغة: من غرم في تجارته إذا خسر، ويقال: أغرم غرمًا ومغرمًا وغرامة، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: غرّمته وأغرمته، جعلته غارمًا.

وفي الاصطلاح: ما يتحمله الغريم في ماله تعويضًا عن ضرر بغير جناية ولا خيانة.

والغنم في اللغة: من غنمت الشيء أغنمه غنمًا، أي: أصبته غنيمة ومغنمًا، وأصله في اللغة يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل.

معنىٰ القاعدة: كما أن المالك يختص بالغنم ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمل الغرم ولا يتحمل معه أحد، سواء أكان المالك فردًا أم جماعة.

تطبيقات القاعدة:

● لما كان المرتهن هو المستفيد بالعين المرهونة بتأمين الدين وتوثيقه، كان على المرتهن أجرة حراسة العين المرهونة.

● لما كان المشتري هو المنتفع بتوثيق نقل ملكية العقار؛ كان عليه أجرة تحرير سند البيع، ودفع رسوم التسجيل في دائرة الأراضي.

● لما كانت الأرباح توزع على الشركاء بحصة رؤوس أموالهم وقدر حصصهم، كان عليهم نفقة تعمير الملك وصيانته (على قدر حصصهم أيضًا).

القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر:

معنى القاعدة: إذا اجتمع على إتلاف الشيء شخصان أحدهما أتلفه بفعله المباشر، والثاني أتلفه بسبب، فإن المباشر هو المسؤول عن الضمان؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض.

ويشترط في هذا الحكم عدة شروط، هي:

الشرط الأول: اجتماع المباشر والمتسبب في إلحاق الضرر بالغير، فإن انفرد أحدهما بالضرر نُسِب الحكم إليه، كما إذا حفر بئرًا فسقط فيه حيوان بنفسه، فإن الحافر يضمن؛ لانفراده بالتسبب.

الشرط الثاني: أن لا يكون للسبب تأثير قوي يؤدي إلى العمل بانفراده إلى الاتلاف: كما لو اجتمع على قيادة الدابة سائق وراكب عليها، فالضمان على المتسبب وعلى المباشر.

تطبيقات القاعدة:

● لو حفر أحد بئرًا في الطريق العام، فألقى شخص فيها مالًا لشخص آخر فتلف، ضمن الذي ألقى المال في البئر، ولا شيء على حافرها.

● لو دل شخص سارقًا على مال غيره فسرقه، فالضمان على السارق، بخلاف ما إذا كان الدالُّ وديعًا، فإنه يضمن لأنه مقصر في الحفظ.

القاعدة الرابعة: «جناية العجماء جبار»:

الجناية لغة: من جنى على قومه إذا أذنب وأجرم.

والجناية في الاصطلاح: (كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها).

والعجماء: في أصل اللغة يدل على السكوت والصمت وعدم الكلام، فيقال: بهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، وكذلك كل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم، والمراد بالعجماء في القاعدة: البهيمة.

معنىٰ القاعدة: إن الحيوان إذا أتلف شيئًا بالليل أو النهار من تلقاء نفسه، وبغير تفريط من مالكه، أو أتلف شيئًا وليس معه أحد من سائق أو قائد، فذلك غير مضمون على صاحبه.

تأصيل القاعدة:

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله ﷺ قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»[(١)]، قال الترمذي: يَقُولُ: هَدَرٌ لَا دِيَةَ فِيهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»، فَسَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: العَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ المُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ فِي انْفِلَاتِهَا فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، يَقُولُ: إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنًا فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ البِئْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ، وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ فِي دَفْنِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ[(٢)].

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ١٤٩٩.

(٢) سنن الترمذي، ج/ ٣ ص: ٦٥٣.

شروط عدم ضمان إتلاف البهائم:

الشرط الأول: أن تكون الجناية متعلقة بفعل إيجابي للحيوان، سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبب.

الشرط الثاني: أن تكون الجناية صادرة من تلقاء نفس الحيوان، كما لو قطعت الدابة رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها فأضرت أحدًا، فلا ضمان على صاحبها.

الشرط الثالث: أن تكون جناية العجماء واقعة بدون تعد أو تفريط من مالكها، كما لو امتنع صاحب الكلب العقور من ربطه أو حبسه، فألحق الضرر بالمارة ضمن صاحب الكلب العقور.

تطبيقات القاعدة:

- إذا جمحت الدابة بالراكب، ولم يقدر على ردها ومنعها، فإنه لا يضمن ما تتلفه من مال أو إنسان.
- لو أغرى إنسان كلبًا، فعقر رجلًا، ضمن المغري للكلب، سواء أكان الإتلاف فور الإغراء أم بعدئذٍ.
- لو أدخل شخص دابته في مزرعة غيره بإذنه، لا يضمن ما تتلفه الدابة هناك، لكن لو أطلقها في المزرعة بدون إذن مالك المزرعة، أو رآها فيها دون أن يطلقها هو، فلم يمنعها عن الزرع ضمن صاحب الدابة؛ لأنه يعتبر متعديًا ومقصرًا.



المبحث الثالث: فقه قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام

الحلال هو المباح الذي أذن الشرع في فعله، ولم يرد أمر بحظره.

والحرام هو الذي نهى الشارع عن فعله نهيًا جازمًا، ويتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة والدنيا.

وفيما يلي بيان لفقه بعض القواعد المتعلقة بهذا الباب:

القاعدة الأولى: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام):

معنىٰ القاعدة: إذا تعارض في المسألة وجهان: وجه إباحة، ووجه تحريم، إما في أصل مأخذ المسألة في الشريعة: كحديثين متعارضين أو قياسين متخالفين، وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة من حكمي الإباحة والتحريم، فيقدَّم الترك على الفعل والأخذ بما لا اشتباه فيه مما فيه اشتباه. كما يقدَّم التحريم على الكراهة إذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم، فالاحتياط حملها على التحريم؛ لأن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب؛ ولأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات.

تأصيل القاعدة:

قوله ﷺ: «**الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقىٰ المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعىٰ حول الحمىٰ، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمىٰ، ألا إن حمىٰ الله**

في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (١).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ» (٢)

وقَالَ: الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٣).

ويرجع سبب الاشتباه إلىٰ الأمور التالية:

السبب الأول: تعارض الأدلة:

السبب الثاني: الاختلاف في التطبيق وإنزال الحكم على الوقائع.

السبب الثالث: اختلاط الحرام بالحلال، وينقسم الاختلاط إلى قسمين:

أ- اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز، كاختلاط المائعات من الدم والخمر والبول.

ب- اختلاط استبهام بحيث يمكن تمييز الأعيان عن بعضها، لكن لا يستطيع أن يحدد العين المحرمة من غير المحرمة، ويندرج تحت هذا القسم ثلاث صور:

الصورة الأولىٰ: أن تستبهم العين المحرمة المحصورة بعدد محصور من الحلال، كما إذا اختلطت محرمة على شخص يريد الزواج بعشرة نسوة، فهذه شبهة يجب اجتنابها.

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٥٢.

(٢) سنن ابن ماجه،ح/ ٤٢١٥.

(٣) سنن الترمذي، ح/ ٢٥١٨.

الصورة الثانية: أن تستبهم العين المحرمة المحصورة بحلال غير محصور، كما إذا اختلطت أخت بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل هذا البلد.

الصورة الثالثة: أن تستبهم العين المحرمة غير المحصورة بحلال غير محصور- مثّلَ الإمام الغزالي لذلك بالأموال في زمانه- فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه، إلا إذا غلب على الظن أنه الحرام.

تطبيقات القاعدة:

- يحرم علي المسلم أكل الذبيحة التي ذكاها مسلم ومجوسي معًا.
- يحرم على المسلم نكاح من التبس أمرها أهي محرمة أم أجنبية.
- إذا اختلط درهم حلال بدرهم حرام وجب اجتنابهما دفعًا لمفسدة الحرام.

القاعدة الثانية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه:

هذه القاعدة تتعلق بالحلال والحرام؛ لأنها تمنع من الاقتراب من الحرام بالأخذ والإعطاء والإعانة عليه، فإذا كان أخذ الشيء حرامًا ممنوعًا على الناس فإعطاؤه حرام ممنوع أيضًا، أي: أن الحرمة على كل من الآخذ والمعطي فهو ممنوع عليهما؛ لذلك يترتب العقاب على المعطي كما يترتب على الآخذ، وقد يترتب على المعطي الضمان أيضًا كما يترتب على الآخذ، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة : ٢]، ولأن المعطي الذي يعين الفاعل على فعل الحرام يعد شريكًا له، كما يؤيد ذلك

قوله ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم في الإثم سواء»[١]، (وقد لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي).

تطبيقات هذه القاعدة:

- يحرم إعطاء الربا كما يحرم أخذه:
- ويحرم إعطاء الرشوة كما يحرم أخذها، ولا تملك بالقبض، ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي.
- يحرم إعطاء حلوان الكاهن، ودفع الأجرة للمغني، والزامر، والنائحة، والواشمة، والواشرة بين الأسنان.
- يحرم على الصيدلي إعطاء السم للمريض بدون وصفة الطبيب، وعليه العقاب.

ويستثنىٰ من ذلك:

- ما إذا كان الإعطاء لضرورة أو حاجة، مثل ما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان مضطرًّا أو محتاجًا.
- وما يُدفَع للشاعر أو الصحفي من مال للتخلص من شره وأذاه.
- وما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي.
- وما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السلطان أو الأمير، فإنه في جميع الأمثلة السابقة يحرم على الآخذ دون المعطي.

القاعدة الثالثة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن:

هذه القاعدة تمنع التصرف في ملك الغير بغير إذنه وإذن الشرع؛ ولذلك

رأى الشيخ مصطفى الزرقاء التعبير بعبارة: "بلا إذن" لتشمل إذن صاحب الملك وإذن الشرع وإذن العرف، ويرى الشيخ علي الندوي ضرورة إضافة لفظ: (بولاية) حتى تكون القاعدة أكثر جمعًا، ويقل عدد المستثنيات.

والتصرف في ملك الغير نوعان: فعلي وقولي.

فالنوع الأول: التصرف الفعلي، فإن كان تقدَّمَه إذن سابق يحل ويصح؛ لأن الإذن السابق توكيل، وإلا فلا يخلو عن أن يكون غصبًا بوضع اليد فقط، أو تصرفًا بإحداث ذي أثر أو إتلافًا، فإن كان غصبًا فهو محظور يوجب رد العين ومضمون بالتلف، إلا إذا لحقته إجازة المالك وكانت العين المغصوبة قائمة، فإنها بالإجازة تنقلب أمانة.

وإن كان التصرف بإحداث فعل ذي أثر في العين كالحفر في ملك الغير بلا إذنه، فليس للمالك أن يجبر الحافر على الطمِّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، بل بضمنه النقصان، بخلاف الحفر في الطريق العام، فإن الحافر فيه يجبر على الطمِّ اتفاقًا، ثم إذا نشأ عن حفر هذا ضرر كما إذا وقع حيوان في الحفرة فتلف يضمنه الحافر؛ لأنه متسبب متعد.

وإن كان إتلافًا فهو مضمون بكل حال، سواء أجاز المالك أو لا؛ لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف.

والنوع الثاني: التصرف القولي في ملك الغير: كبيع الفضولي وهبته وإجارته وغيرها، وهو إما أن يكون قوليًّا محضًا، أو أن يكون قوليًّا يعقبه فعل كالتسليم، فإن كان قوليًّا محضًا لم يعقبه تسليم فهو موقوف على إجازة المالك بشروطها

لزم، وشرطها بقاء المالك، وبقاء العين المتصرف فيها، وبقاء المتعاقدين، ويزاد في البيع: قيام الثمن لو غير نقد، ويزاد في الإجارة: بقاء المدة، وأما إذا كان التصرف قوليًّا يعقبه فعل كالتسليم كان المتصرف غاصبًا بالتسليم وضامنًا، وعقده موقوفًا، فإذا لحقته إجازة المالك بشروطها لزم القعد.

والمعنىٰ الإجمالي للقاعدة: ليس لأحد حق التصرف في ملك غيره إلا إذا أذن له المالك، وكذلك إذا كان له ولاية عليه؛ لأن الولي قائم مقام المولى عليه.

تطبيقات القاعدة ومستثنياتها:

- لا يجوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها؛ إذ لا ولاية لها في التصرف حال الصغر، ولا في الحفظ بعد الكبر.
- لا يجوز المشي في بستان الغير ولا السكن فيه، حتى لا يجوز إجابة دعوة من سكن في بستان مغصوب ولا عيادته.
- لا يجوز لأحد أن يستخدم جدار الغير بأن يضع عليه سقف بيته بلا إذن من جاره، وإذا فعل ذلك كان لجاره حق طلب رفع ذلك.
- لا يجوز لمن ليس له حق المرور في طريق خاص أن يفتح بابًا على ذلك الطريق بلا إذن مالكه، فإن فعل كان لصاحب الطريق طلب عند سدّ الباب.

ويستثنىٰ من هذه القاعدة بعض الفروع، منها:

أ- يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاج اليه الأب أو الابن للتمريض بلا إذنه للضرورة، ولا يجوز في غير الدواء كالمتاع أو الأثاث.

ب- يجوز لمن سقط ثوبه في حوش غيره، وخاف أن يخفيه الغير أن يدخل

لأخذه لعلامة، ولو بدون إذن صاحب الحوش للضرورة.

ج- يجوز للرفقة في السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغمي عليه أن ينفقوا عليه من ماله، كما يجوز لهم أن يبيعوا ما معه من ثياب وأمتعته لتجهيزه إذا مات، ورد ما بقي من أموال إلى الورثة، ووجه الاستثناء الضرورة.

القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة:

تتعلق بقاعدة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ذلك الغير بغير إذن» عدة قواعد، منها:

الأولى: قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل:

والمعنى الإجمالي للقاعدة: إذا أمر أحد غيره بأن يتصرف في ملك شخص آخر فلا عبرة بهذا الأمر، فإذا تصرف المأمور وكان عاقلًا بالغًا ولم يكن الآمر مجبرًا للمأمور، وترتب على تصرفه شيء، فالتبعة على المأمور لا على الآمر.

تطبيقات هذه القاعدة:

- إذا أمر أحد آخر بأن يحرق مال غيره فأحرقه، فالضمان على المأمور؛ لأن أمر هذا الآمر لا عبرة به.
- لو قال الدائن لمدينه عندما أراد أن يسلمه الدين: ارمه في البحر فرماه، فلا عبرة بهذا الأمر، ويبقى الدين بحاله في ذمة المدين؛ لأن المال الذي بيد المدين ملكه قبل أن يقبضه الدائن.
- إذا قال المودع للوديع: إذا مت فادفع هذه الوديعة لابني فلان ففعل،

وكان للميت المودع وارث آخر فإن الوديع يضمن؛ لأن الوديعة بعد موت الموقع تصبح ملكًا للورثة جميعًا، فأمره بالدفع إلى أحدهم باطل.

والحاصل أنه يشترط لإعمال القاعدة ثلاثة شروط، وهي:

أ- أن يكون التنفيذ في ملك الغير، أما إذا كان التنفيذ في ملك الآمر فلا ضمان على المأمور؛ لأنه إذن بالإتلاف.

ب- أن لا تكون للآخر ولاية ما على المال، كما لو أعار أحد الشركاء المال المشترك دون إذن شركائه، وأمر أحدًا أن يسلم العارية إلى المستعير فامتثل المأمور، فالضمان على الشريك لا على المأمور فيما لو هلكت العارية.

ج- أن لا يكون الآمر مجبرًا للمأمور على التنفيذ، وإلا كان الآمر ضامنًا.

الثانية: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي:

أسباب التملك الشرعية أربعة، وهي:

١- إحراز المباحات.

٢- والعقود.

٣- والخلفية.

٤- والتولد من المملوك.

فإحراز المباحات كحيازة الماء في المنابع والكلأ في المنابت والأشجار في البراري وسيد البر والبحر، ويشترط لذلك أن لا يكون قد سبق إلى إحراز المباح شخص سابق، فلو جمع إنسان ماء البحر في إناء فليس لغيره أن يأخذه، كما يشترط قصد التملك، فإذا حصل المباح في حوزة إنسان دون قصد منه لتملكه لا

يملكه، كمن نشر شبكته للتجفيف، فوقع فيها سيد لا يملكه.

وأما العقود فهي كالبيع والإجارة والهبة والكفالة والنكاح والخلع والوقف وغير ذلك، وأما الخليفة (بفتحتين مع تشديد الياء) فهي حلول شخص محل شخص كالإرث، وحلول شيء عن شيء كالتضمين أو التعويض.

وأما التولد من المملوك فهو لصاحبه، عملًا بقاعدة: ما يتولد أو ينشأ عن المملوك مملوك، فمالك الأصل هو أولى بفرعه من سواه، سواء في ذلك ما ينتج من تسبب مالك الأصل وعمله، وما يحصل بطبعه دون عمل مالك الأصل، فثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها، كلها مملوكة لصاحب الأصل.

أما ما عدا تلك الأسباب فيمنع التملك عن طريقها، كالتملك من طريق الظلم والاستغلال، كما في تحريم الربا والاحتكار والقمار والنصب والسرقة والتملك عن طريق الغش والخداع في السلع، كإخفاء عيوب السلعة، واصطناع الصفة الكاذبة فيها، والتملك عن طريق إلحاق الضرر بالغير، كالاتجار مع العدو، والاتجار بالخمر والمخدرات.

معنىٰ القاعدة: ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بسبب غير مشروع، كالغصب والسرقة والرشوة، سواء أكان الآخذ جادًّا أم هازلًا أم ناسيًا؛ لأن حقوق الناس محترمة، والنسيان والهزل لا يكون عذرًا في حقوق العباد، فإذا أخذ أحد مال غيره بوجه من الوجوه غير المشروعة وجب عليه رده إليه، وإذا هلك قبل رده إليه لزمه الضمان.

تطبيقات القاعدة:

- إذا غصب أحد مال شخص وجب عليه رده بعينه، فإن هلك قبل الرد

لزمه الضمان.

● إذا أخذ شخص مال غيره ها زلًا، وجب عليه أن يرده إليه، وإذا هلك قبل الرد لزمه الضمان.

● إذا صالح أحد آخر عن دعوى، ثم ظهر بعد ذلك أنه ليس له أي حق في الدعوى التي أقامها، كان له أن يسترد بدل الصلح، ومثال ذلك: ادعى المشتري وجوب عيب في السلعة التي اشتراها، وأنكر المدعى عليه (البائع) وجود العيب قبل البيع، ثم صالح المشتري البائع على أن يبرئه من العيب المذكور على مبلغ مائة دينار، ثم ظهر أن ليس في المبيع عيب، أو كان العيب جديدًا بعد عقد البيع، فإن للبائع أن يسترد المائة دينار.

● أن التقادم (مرور الزمن) يمنع فقط سماع الدعوى بالحق أو بالعين أمام القضاء، فلا تُسمع الدعوى بالحق الذي مرّ عليه زمن معين تجنيًا لعراقيل الإثبات ومشكلاته بعد التقادم، وللشك في الحق الذي تقادم عليه الزمن دون مطالبة له، ولكن أصل الحق لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز لمن كان تحت يده أن يتملكه، بل عليه رده في حكم الديانة؛ لأن التقادم ليس سببًا مملكًا من أسباب الملكية، وإنما هو حاجز قضائي.

❁ ❁ ❁

المبحث الرابع: فقه قواعد كلية خاصة بالقضاء وطرق الإثبات

القاعدة الأولى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

معنىٰ القاعدة: المدعي إذا ادعى حقًّا له على غيره يكلف لإثبات دعواه بإقامة البينة إذا كان المدعى عليه منكرًا للدعوى، فإن عجز المدعي عن إقامة البينة فإن المدعى عليه تتوجه إليه اليمين.

والبينة اسم لما يبين الحق ويظهره، فتارة تكون بأربعة شهود، وتارة ثلاثة بالنصّ في بينة المفلس، وتارة تكون شاهدين، وتارة شاهدًا واحدًا، وتارة امرأة واحدة.

تأصيل القاعدة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ»[1].

شروط الدعوى:

ويشترط في الدعوىٰ عدة شروط، منها:

١) ألا يسبق من المدعي ما يناقض دعواه، كما لو ادعى شخص ملكية دار بعد إقراره أنه استأجرها.

٢) أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت، فلا يصح ما هو مستحيل شرعًا أو عقلًا أو عادة.

٣) أن يكون المدعى به معلومًا مفصلًا فيه.

---

(١) صحيح مسلم، ح/ ١٧١١.

٤) أن تكون الدعوى ملزمة بشيء على الخصم.

٥) أن تكون الدعوى في مجلس القضاء، فلا يلزم المدعى عليه بالجواب إذا كانت في غير مجلس القضاء.

٦) أن يكون المدعى عليه معينًا في الدعوى.

٧) أن تكون الدعوى محققة، فلا تصح الدعوى بالظنون.

والضابط في التمييز بين المدعي والمدعى عليه: أن المدعي يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه يوافق قوله الظاهر، ويعرف الظاهر بعدة أمور أو مرجحات هي:

- البراءة الأصلية.
- العرف، فحيازة الشيء دليل على الملك، فالقول قول الحائز بيمينه.
- الاستصحاب، فمن ثبت له حق في حالة يحكم له باستمرار هذه الحالة.
- المعهود الشرعي: فالشارع ينص على حالات خاصة تتعلق بأصحابها بقبول أقوالهم ويفترض صدقهم حتى يثبت العكس، مثل الأمناء كالوصيّ والوليّ والوكيل والملتقط.

القاعدة الثانية: المرء مؤاخذ بإقراره:

معنىٰ القاعدة: الشخص إذا أقرّ بشيء على نفسه فإنه يلزم به، ولا ينفعه بعد ذلك ادعاؤه الخطأ في الإقرار، فمن أقرّ على نفسه بشيء ألزمناه إياه؛ لأن الإقرار سيّد الأدلة.

تأصيل القاعدة:

قال تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا﴾[البقرة: ٢٨٢].

وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد، قالا: كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي ﷺ: «**والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، عليك وعلىٰ ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس علىٰ امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها**»(١).

وموضوع القاعدة هو الإقرار الصادر من المرء، ويشترط فيه عدة شروط بعضها يتعلق بالمُقرّ، وبعضها يتعلق بالمُقرّ له، وبعضها يتعلق بالمُقرّ به، وبعضها يتعلق بصيغة الإقرار.

شروط المُقر:

أ- أن يكون مكلفًا (بالغًا، عاقلًا).

ب- أن يكون مختارًا غير مُكْرَه.

ج- أن يكون غير متهم في إقراره، كالمريض المقر لوارثه بدين عليه.

د- أن يكون المقر معلوم العين غير مجهول.

هـ- أن يكون نافذ التصرف غير محجور عليه.

و- أن يكون جادًّا غير هازل.

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٦٨٢٧.

شروط المُقر له:

أ- أن يكون معلوم العين غير مجهول.

ب- أن تكون له أهلية التملك.

ج- أن يكون مُصدقًا لما أقر به المقر.

د- أن يكون مستحقًّا للمقر به عقلًا وشرعًا.

شروط المُقر به:

أ- أن يكون معلومًا غير مجهول.

ب- أن لا يكون ملكًا للمُقر.

ج- أن يكون غير محال عقلًا ولا شرعًا، ولا يكذب به ظاهر الحال.

شروط صيغة الإقرار:

أ- أن تكون جازمة غير مفيدة للشك.

ب- أن تكون منجزة عير معلقة على المستقبل.

تطبيقات القاعدة:

- لو أقر عمر لزيد ألف دينار دينًا عليه، ثم ادعى الغلط والخطأ لم يقبل؛ لأن المرْأ مؤاخذ باقراره، وقد قرر الفقهاء: لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.

- إذا قبض المؤجر الأجرة من المستأجر وبعد إقراره بقبضها، ادعى أن النقود التي تسلمها مزيفة لا يقبل ادعاؤه .

القاعدة الثالثة: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة:

معنىٰ القاعدة: هذه القاعدة تتكون من شطرين: الشطر الأول: البينة حجة متعدية، والشطر الثاني: الإقرار حجة قاصرة، والبينة إذا أقيمت على الشخص كانت ملزمة له، وملزمة لغيره من الناس؛ لأن البينة برهان يكشف الواقع ويوضحه بالنسبة إلى جميع الناس، وليس خاصًّا بشخص معين، ولهذا كان الثابت بالبينة يُحتج به على سائر الناس.

تطبيقات القاعدة:

- إذا ثبت بالبينة نكاح امرأة من رجل، فلا تسمع من أحد في العالم بعد ذلك الدعوى على خلاف ذلك.
- إذا اشترى شخص من آخر سيارة بألف دينار، ثم ادعى شخص ثالث أن السيارة له وأقام بينة على ذلك، فإن الحكم يسري على البائع كما يسري على المشتري.
- إذا ادعى شخص أن له ألف دينار على شخص متوفى، ولم تثبت الدعوى بالبينة، بل بإقرار أحد الورثة الذي اتخذ المدعي خصمًا، فإن الحكم الذي يصدر بموجب الإقرار يختص بما يصيب حصة المقر من الدين إضافة إلى التركة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة وليست متعدية على غير المقر.



المبحث الخامس: فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية

السياسة في اللغة هي: تعهد الأمر بما يصلحه، وفي الاصطلاح: تدبير الأمر في الأمة داخلًا وخارجًا تدبيرًا منوطًا بالمصلحة.

وفيما يلي بيان لفقه بعض القواعد المتعلقة بالسياسة الشرعية:

القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:

معنى القاعدة: من كانت له ولاية على غيره عامة كانت أو خاصة، فتصرفه على ذلك الغير مرتبط بمصلحة من يتصرف له، فلا تكون تصرفاته على من هو في رعايته نافذة إلا إذا كان ذلك التصرف مصلحة له.

تأصيل القاعدة:

يرجع أصل هذه القاعدة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة، ومن الأدلة عليها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾ [النساء: ٥٨].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا﴾[الإسراء: ٣٤].

عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «**كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها،**

والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته»[١].

موضوع القاعدة: هو تصرفات كل من له ولاية غيره كالإمام والقاضي وناظر الوقف والوليّ والوصيّ والنائب في مجلس الأمة في النواب، وغير ذلك.

والولاية نوعان: عامة وخاصة.

فالولاية العامة: هي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة، وتصريف شئون الناس والأمر والنهي فيهم، ويندرج تحتها: الإمامة العظمى، وإمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، وإمارة الجيش، وإمامة الصلاة، وجباية الصدقات والخراج.

والولاية الخاصة: هي سلطة تمكن صاحبها من التصرف عن الغير، إما بمباشرة العقود عنه وترتيب آثارها دون توقف على رضاه، وإما بالتربية والرعاية للصغير كالولاية على النفس والحضانة.

ويشترط لإعمال هذه القاعدة عدة شروط، منها:

الشرط الأول: أن تتوفر في الولي شروط الوكيل؛ لأن الولي لا يتصرف لنفسه، وإنما هو وكيل عن غيره في القيام بشئونه.

ومن الشروط المشتركة في الولاية العامة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والعلم بالأحكام الشرعية، والقدرة على تحقيق مقاصد الولاية.

ويشترط في الولاية الخاصة: العقل، والبلوغ، والحرية، والقدرة على تحقيق مقاصد الولاية.

---

(١) صحيح البخاري، الآية: ٢٤٠٩.

والشرط الثاني: أن يتضمن التصرف منفعة للمولى عليه؛ لأن الولي مأمور من قبل الشارع أن يحوطه بالنصح، ولأنه وكيل عن الغير، فعليه أن يراعي خير التدابير لإقامة العدل وإحقاق الحق.

تطبيقات القاعدة:

- إذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بالأيتام، قدم الحاكم أقومهم بذلك، وأعرفهم بمصالح الأيتام، وأشدهم شفقه ومرحمة.
- لا يقدَّم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكائد الحرب.
- إذا قُتل شخص لا وليّ له فالسلطان وليه، لكن لا يصح أن يعفو عن القصاص مجانًصا؛ لأنه خلاف المصلحة.
- إذا أراد القاضي تزويج الصغيرة، فلا يزوجها لغير كفء؛ لأنه خلاف مصلحتها.
- لا يجوز للوالي أن يمنع من محاسبة من تحت يده أموال العامة والقاصرين.
- لا يجوز لمجلس الأمة أن يسنّ القوانين المخالفة للقرآن والسنة؛ لأنها منافية لمصلحة الأمة.

القاعدة الثانية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة:

معنى القاعدة: هذه القاعدة تتعلق بالسياسة الشرعية في الإدارة وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، فإذا وُجدت الولاية الخاصة فتقدم على الولاية العامة، وهذا ما يقضي به علم الإدارة اليوم، وفقًا لقاعدة توزيع الصلاحيات ومبدأ التدرج.

تطبيقات هذه القاعدة:

- إذا كان للصغير ولي، فليس للقاضي تزويجه حسب ولايته العامة.

- إذا كان لليتيم وصي، فليس للقاضي أن يتصرف في ماله، ولا أن يؤجر أملاكه.
- لا يحق للقاضي أن يعزل ناظر الوقف من قبل الواقف، ما لم تظهر عليه خيانة.

القاعدة الثالثة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

معنىٰ القاعدة: إذا كان الشخص يستحق شيئًا بسبب لم يحن بعد، فلم يصبر المستحق وعجل في حصوله بدون وجه حق ليتحقق له استحقاق الشيء، فإنه يعاقب بالحرمان من الاستحقاق، وقريب من هذه القاعدة:

من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده.

من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.

من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه.

تطبيقات هذه القاعدة:

- من قتل مورثه بغير حق يحرم من الميراث، كأن يقتله عمدًا.
- من قتل الموصى بغير حق يحرم من الوصية.
- إذا طلق زوجته في مرض موته بدون رضاها ومات وهي في العدة فإنها ترثه، ولا تحرم من الميراث بسبب الطلاق.

مستثنيات القاعدة: يستثنى من هذه القاعدة ما لو قتل الدائن المدين ليحل الدين المؤجل، فإنه يحل بالموت، ولا يمنع قتله له من حلول الدين.

المبحث السادس : فقه قواعد كلية خاصة بالاجتهاد الفقهي

الاجتهاد هو: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم ظني شرعي، والفقهاء أوردوا بعض القواعد المتلعقة بالاجتهاد الفقهي لكثرة حاجة الفقيه إليها، وهي:

القاعدة الأولى: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص):

معنىٰ القاعدة: لا يجوز الاجتهاد في قضية شرعية ورد نص واضح وصريح بحكمها؛ لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لا نصّ فيه، أو فيما فيه نصّ ولكن معناه محتمل، فيجتهد العالم في فهم ذلك النصّ.

تأصيل القاعدة:

قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾[الحجرات:١].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾[الأحزاب:٣٦].

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن هلال بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء، فقال النبي ﷺ: «البينة أو حد في ظهرك»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي ﷺ يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ﴾ [النور: ٦] فقرأ حتى بلغ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [النور: ٩] فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي ﷺ يقول: «**إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب**» ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة

وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي ﷺ: «**أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء**»، فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» (١).

تطبيقات هذه القاعدة:

- جاء النص الصريح في منع الخمر والميسر، فلا يجوز الاجتهاد في إجازتها.
- جاء النص الصريح في تحريم الربا، فلا مساغ للاجتهاد في إجازتها.
- ورد النص الصريح في أن للبنت نصف ميراث الابن، فلا يجوز الاجتهاد في مساواة البنت للابن في الميراث.

القاعدة الثانية: (الاجتهاد لا يُنقَض بمثله):

معنىٰ القاعدة: إذا اجتهد المجتهد في مسألة لم يرد فيها نص قطعي فحكم فيها حسب ما أوصله إليه اجتهاده، ثم وقعت مسألة مشابهة، فبدا له رأي آخر، فعدل عن حكم المسألة الأولى وحكم في الثانية بحكم آخر مناقض، فإن حكمه الثاني المتعلق بالمسألة الثانية لا يبطل حكم المسألة الأولى ولو كانت مشابهة للثانية، وسواء أكان هذا الاجتهاد من المجتهد الأول أم غيره.

تأصيل القاعدة:

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: «**لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة**»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال

(١) صحيح البخاري، ج/ ٤٧٤٧.

بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ، فلم يعنف واحدًا منهم(١).

ويدل أيضًا على هذه القاعدة إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حيث نقله ابن الصباغ، فإن أبا بكر الصديق حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ولم ينتقض حكمه.

ولإعمال هذا الحكم يشترط لهذه القاعدة عدة شروط، هي:

الشرط الأول: أن يكون الاجتهاد صادرًا فيما مضى، أما الاجتهاد الحالي أو المستقبلي فقد يتبدل ويعمل بما استقر عليه الاجتهاد.

الشرط الثاني: أن لا يكون الاجتهاد السابق مخالفًا لنص قطعي.

الشرط الثالث: أن لا يكون الاجتهاد السابق مبنيًّا على خطأ بيِّن أو ظلم وجور.

الشرط الرابع: أن لا يكون الاجتهاد السابق متعلقًا بمصلحة عامة، فإذا تغيرت المصلحة نقض الحاكم الاجتهاد السابق وفق مقتضى المصلحة.

تطبيقات هذه القاعدة:

- إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، ينبغي ألا يبطل الحكم باجتهاد آخر؛ لموافقة ذلك الحكم رأي المجتهد.
- إذا حكم القاضي برد شهادة رجل لفسقه، ثم تاب، فادعى الشهادة مرة ثانية لم تقبل شهادته؛ لأن قبول شهادته بعد التوبة يُعدّ نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد.

---

(١) صحيح البخاري، ح/ ٩٤٦.



الفصل الرابع

الضوابط الفقهية

يشمل هذا الفصل المباحث التالية:

- **المبحث الأول: الضوابط الفقهية في العبادات.**
- **المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المعاملات المالية.**
- **المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية.**
- **المبحث الرابع: الضوابط الفقهية في الجنايات.**
- **المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في القضاء.**



المبحث الأول: الضوابط الفقهية في العبادات

الضابط الأول (في الطهارة): «كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة»

المعنى الإجمالي للضابط: أن الأعيان النجسة إذا تحولت إلى أجناس أخرى بحيث إذا زالت الصفات المتعلقة بالاستقذار زال حكم التنجيس، وأصبحت طاهرة، وقد عبَّرالفقهاء عن هذا الضابط بتعبيرات متعددة، منها: "كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال حكم التنجيس" ومنها: "أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية منها كالسمك".

تأصيل القاعدة:

استدل الفقهاء لهذا الضابط بالأدلة التالية:

١) قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾[الأعراف:١٥٧].

٢) وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**إذا دُبغ الإهاب فقد طهر**»[(١)].

القيود الواردة في الضابط:

أ- تغير صفات العين النجسة من قذارة وطعم ولون ورائحة إلى صفات أخرى.

طيبه عن طريق الاستحالة، حيث يتحول الخبث والفساد إلى طيب وصلاح.

ب- أن يتبع تغير الصفات تغير الاسم، كما أشار إلى ذلك النبي ﷺ.

فقد سمى الخمر التي تخللت بالخل، وجلد الميتة بالإهاب.

تطبيقات الضابط:

- النجاسة كالميتة والدم إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا فإنها تطهر.

---

(١) صحيح مسلم، ح/ ٣٦٦.

- الخمر إذا انقلبت إلى خل بنفسها فإنها تكون طاهرة.
- المياه المحتوية على فضلات إنسانية نجسة من مخلفات صناعية ضارة بالصحة إذا عولجت، بحيث يتم التخلص مما فيها من مواد ضارة بالصحة طاهرة، ويجوز للإنسان استعمالها.

الضابط الثاني (في الصلاة): «الأصوات في الصلاة من جنس الحركات»:

المعنى الإجمالي للضابط: أن الأصوات الحلقية الصادرة من المصلي أثناء الصلاة: كالنحنحة والسعال والأنين والتأوه تنزل منزلة الحركات التي تصدر عن المصلي، مما هي ليست من جنس الصلاة، فتأخذ حكمها، لا حكم الكلام؛ لأن هذه الأصوات لا تسمى كلامًا في اللغة، ولو حلف شخص أن لا يتكلم لم يحنث بإصدار هذه الأصوات؛ إذ الكلام لا بدَّ فيه لفظ دال على معنى دلالة وضعية، فلا تبطل الصلاة بالصوت اليسير، كما لا تبطل بالحركة اليسيرة، أما إذا كانت كثيره فتبطل بها الصلاة.

تأصيل الضابط:

ما روي عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كان لي مع رسول الله ﷺ مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح»[(١)].

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ، قال: «**إنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطاسَ، ويَكْرَهُ التَّثاؤُبَ، فإذا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌّ علَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يُشَمِّتَهُ، وأَمَّا التَّثاؤُبُ: فإنَّما هو مِنَ الشَّيْطانِ، فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطاعَ، فإذا قالَ: ها، ضَحِكَ منه الشَّيْطانُ**»[(٢)].

---

(١) سنن النسائي، ح/ ١٢١٢.

(٢) صحيح البخاري رقم ٦٢٢٣.

تطبيقات الضابط:

- التأوه والأنين والتثاؤب والبكاء في الصلاة لا يبطلها؛ لأنها ليست كلامًا.
- النفخ في أثناء الصلاة لا يبطلها.

الضابط الثالث (في الزكاة): «الموطن الزكوي للمال هو حدود الإقليم عرفًا، وهو الذي يوجد فيه المال، مهما تباعدت نواحيه وقراه».

المعنىٰ الإجمالي للضابط: أن الموطن الزكوي للمال الذي تجب فيه الزكاة هو الإقليم، فلا تنقل زكاة ذلك المال من إقليم إلى إقليم، ولكن تنقل من ناحية إلى ناحية داخل الإقليم، وإن كان بينهما أكثر من مسافة القصر.

تأصيل الضابط:

يستدل لهذا الضابط بأن النبي ﷺ كان يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

القيود الواردة في الضابط:

أ) يتقيد الموطن الزكوي للمال الذي تجب فيه الزكاة بمكان وجود المال، وليس بمكان المالك.

ب) يتحدد الموطن الزكوي للمال بالإقليم عرفًا.

تطبيقات الضابط ومستثنياته:

يتفرع علىٰ هذا الضابط عدة فروع فقهية، منها:

١. الأصل في توزيع زكاة المال أن توزع في موطنها الزكوي، ولا تنقل منه إلا لمصلحة راجحة: كوجود قريب محتاج أو من هو أشد حاجه أو من هو أنفع للمسلمين: كطلبة العلم الذين يدرسون في الخارج، أو للجهاد في سبيل الله.

٢. الموطن الزكوي لزكاة الفطر هو إقليم المُخرِج للزكاة؛ لأنها لا تتعلق بمال معين، وإنما تتعلق بذمة الُمخرِج.

المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المعاملات المالية

تعريف المعاملات المالية: هي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال.

تقسيمات المعاملات المالية:

تشمل المعاملات المالية كلًّا من الموضوعات التالية:

أ- المعاوضات مثل: البيع، والإجارة.

ب- التبرعات مثل: الهبة والوقف.

ج- الإسقاطات مثل: الإبراء من الدين.

د- المشاركات والتوثيقات، مثل: الرهن، والكفالة، والحوالة.

الضابط الأول: إن جهالة المبيع أو الثمن إنما توجب فساد العقد إذا كانت مفضية إلىٰ المنازعة من التسليم والتسلم، أما إذا لم تكن مفضية فلا؛ لأن الجهالة لا تؤثر في العقد لذاتها، وإنما تؤثر لإفضائها إلىٰ المنازعة.

المعنى الإجمالي للضابط:

إن الجهالة في العقد نوعان:

النوع الأول: جهالة مفضية إلىٰ المنازعة، تمنع من التسليم والتسلم، كما لو قال شخص لآخر: بعتك جميع ما في هذه القرية بمليون دينار، فهذه جهالة فاحشة لا يحصل بها المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا فلا يصح.

النوع الثاني: جهالة غير مفضية إلىٰ المنازعة: بحيث يوجد التسليم والتسلم، ويحصل المقصود من العقد، كبيع دار بأساساتها، فالأساسيات مجهولة، ولكن لا تمنع التسليم والتسلم، فيصح العقد.

تأصيل الضابط وأدلته:

يستند هذا الضابط إلىٰ الأحاديث التالية:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١).

٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ»(٢).

أنواع الجهالة في الضابط:

١- الجهالة في المبيع وقد تكون:

في الذات، كأن يقول: بعتك شاة من هذا القطيع دون أن يحددها.

وفي الجنس، كقول البائع للمشتري: بعتك سلعة دون أن يسميها.

وفي النوع، كقول البائع للمشتري: بعتك قنطارًا من حنطة، والحنطة أنواع.

وفي المقدار، كأن يبيع البائع صبرة من قمح، دون معرفة مقدارها.

وفي الصفة، كأن يقول: بعتك قنطارًا من الأرز المصري.

٢- الجهالة في الثمن، وقد تكون: في الصفة، وفي المقدار.

تطبيقات هذا الضابط:

● رجل له عشرة من الغنم، وصبرة حنطة فيها عشرة أقفزة، فباعها من رجل آخر على أن كل قفيز وشاة بعشرة دراهم، فإن كانت الغنم عشرة والأفقز

---

(١) صحيح مسلم،ح/ ١٥١٣.

(٢) مسند أحمد، ح/ ٣٦٧٦.

عشرة كان البيع جائزًا؛ لأن جملة المبيع معلوم وهو عشرة أغنام بأعيانها وعشرة أقفز من الصبرة الواحدة لا تتفاوت، وهي معلومة بالإشارة إليها، ولا يقال: كل قفيز وكل شاة منها مجهول جهالة تفسد العقد؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ لأن كل شاة من العشر وكل قفيز عينهما البائع مبيعًا بثمن محدد، فلا يجوز للمشتري أن يمتنع عن تسلم المبيع.

● لو قال رجل لآخر: بعتك أحد القميصين بخمسة دنانير جاز؛ لأنه أشار إلى المبيع وعينه، فلا يفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم.

الضابط الثاني: إن الدَّينَين إذا اتفقا جنسًا ووصفًا: أحدهما للرجل علىٰ صاحبه، والآخر لصاحبه عليه وقعت المقاصة بينهما تقاصًّا أو لم يتقاصَّا؛ لأنه لا فائدة في بقائهما.

المعنىٰ الإجمالي للضابط: أن من ثبت له على غريمه مثل ما للغريم عليه من الدين جنسًا وصفة وحلولًا وقعت المقاصاة، وتساقط الدينان إن كانا متساويين في المقدار، وإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة.

تأصيل الضابط وأدلته:

١- أن مطالبة أحد الدئنين للآخر بمثل ما عليه من الدين عبث لا فائدة فيه، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية تنكر العبث.

٢- القياس: على ما إذا كان لوارث وحيد دَين على مورثة، فمات المورث سقط دين الوارث، ولا يؤمر بتسلمه لعدم الفائدة في قبضه، وتبرأ ذمة المورث المدين؛ لأن كل التركة انتقلت إلى الوارث.

القيود -الشروط - الواردة في الضابط:

١- اتحاد جنس الدَّينَين.

٢- اتحاد الدَّينَين في الوصف من جودة ورداءة.

٣- اتحاد الدَّينَين في الحلول أو التأجيل.

تطبيقات الضابط:

● لو أحرق زيد ألف كيلو قمح لبكر، وكان لزيد على بكر ألف كيلو قمح، فإذا كان القمح الذي أحرقه زيد مساويًا في الصفة لما له، وقعت المقاصاة الإجبارية، وإلا فلا.

● اعتبر الحنفية الدنانير والدراهم جنسًا واحدًا في كثير من الأحكام؛ ولذلك تقع المقاصاة الجبرية بينهما، في حين ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدنانير والدراهم جنسان، فلا تقع المقاصاة الجبرية بينهما لاختلاف الجنس، وهو الراجح.

الضابط الثالث (إسقاط الحقوق): إن كل ما كان حقًّا، صاحبه عامل فيه لنفسه، وكان قائمًا حين الإسقاط خالصًا للمسقط أو غالبًا، ولم يترتب علىٰ إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس متعلقًا بتملك عين علىٰ وجه متأكد، يسقط بالإسقاط، وإلا فلا.

هذا الضابط توصل إليه الشيخ أحمد الزرقاء بعد إعمال الفكر وإجالة النظر في فروع قاعدة: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود[1].

---

(١) قال الشيخ: لم أر من ذكر ضابطًا جَامعًا لما يسْقط من الْحُقُوق بِإِسْقَاط صَاحبه لَهُ وَمَا لَا يسْقط. وَبعد إِعْمَال الْفِكر وإجالة النّظر فِي الْفُرُوع السَّابِقَة ظهر لي من خلالها ضَابِط يغلب =

المعنى الإجمالي للضابط:

أن الحقوق التي تقبل الإسقاط من صاحبها هي ما توافرت فيها الشروط التالية:

١- أن تكون موجودة وقائمة عند الإسقاط، فلا يصح إسقاط حق قبل وجوده.

٢- أن لا يكون الحق عينًا من الأعيان؛ لأن إسقاط الأعيان لا يفيد زوال الملك.

٣- وأن تكون قابلة للإسقاط شرعًا، فلا يؤدي إلى تغيير وضع شرعي.

٤- وأن يكون خالصًا لصاحبه، فلا يجوز إسقاط حق تعلق به حق الغير.

ثانيًا: أدلة الضابط:

يستدل لجواز إسقاط الإنسان حقوقه بعددة أدلة، منها:

قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾[البقرة: ١٧٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾[البقرة: ٢٨٠].

ثالثًا: القيود – الشروط- الواردة في الضابط:

شروط المُسْقِطِ:

أ- أن يكون أهلًا للتبرع والتصرف، وذلك بأن يكون: بالغًا، عاقلًا، غير

=

على الظَّن صدقه وَصِحَّته، وَهُوَ: "أَن كل مَا كَانَ حَقًّا صَاحبه عَامل فِيهِ لنَفسِهِ، وَكَانَ قَائِمًا حِين الْإِسْقَاط خَالِصًا للمسقط أَو غَالِبًا، وَلم يَتَرَتَّب على إِسْقَاطه تَغْيِير وضع شَرْعِي، وَلَيْسَ مُتَعَلقًا بتملك عين على وَجه متأكد، يسْقط بالإسقاط، وَمَا لَا فَلَا. شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص: ٢٦٧.

محجور عليه لسفه أو دين.

ب- أن يكون مختارًا غير مكره.

ج- أن يكون مالكًا لما يتصرف فيه، عاملًا فيه بنفسه.

شروط في المُسقَطِ عنه:

أ- أن يكون معلومًا.

ب- وأن يكون معينًا.

ج- وموجودًا وقت الإسقاط، فلا يصح الإسقاط لمجهول أو ميت.

شروط محل الإسقاط (الحق):

أ- أن يكون موجودًا عند الإسقاط وقائمًا.

ب- أن لا يكون عينًا من الأعيان؛ لأن اسقاط الأعيان لا يفيد زوال الملك عن العين.

ج- أن يكون قابلًا للإسقاط شرعًا، فلا يصح إسقاط الحقوق التي قررها الشارع لصحة المعاملات.

د- أن يكون خالصًا للمسقط، فلا يجوز إسقاط حق تعلق به حق للغير، كالحدود والتعازير.



المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية

الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية:

الضابط الأول : «العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار إلا في العنة على الأصح».

يتعلق هذا الضابط بالعيوب الموجودة في الزوج وأثرها في فسخ عقد الزواج، فإذا علمت الزوجة بتلك العيوب قبل عقد الزواج، ورضيت بها لم تعط حق فسخ عقد الزواج إلا في حالة العنة عند بعض الفقهاء.

أقسام العيوب:

تنقسم العيوب الموجبة للفسخ بالنكاح إلى ثلاثة أقسام:

١. عيوب خاصة بالرجل: الجب، العنة، والخصاء.

٢. عيوب خاصة بالمرأة : الرتق، القرن، والعفل.

٣. عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة: الجدام، البرص، الجدام، الجنون، الخنوثة والعقم.

قيود الضابط:

يثبت خيار الفسخ والإمضاء في عقد الزواج للزوجة بالقيود التالية:

أ- وجود عيب في الرجل: كالجب أو العنة أو الخصاء، ويستدل لذلك بالإجماع والقياس، وقال القاضي عياض رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "اتفق الفقهاء على أن للمرأة حقًا في الجماع، فثبت لها الخيار إن تزوجت المجبوب جاهلة به". واستدلوا بالقياس على ثبوت الخيار في البيع إذا كان المبيع معيبًا".

ب- أن تكون المرأة جاهلة بالعيب عند العقد، وإلا إذا علمت ورضيت سقط حقها في خيار الفسخ قياسًا على رضا المشترى بالعيب عند البيع، فإنه يمنع الرد وخيار الفسخ، ويستثنى من ذلك علم الزوجة بالعنة ورضاها، فإنه لا يسقط حق الخيار؛ لأن العنة تتغير بتغير المرأة والزمن.

ج- أن يكون العيب في الزوج قديمًا، أي: قبل عقد الزواج أو يكون مقارنًا له، فإن كان العيب طارئًا فلا خيار للزوجة عند الحنفية، خلافًا للجمهور الذين يرون ثبوت حقها في الفسخ لتضررها بذلك، وهو الراجح.

تطبيقات الضابط:

● إذا علمت الزوجة عند عقد الزواج بما في الزوج من عيب: كالجب والخصاء، واختارت الإمضاء والمقام معه، بطل حقها في فسخ عقد الزواج، ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح؛ لأنها رضيت بالعيب، فسقط خيارها.

● إذا اختلفت الزوجة مع الزوج في العلم بالعيب في الزوج، فادعت الزوجة عدم العلم وادعى الزوج علمها، فالقول قول الزوجة، وعلى الزوج إثبات ذلك العلم بالبينة.

الضابط الثاني: «جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا أربعة: بنات أعمامه، وأخواله، وعماته، وخالاته، بخلاف أصهاره، فإن كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة: حلائل الآباء، وحلائل الأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن».

هذا الضابط يحصر المحرمات في النكاح نسبًا وصهرًا.

أدلة الضابط:

أ- قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾[النساء:٢٣].

ب-وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾[النساء:٢٢].

الضابط الثالث: «**كل فُرقة بين الزوجين تعد طلاقًا إذا أوقعها الزوج، أو نائبه، أو فوض الطلاق إلىٰ زوجته، وإن كل فرقة لم ينطق بها الزوج ولم يردها أن تقع فأوقعت فهذه فرقة لا تسمىٰ طلاقًا، بل فسخًا**».

هذا الضابط يتعلق بوضع حد فاصل بين ما يعدُّ طلاقًا وما يعد فسخًا، فالفرقة التي تأتي من قبل الزوج أو نائبه أو بتفويضه إلى زوجته تعدُّ طلاقًا، أما الفرقة التي لا يريدها ولا ينطق بها فهي فسخٌ.

الأسباب الموجبة بالتفريق:

- التفريق بالضرر.
- التفريق بالعيب.
- الإيلاء.
- فساد عقد الزواج.
- فقد الزوج.
- التفريق بالإعسار.
- التفريق بالردة.
- اللعان.
- الحكمين.

المبحث الرابع: الضوابط الفقهية في الجنايات

الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة مصدر جنى أي: أذنب ذنبًا يؤاخذ به، وهي بالمعنى العام: كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها، وخصها الفقهاء بالجرح والقطع المتعلقين بالنفس الإنسانية، والمراد بها هنا المعنى العام، وهو: الفعل أو الترك أو التسبب إذا أضرَّ بالنفس أو بغيرها واستوجب عقوبة دنيوية، ويندرج تحت الجنايات ما يتعلق بالقصاص والحدود والتعزيرات.

الضابط الأول (قتل الغيلة) هو: «**كل قتل عمد عدوان علىٰ غرة أو علىٰ وجه الخداع والمخاتلة، بحيث يتعذر معه الخلاص لغرض يقصد القاتل من مال ونحوه**».

المعنى الإجمالي لهذا الضابط: هذا الضابط يتعلق بقتل الغيلة وعقوبته.

وقتل الغيلة: هو أن يخدع شخصًا حتى يصير به إلى موضع خفي، فيقتله[١].

واعتبره التسولي المالكي نوعًا من أنواع الحرابة، فقال: فَأَما الغيلة فَهِيَ من أَنْوَاع الْحِرَابَة، وَهِي أَن يقْتله لأخذ مَاله أَو زَوجته أَو ابْنَته، وَكَذَا لَو خدع كَبِيرًا أَو صَغِيرًا، فيدخله موضعًا خَالِيًا ليَقْتُلهُ، وَيَأْخُذ مَاله[٢].

قيود هذا الضابط:

١- القتل العمد على وجه الخداع والمخاتلة، ويؤيد ذلك حديث العرنين، عن

---

(١) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج/ ١٢ ص: ٢١٠.

(٢) البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السلام .بن علي، أبو الحسن التُّسُولي، بتحقيق: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م ج/ ٢ ص: ٦١٨.

أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلًا، فقال: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله» فأتوها، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأتى النبي ﷺ الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة، يستسقون فما سقوا، حتى ماتوا[1].

فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء قتلوا الرعاة قتل غيلة وغدر وخداع ومخاتلة.

٢- أن يكون القتل بقصد أخذ المال أو العرض أو غير ذلك، كما أشار الحديث العرنيين السابق.

٣- أن يتم القتل في مكان يعتذر فيه الإغاثة، كما أشار إلى ذلك حديث العرنيين، حيث استفرد العرنيون بالرعاة في الصحراء، وهي مكان يعتذر فيه الإغاثة.

الضابط الثاني (في الحرز) «إن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز مثلها»:

هذا الضابط يتعلق بحرز المال المسروق، فلا يعد أخذ مال الغير سرقة إلا إذا كان هذا المال بالغًا النصاب ومحرزًا بحرز مثله، فإن أُخِذ من غير حرز فلا قطع على آخذه.

---

(١) البخاري، ح/ ٦٨٠٤.

ويؤيد اشتراط هذا الحرز ماروي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: سمعتُ رجلًا من مُزينَة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، جئتُ أسألك عن الضَّالّة من الإبل؟، قال: "معها حذاؤُها وسقاؤُها، تأكل الشجر، وتَرِدُ الماء، فَدعْها حتي يأتيها باغِيها"، قال "الضَّالَّةُ من الغَنَم؟، قال: "لك أو لأخيك أو للذِّئب، تجْمَعها حتِى يأتيها باغيها، قال: الحِريسةُ التي تُوجد في مَراتعها؟، قال: "فيها ثمنها مرتين وضرْبُ نَكَالٍ، وما أُخِذَ من عطَنه ففيه القَطعُ، إذا بَلَغ ما يؤخذُ من ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ"، قال: يا رسول الله، فَالثِّمَارُ، وما أُخِذَ مِنها في أكمامها؟، "من أخَذ بِفَمه، ولم يتَّخذْ خُبْنَةً، فليس عليه شيء، ومن احْتَمَل، فعليه ثمنُه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخَذ من أجْرانه، ففيه القَطعُ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثَمنَ المِجَنِّ"، قال: يا رسول الله؛ واللُّقَطَةُ نجدها في سبيل العامرة؟، قال: "عرِّفْها حَوْلًا، فإن وُجد بَاغيها، فأدِّها إليه، وإلا فهي لك"، قال: ما يوجد في الخَرِبِ العَادِيّ؟، قال: "فيه وفي الرِّكاز الخُمُسُ"[1].

معاني مفردات الحديث:

الحريسة: يُقال للشَّاة الَّتي يُدْرِكُها اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُرَاحها: حَرِيسَة.

عطن: مَبْرَك الإبلِ حَولَ الْمَاءِ، يُقَالُ: عَطَنَتِ الْإِبِلُ فَهِيَ عَاطِنَة وعَوَاطِن إِذَا سُقِيت وبَركت عِنْدَ الحِياضِ لتُعَاد إِلَى الشُّرب مرَّة أخْرى.

المجنّ: هُو التُّرْس، لِأَنَّهُ يُوَارِي حَامِلَه، أَيْ: يَسْتُره.

---

(١) مسند الإمام أحمد، ح/ ٦٦٨٣.

خُبْنَةً: مَعْطِفُ الإزارِ وطرَفُ الثَّوب: أَيْ لَا يأخُذ مِنْهُ فِي ثَوبه، يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبأ شَيْئًا فِي خُبْنه ثَوْبِهِ أَوْ سَراويله[١].

الضابط الثالث: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»: هذا الضابط يتعلق بالمسكرات والمخدرات، فيحرم كل ما أسكر، وإذا أسكر كثيره فقليله حرام.

تأصيل هذا الضابط من الكتاب: قوله تعالى: ﴿**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ**﴾[المائدة: ٩٠].

ومن السنة: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»[٢].

❁ ❁ ❁

(١) يراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.
(٢) صحيح مسلم، ح/ ١٧٣٣.

المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في القضاء

من الكتب المعاصرة التي جمعت القواعد والضوابط الفقهية كتاب: القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام لإبراهيم الحريري، وهو كتاب مهم في هذا الموضوع.

وفيما يلي بعض الضوابط المتعلقة بالقضاء:

الضابط الأول: كتاب القاضي إلىٰ مثله كالخطاب له في إثبات الحكم:

هذا الضابط يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي، وهو أن يكتب القاضي إلى القاضي ما يسمعه من الشهادة أو ما قضى به على شخص ويرسله إلى قاض آخر ويعمل به بموجب ما فيه ويسمى: "الكتاب الحكمي".

وقد اتفق الفقهاء على جواز الإثبات بكتاب القاضي والعمل به. (ويؤيد ذلك ما **روي أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَىٰ العَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّىٰ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: «وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ**[1].

وثبت عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه عمل بكتاب القاضي، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا، ولأنه قد يتعذر على صاحب الحق الجمع بين الخصوم والشهود في مجلس واحد، كما يصعب أن يحضر الشاهد إلى بلد قاضي المدعي، فيتعرض الحق إلى السقوط والضياع، فالحاجة

---

(١) سنن الترمذي، ح/ ١٤١٥.

داعية إلى الأخذ بكتاب القاضي.

الضابط الثاني: تقوم القرينة القاطعة والراجحة مقام البينة في إثبات الحقوق:

هذا الضابط يتعلق بالقرائن ودورها في الإثبات.

والقرينة لغة: من قرن الشيء بالشيء إذا شده ووصله أو جمع بينهما.

والقرينة في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب، وبعبارة أخرى: ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحًا فيه، وهي على نوعين: **قرينة قاطعة، وقرينة غير قاطعة.**

ومن صور القرينة في القضاء: **القسامة، والقيافة، والفراسة، والحيازة.**

فالقسامة: أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به جراحة أو أثر ضرب أو خنق ولا يعلم من قتله، يقسم خمسون رجلًا من أهل تلك المحلة أو الدار: كأن يقول كل واحد منهم: والله ما قتلته ولا علمت له قاتلًا، فقد أقر النبي ﷺ العمل بها على ما كانت في الجاهلية.

والقيافة في اللغة: تتبع الآثار.

وفي الاصطلاح: إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم. وأصل ذلك **أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»، قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ** (١).

والفراسة لغة: من أفرس الشخص فراسة وتفرست فيه الخير، تعرفته بالظن الصائب.

---

(١) صحيح مسلم، ح/ ١٤٩٦.

والفراسة في الاصطلاح: الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾[الحجر: ٧٥]، أي: للمتفرسين أو الناظرين، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: ٣٠].

والحيازة: هي وضع اليد على الشيء زمنًا طويلًا أو الاستيلاء عليه،

وتكون الحيازة مشروعة في حالة ما إذا كان الشيء المحوز غير مملوك كالاصطياد والاحتشاش وإحياء الموات، واستخراج ما في باطن الأرض، وتكون غير مشروعة في حالة ما إذا كان الشيء المحجوز مملوكًا لأحد؛ لأن وضع اليد على المال المملوك لا يعد سببًا مشروعًا للتملك، وإنما هو من قبيل الغصب والسرقة والحرابة.

الضابط الثالث: كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد، أو دفع مغرم عنه ترد.

هذا الضابط يتعلق بالتهمة في الشهادة، فترد شهادة كل من جر بها نفعًا أو مغنمًا لنفسه للتهمة؛ لأن التهمة تقدح في التصرفات إجماعًا، ويندرج تحت هذا الضابط عدة صور، منها:

أ- القرابة: فلا تُقبَل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا الولد لوالده وإن علا عند جمهور الفقهاء، كما لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها.

ب- الخصومة والعداوة، بأن لا يكون الشاهد خصمًا للمشهود عليه وهو من يبغضه ويتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته.

ج- أن يشهد لغريمه المفلس أو شريكه، أو أن يشهد الوكيل فيما هو وكيل فيه.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

١- صحيح البخاري.

٢- الأدب المفرد، البخاري.

٣- صحيح مسلم.

٤- النسائي.

٥- مسند أحمد.

٦- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩.

٧- النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

٨- التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

٩- المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا.

١٠- القواعد الكلية والضوابط الفقهية، الدكتور محمد عثمان شبير، ط: ٢سنة: ١٤٢٨هـ. دار النفائس- الأردن.

١١- الأم للشافعي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة: بدون طبعة. سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

١٢- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
١٣- الفروق، للقرافي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٤- الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
١٥- بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
١٦- مجموع الفتاوى، ابن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
١٧- شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء.
١٨- البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي، بتحقيق:محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.

الفهرس

المُقدِّمَة ٥
وميزة هذا الكتاب ٦
الفصل الأول: حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية ٩
المبحث الأول: معنى القواعد الكلية والضوابط الفقهية والعلاقة بينهما ١٠
المبحث الثاني: القواعد الفقهية والعلوم المشابهة ١١
أولاً: النظريات الفقهية ١١
ثانيًا: القواعد الأصولية ١٢
ثالثًا: القواعد المقاصدية ١٣
رابعًا: الأشباه والنظائر ١٤
خامسًا: الفروق الفقهية ١٥
سادسًا: القواعد القانونية والمبادئ العامة ١٥
المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها ١٧
نشأة علم القواعد الفقهية وتطوره ٢١
المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها ٢٩
المطلب الأول: أنواع القواعد الفقهية ٢٩
المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية ومكانتها ٣١
الفصل الثاني: فقه القواعد الكلية الكبرى ٣٥
المبحث الأول: فقه قاعدة: الأمور بمقاصدها ٣٦
القواعد التي تتعلق بقاعدة: الأمور بمقاصدها ٤٣
القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: الأمور بمقاصدها ٤٦
المبحث الثاني: فقه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك ٤٧
تطبيقات القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ٥٢
القواعد التي تتعلق بقاعدة: اليقين لا يزول بالشك ٥٢
الفرع الأول: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ٥٢
الفرع الثاني: (الأصل براءة الذمة) ٥٣
الفرع الثالث: الأصل في الأمور العارضة العدم ٥٤
الفرع الرابع: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت ٥٥
الفرع الخامس: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) ٥٧
الفرع السادس: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل) ٥٧
الفرع السابع (لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح) ٥٨
ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ٥٨
المبحث الثالث: فقه قاعدة : الضرر يزال ٦٠
تأصيل قاعدة (الضرر يزال) ٦٠

نصوص تدل على إزالة الضرر ٦١
القواعد تتعلق بقاعدة : الضرر يزال. ٦٤
القاعدة الأولى: (تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح ٦٤
القاعدة الثانية (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) ٦٥
القاعدة الثالثة: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما) ٦٥
القاعدة الرابعة: (الضرر يُدفَع بقدر الإمكان) ٦٦
ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة (الضرر يزال) ٦٧
القاعدة الأولى: (الضرر لا يزال بمثله) ٦٧
القاعدة الثانية: الضرر لا يكون قديمًا ٦٧
المبحث الرابع: فقه قاعدة: المشقة تجلب التيسير ٦٨
أسباب وجود المشقة ثمانية ٧٠
أنواع المشقة ٧٥
أنواع التيسير(الرخص) ٧٧
فائدة: الرُّخَصُ أَقْسَامٌ ٧٧
القواعد التي تتعلق بقاعدة (المشقة تجلب التيسير) ٧٨
الفرع الثاني: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) ٨٠
الفرع الثالث: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) ٨١
ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أوضوابط لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) ٨١
القاعدة الثانية (ما جاز لعذر بطل بزواله) ٨٢
القاعدة الثالثة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) ٨٣
القاعدة الرابعة (الاضطرار لا يبطل حق الغير) ٨٥
المبحث الخامس فقه قاعدة: العادة محكمة ٨٦
أنواع العادة أو العرف ٨٨
الفرع الثاني: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ٩٣
الفرع الثالث: الحقيقة تترك بدلالة العادة. ٩٤
الفرع الرابع: الكتاب كالخطاب ٩٤
الفرع الخامس: الإشارة المعهود للأخرس كالبيان باللسان ٩٥
الفرع السادس: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ٩٦
الفرع السابع: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ٩٦
أسباب تغير الزمان ٩٧
ثانيًا: القواعد التي تمثل قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: العادة محكمة ٩٩
القاعدة الأولى: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ٩٩
القاعدة الثانية: العبرة للغالب الشائع لا النادر. ٩٩
مستثنيات قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا النادر ١٠٠
المبحث السادس فقه قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) ١٠٥

الفرع الأول: الأصل في الكلام الحقيقة.....١٠٩
الفرع الثاني: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.....١٠٩
الفرع الثالث: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.....١١٠
الفرع الرابع: التأسيس أولى من التأكيد.....١١١
الفرع الخامس: المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة.....١١١
الفرع السادس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.....١١٣
الفرع السابع: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.....١١٣
الفرع الثامن: السؤال معاد في الجواب.....١١٤
ثانيًا: القواعد التي تعد قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.....١١٥
القاعدة الأولى: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.....١١٥
القاعدة الثانية: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به.....١١٥
الفصل الثالث: فقه القواعد الكلية الصغرى.....١١٧
المبحث الأول : فقه قاعدة كلية عامة: التابع تابع.....١١٩
القواعد التي تمثل فروعا لقاعدة: التابع تابع.....١٢١
الفرع الأول: قاعدة (التابع لا يفرد بالحكم).....١٢١
الفرع الثاني: قاعدة (من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته).....١٢١
الفرع الثالث: قاعدة (التابع يسقط بسقوط المتبوع).....١٢٢
ثانيًا: القواعد التي تعد قيدًا أو ضابطًا لقاعدة: التابع تابع.....١٢٣
ثالثًا: القواعد التي تعد استثناء من قاعدة: التابع تابع.....١٢٣
المبحث الثاني : فقه قواعد كلية خاصة بالضمان.....١٢٥
القاعدة الأولى: الخراج بالضمان.....١٢٥
القاعدة الثانية: «الغُرم بالغُنم».....١٢٨
القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.....١٢٩
القاعدة الرابعة: «جناية العجماء جبار».....١٣٠
شروط عدم ضمان إتلاف البهائم.....١٣١
المبحث الثالث: فقه قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام.....١٣٢
القاعدة الأولى: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام).....١٣٢
القاعدة الثانية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.....١٣٤
القاعدة الثالثة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.....١٣٥
الأولى: قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.....١٣٨
الثانية: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.....١٣٩
المبحث الرابع: فقه قواعد كلية خاصة بالقضاء وطرق الإثبات.....١٤٢
القاعدة الأولى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.....١٤٢
القاعدة الثانية: المرء مؤاخذ بإقراره.....١٤٣
القاعدةالثالثة: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.....١٤٦

المبحث الخامس: فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية ١٤٧
القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ١٤٧
القاعدة الثانية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ١٤٩
القاعدة الثالثة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ١٥٠
المبحث السادس : فقه قواعد كلية خاصة بالاجتهاد الفقهي ١٥١
القاعدة الأولى: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) ١٥١
القاعدة الثانية: (الاجتهاد لا يُنقَض بمثله) ١٥٢
الفصل الرابع: الضوابط الفقهية ١٥٥
المبحث الأول: الضوابط الفقهية في العبادات ١٥٦
الضابط الأول (في الطهارة) ١٥٦
الضابط الثاني (في الصلاة) ١٥٧
الضابط الثالث (في الزكاة) ١٥٨
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المعاملات المالية ١٥٩
الضابط الأول ١٥٩
الضابط الثاني ١٦١
الضابط الثالث (إسقاط الحقوق) ١٦٢
المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية ١٦٥
الضابط الأول ١٦٥
الضابط الثاني ١٦٦
الضابط الثالث ١٦٧
المبحث الرابع: الضوابط الفقهية في الجنايات ١٦٨
الضابط الأول (قتل الغيلة) ١٦٨
الضابط الثاني (في الحرز) ١٦٩
الضابط الثالث ١٧١
المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في القضاء ١٧٢
الضابط الأول ١٧٢
الضابط الثاني ١٧٣
الضابط الثالث ١٧٤
المصادر والمراجع ١٧٥
الفهرس ١٧٧

هـــذا الـكـتـاب

هو تهذيب واختصار لكتاب: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - للدكتور محمد عثمان شبير

وميزة هذا الكتاب أنه اعتمد واستفاد من جُلّ أو كلّ كتب من سبقوه في التأليف في هذا الموضوع، وبهذا يمكن وصف الكتاب بأنه زبدة الدراسات في موضوع القواعد الفقهية.

ولما رأيت الكتاب بهذه المكانة العظيمة- ورأيت أن المؤلف جزاه الله خيرًا- توسع في بعض الموضوعات، وأدخل في الكتاب بعض المباحث التي لا تتصل اتصالاً مباشرًا بموضوع القواعد الفقهية؛ مما يثقل كاهل الطالب المبتدئ في دراسة القواعد الفقهية- عزمت على تهذيب الكتاب. واتبعت المنهج التالي:

١- اختصار العبارات التي أوردها المؤلف بإسهاب وتوسع بحيث لا تخل بالمعنى وتفي بالغرض.

٢- إيـــــراد الـقـاعـــــدة.

٣- ذكـر الـتأصيل الشرعي للقاعـدة.

٤- ذكـر الـمعـنى الإجـمـالي للقاعـدة.

٥- إيراد الشروط المتعلقة بمفردات القاعدة.

٦- تـطـبـيـقـات الـقـاعـــــدة.

٧- ذكر القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية.

٨- تـطـبـيـقـات الـقـواعـد الـفـرعـيـــــة.

٩- ذكر القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطًا أو استثناء للقاعدة الكلية.

١٠- تـطـبـيـقات القواعـد الـتي تـمـثـل قيداً أو ضابطًا.

١١- تـوثـيـق الـنـصـوص مـن مـصـادرهـا الأصـلـيـة.

١٢-زيادة بعض الموضوعات التي لم يذكرها المؤلف والتي نقلتها من مصادر أخرى.

Hud Hud
BOOKS